第一章 行政法基本理论

第一节 行政法基础

【高频考点】行政法的渊源（★★）

（一）行政法的渊源体系构成

<table>
<tr><td colspan="2">渊源</td><td colspan="2">制定主体</td><td colspan="2">说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">宪法</td><td colspan="2">全国人民代表大会</td><td colspan="2">宪法是国家的根本大法，具有最高法律地位和法律效力，是各项立法的依据</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">法律</td><td>基本法律</td><td>全国人民代表大会</td><td colspan="2">如《行政诉讼法》《行政处罚法》</td></tr>
<tr><td>一般法律</td><td>全国人大常委会</td><td colspan="2">如《税收征管法》《治安管理处罚法》《行政复议法》《行政强制法》</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">行政法规</td><td colspan="2" rowspan="2">国务院</td><td>依职权制定</td><td>如《国有土地上房屋征收与补偿条例》《行政复议法实施条例》《税收征管法实施细则》《车船税法实施条例》</td></tr>
<tr><td>依授权制定</td><td>如《增值税暂行条例》</td></tr>
<tr><td rowspan="2">规章</td><td>部门规章</td><td colspan="2">国务院各部委、中国人民银行、审计署、具有行政管理职能的直属机构</td><td colspan="2">如《发票管理办法实施细则》《税务行政复议规则》《纳税担保试行办法》</td></tr>
<tr><td>地方规章</td><td colspan="2">省、自治区、直辖市的人民政府</td><td colspan="2">——</td></tr>
</table>

		设区的市、自治州的**人民政府**	——
地方性法规		省、自治区、直辖市**人大及其常委会**	不得与宪法、法律、行政法规相抵触
		设区的市、自治区**人大及其常委会**	
民族自治条例、单行条例		自治地方的**权力机关**	①自治区的自治条例和单行条例，报全国人大常委会批准后生效； ②自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市人大常委会批准后生效，并报全国人大常委会和国务院备案
其他渊源		国际条约和国际协定中涉及国内行政管理部分，对行政活动具有约束力的法律解释以及行政机关制定和经公告发布的规范性文件	

（二）行政法渊源中效力冲突的解决方式

法律渊源效力冲突	解决方式
法律新的一般规定 vs 法律旧的特别规定	全国人大常委会裁决
行政法规新的一般规定 vs 行政法规旧的特别规定	国务院裁决
授权制定的法规 vs 法律	全国人大常委会裁决
地方性法规 vs 部门规章	国务院提出意见： （1）地方性法规直接适用 （2）部门规章→全国人大常委会裁决
部门规章 vs 部门规章	国务院裁决
部门规章 vs 地方政府规章	国务院裁决

第二节 行政主体

【高频考点】行政机关及其工作人员（★★★）

（一）中央行政机关

名称	组成或举例	是否是行政主体
国务院	即中央人民政府，最高权力机构的执行机关，是最高国家行政机关	是
国务院组成部门	即国务院职能机关，是负责国家行政管理某一方面事务或某些职能的工作机构，是国务院的组成部分，依法对某一方面的行政事务具有全国范围内的管理权限。 包括国务院各部委，如自然资源部、农业农村部、退役军人事务部、应急管理部、人力资源和社会保障部、交通运输部、财政部、生态环境部、司法部、商务部、住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会及中国人民银行和审计署等。	是
国务院直属特设机构	国务院国有资产监督管理委员会（国资委）性质上属于直属特设机构，也作为国务院机构设置的重要组成部分。	是
国务院直属机构	国务院直属机构，是国务院主管某项专门业务的机构。如中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、国家国际发展合作署、国家广播电视总局、海关总署、国家体育总局以及国家统计局、国家医疗保障局、国家知识产权局、国家信访局等（名称多带“总”，但有例外。）	是
国务院办事机构	国务院办事机构属于国务院内部机构。如国务院研究室	不是
国务院直属事业单位	国务院直属事业单位作为国务院机构设置的重要部分，具体包括中国气象局、国务院发展研究中心、新华通讯社、中央广播电视总台、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院等。 经法律、法规授权的，可以成为行政主体。	一般不是，但法律法规授权时是
国务院部委管理的国家局	国务院部委管理的国家局，是国务院根据国家行政事务管理的需要，依法设立的由相应部委实施管理的行政主管职能部门，如公安部管理的国家移民管理局、交通运输部管理的国家铁路局、中国人民银行管理的国家外汇管理局、文化和旅游部管理的国家文物局、国家发展和改革委员会管理的国家能源局、自然资源部管理的国家林业和草原局、应急管理部管理的国家矿山安全监察局以及国家发展和改革委员会管理的国家数据局等。	是

（二）地方行政机关

地方行政机关，是指活动范围及管辖事项仅限于国家一定行政区域范围内的行政机关，其组成包括地方各

级人民政府及其职能部门、派出机关等。

（三）行政机关工作人员

（1）	概念	即公务员
（2）	职位分类	综合管理类、专业技术类和行政执法类
	职务分类	领导职务和非领导职务
（3）	公务员的权利	①获得履行职责应当具有的工作条件； ②非因法定事由、非经法定程序，不被免职、降职、辞退或者处分； ③获得工资报酬，享受福利、保险待遇； ④参加培训； ⑤对机关工作和领导人员提出批评和建议； ⑥提出申诉和控告； ⑦申请辞职； ⑧法律规定的其他权利
（4）	不得录用为公务员的情况	①因犯罪受过刑事处罚的； ②被开除中国共产党党籍的； ③被开除公职的； ④被依法列入失信联合惩戒对象的； ⑤有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。

第三节 行政行为

【高频考点】行政程序法（★★★）

（一）行政程序法的基本原则

公开原则	除法律另有规定，行政主体必须将行政行为在事前、事中、事后公开于行政相对人和有关利害关系人。主要体现在行政依据公开、行政程序公开、行政信息公开、行政决定公开等方面
公正原则	行政主体在作出行政行为时，要平等地对待当事人各方，排除各种可能造成不平等或偏见的因素
参与原则	行政主体在实施行政行为的过程中，行政相对人有权参与行政过程，并有权对行政行为发表意见
效率原则	时效制度，简易程序、紧急处置程序也是效率原则的重要体现和具体实现

（二）行政程序法的基

本制度

	制度	含义
1	信息公开制度	指凡是涉及行政相对人权利、义务的行政信息资料，除法律规定应予以保密的以外，行政主体及有关机构依法向社会公开，任何公民或组织均可依法获取。
2	回避制度	（1）与当事人有利害关系的行政执法人员应主动回避。 （2）若不主动回避，当事人有权提出要求其回避的请求
3	行政调查制度	是行政主体依法获取证据材料的一种行政程序制度。包括： （1）调查权限 （2）调查程序
4	告知制度	在进行某项行政行为之前对行政相对人享有哪些权利、承担哪些义务，如何行使有关权利、履行有关义务以及其他有关事项，负有以书面或口头形式告知相对人并加以指导的义务
5	催告制度	（1）当事人不自觉履行义务，行政主体督促当事人在一定期限内履行义务，否则承担被强制执行后果的一种程序。 （2）催告是强制执行行政决定的前置程序，是行政强制执行的核心程序
6	听证制度	是行政主体在作出影响行政相对人合法权益的决定前，行政主体告知决定理由和听证权利，行政相对人表达意见、提供证据，以及行政主体听取意见、质证等所构成的一项行政程序基本法律制度
7	行政案卷制度	即行政机关作出的行政决定应当以行政案卷为根据，行政机关不能在行政案卷以外，以当事人所未知悉的或者未由当事人申辩、质证的事实作为根据来作出行政决定
8	说明理由制度	行政主体应将作出行政决定所依据的事实上和法律上的理由对行政相对人说明，即说明理由制度。 （1）行政机关对作出影响行政相对人权利义务的决定应持慎重态度，抑制其随意性，保障和提高其公正性； （2）便于行政相对人获知行政机关作出对其产生不利影响的行政决定的确切理由，并可为申请行政复议或提起行政诉讼时提供方便
9	教示制度	行政机关对行政相对人正式作出某种不利决定时，将有关法律救济权利事项明确地告知的一种行政程序法律制度。内容主要有： （1）行政机关应当告知相对人向什么机关提出法律救济以及请求获得法律救济的法定时限； （2）行政机关应当告知行政相对人提出法律救济的法定方式，如书面方式还是口

		头方式等； （3）行政机关如不履行该教示程序，应当承担不利于己的法律后果
10	时效制度	对行政主体的行政行为给予时间上的限制以保证行政效率和有效保障当事人合法权益的程序制度

第二章 行政许可法律制度

第一节 行政许可法基础

【高频考点】行政许可法的基本原则（★★★）

1.**法定原则**。

包括许可**设定**法定、主体及权限法定、实施程序法定等。

2.**公开、公平、公正原则**。

（1）**规范公开**：未经公开的法律规范不得作为许可的法律依据。这里主要是指内部的法律文件不得作为法律依据；

（2）行政许可的过程要公开，但是涉及国家秘密、商业秘密及个人隐私的**除外**。

未经申请人同意，行政机关及其工作人员、参与专家评审等的人员**不得披露**申请人提交的商业秘密、未披露信息或者保密商务信息，法律另有规定或者涉及**国家安全、重大社会公共利益**的除外；行政机关依法公开申请人前述信息的，允许申请人在合理期限内提出异议。

（3）符合法定条件、标准的，申请人有依法取得行政许可的平等权利，行政机关**不得歧视任何人**。

3.**便民和效率原则**。

如公示制度、一次申请制度、当场更正制度、一次告知补正制度、相对集中行政许可制度、期限时效制度等

4.**救济原则**。

公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有陈述权、申辩权；有权依法申请**行政复议**或者提起**行政诉讼**；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求**赔偿**。

5.**信赖保护原则**。

（1）含义

①行政机关不得擅自改变已经生效的行政行为；

②确需改变的，由此给相对人造成的损失应当予以补偿。

（2）特征

①取得的许可正当，相对人基于其对许可行为的合理信赖，受到法律保护；

②行政机关和被许可人都无过错；

③行政机关撤回或变更许可造成当事人财产损失的，应予以补偿。

6.**行政许可不得转让原则**。

除法律、法规另有规定的外，被许可人不得转让行政许可权利。

7.**监督原则**。

（1）县级以上人民政府应当建立健全对行政机关实施行政许可的监督制度，加强对行政机关实施行政许可的监督检查。

（2）行政机关应当对公民、法人或者其他组织从事行政许可事项的活动实施有效监督。

【高频考点】行政许可事项（★★）

（一）概念与设定程序

概念		特定的国家机关，通过一定的形式，创设行政许可事项的活动。
设定的有关程序	听证、论证制度	拟设定行政许可的，起草单位应当采取听证会、论证会等形式听取意见。
	许可评价制度	已经设定的许可，应定期进行评价，根据需要进行修改或废止。
	停止实施制度	省、自治区、直辖市人民政府对行政法规设定的有关经济事务的行政许可，根据本行政区域经济和社会发展情况，认为其是可以不设定行政许可的事项的，报国务院批准后，可在本行政区域内停止实施该行政许可。

（二）设定行政许可的事项（熟悉）

1.可以设定行政许可的事项

事项	举例
（1）直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动——普通许可	如出入境许可、治安许可、爆炸物生产运输许可等
（2）有限自然资源的开发利用、公共资源配置、直接关系公共利益的特定行业的市场准入——特许	如无线电频率使用、狩猎、采伐许可等
（3）提供公共服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质——认可	如医师资格、教师资格、律师资格等
（4）直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的	如特种设备的年检、航空器适航的认定等

重要设备、设施、产品、物品，需要按照一定技术标准、技术规范，通过检验、检疫等方式进行审定的事项——核准	
（5）企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格（并非所有登记均属于许可事项）——企业登记 【注意】纳税人取得一般纳税人资格的纳税主体登记事项，不属于此类事项范围	如企业登记、社会组织登记
（6）法律、行政法规规定可以设定行政许可的其他事项	——

2.可不设定许可的事项

（1）公民、法人或其他组织能够自主决定的——如考试用书的选择。

（2）市场竞争机制能够有效调节的。

（3）行业组织或中介机构能够自律管理的。

（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。

3.税务行政许可事项

（1）指定企业印制发票审批

（2）对纳税人**延期缴纳罚款**的核准（推动调整为其他权利事项）

（3）对纳税人**延期申报**的核准（推动调整为其他权利事项）

（4）对纳税人**变更纳税定额**的核准（推动调整为其他权利事项）

（5）增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批

（6）对采取实际利润额预缴以外的**其他企业所得税预缴方式**的核定（推动调整为其他权利事项）

【注意】目前，税务行政许可事项仅保留了“增值税专用发票（增值税税款系统）最高开票限额审批”。

（三）行政许可设定权划分

名称	行政许可设定权	备注
法律	是确定适用行政许可的主要依据	采矿许可、草原使用许可、伐木许可等，以及国民健康权、环境权、劳动权等只能由法律设定
行政法规	尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可	
部门规章	不能设定行政许可	
国务院的决定	必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可	决定属于规章以下的规范性文件，不是行政法的渊源
地方性法规	尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可	①不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或其他组织的资格、资

地方 规章	省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可	质的许可； ②不得设定企业或其他组织的设立登记及其前置性许可。
	其他主体制定的，不能设定行政许可	

第二节 税务行政许可的实施

【高频考点】税务行政许可实施主体（★★★）

（一）实施主体

行政机关	（1）税务机关在法定权限内实施，下属的事业单位一律不得实施； （2）没有法律、法规、规章的规定，税务机关不得委托其他机关实施税务行政许可。
具有管理公共事务职能的组织	如证券业协会、律师协会、注册会计师协会等。
受委托的行政机关	（1）受委托主体只限于行政机关； （2）受委托行政机关在委托范围内，以委托行政机关名义实施行政许可； （3）许可行为的法律后果由委托行政机关承担； （4）不得再委托其他组织或者个人实施行政许可。 【注意】委托机关应当将受委托行政机关和受委托实施行政许可的内容予以公告

（二）实施主体的其他有关规定

1.相对集中行政许可权的原则规定。

经国务院批准，**省、自治区、直辖市人民政府**可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权。

2.一个窗口对外、统一办理或联合办理、集中办理的规定。

（1）行政许可需要**行政机关**内设的多个机构办理的，该行政机关**应当**确定一个机构统一受理行政许可申请，统一送达行政许可决定。

（2）行政许可依法由地方人民政府**两个以上部门**分别实施的，本级人民政府可以确定一个部门受理行政许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或者组织有关部门联合办理、集中办理。

3.行政机关及其工作人员办理行政许可事项应当遵守的纪律约束规定。

4.专业技术标准或者技术规范的行政许可应当逐步授权专业组织实施的指导性规定。

（三）税务行政许可实施机关

1.税务机关在法定权限内实施，下属的事业单位一律不得实施；

2.没有法律、法规、规章的规定，税务机关不得委托其他机关实施税务行政许可；

3.税务机关应当按照“窗口受理、内部流转、限时办结、窗口出件”的要求，由办税服务厅或者政府服务大厅设立的窗口集中受理行政许可申请，送达行政许可决定。（“一个窗口对外”）。

【高频考点】税务行政许可实施程序（★★★）

（一）申请

	行政许可	税务行政许可
公示义务	行政机关在申请阶段负有“八项公示”义务，即行政机关应当将法律、法规、规章规定的有关行政许可的**事项、依据、条件、数量、程序、期限**以及**需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本**等在办公场所公示	税务机关除“八项公示”义务外，增加一项**“服务指南”**
申请人	申请人**可以委托他人**提出行政许可申请，但是依法应当由申请人到行政机关办公场所提出申请的除外	申请人**可以委托代理人**提出申请，税务机关不得拒绝受理。代理人办理受托事项时，应当出具**有效身份证件和委托证明**
申请方式	行政相对人可以书面形式上门递交申请，也可以采用现代化通信手段，如信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式	申请人可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件和网上办理平台等方式提出申请
申请材料	申请人应当如实向行政机关提交有关材料反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。 行政机关**不得**要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。 行政机关及其工作人员**不得**以转让技术作为取得行政许可的条件；**不得**在实施行政许可的过程中，直接或间接地要求转让技术	税务行政许可实施机关与申请人不在同一县（市、区、旗）的，申请人可在规定的申请期限内，选择由其主管税务机关代为转报申请材料。 主管税务机关在核对申请材料后出具材料接收清单，并向税务行政许可实施机关转报。代办转报一般应当在 5 个工作日内完成。有条件的税务机关可以通过信息化手段实现申请资料网上传递
格式文本	申请许可需要采用申请书格式文本的，行政机关应当提供文本，文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容	——

（二）受理

	行政许可	税务行政许可
不受理	申请事项依法**不需要取得行政许可**的，应当即时告知申请人不受理	申请事项属于税务机关管辖范围，但**不需要取得税务行政许可的**，应当即时告知申请人不受理，同时告知其解决的途径
不予受理	申请事项依法**不属于本行政机关职权范围的**，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请	申请事项依法**不属于本税务机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定**，制作并送达《**税务行政许可不予受理通知书**》，并告知申请人向有关行政机关申请
告知补正材料	申请材料存在**可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正**； 申请材料**不齐全或者不符合法定形式的，**	申请人申请材料存在**可以当场更正的错误的，应当告知并允许申请人当场更正。** 申请材料**不齐全或者不符合法定形式的，应当**

	应当当场或者在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理	**当场或者在5日内一次告知**申请人需要补正的全部内容，制作并送达《**补正税务行政许可材料告知书**》；逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理
受理	申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。	申请事项属于本税务机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本税务机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理税务行政许可申请，制作并送达《**税务行政许可受理通知书**》。
	行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证	税务机关制作《税务行政许可不予受理通知书》《税务行政许可受理通知书》《补正税务行政许可材料告知书》，应当加盖本税务机关印章（或者许可专用章）并注明日期。但是，对能够当即办理的税务行政许可事项，直接出具和送达《准予税务行政许可决定书》，不再出具《税务行政许可受理通知书》

（三）审查

	行政许可	税务行政许可
审查形式	**形式**审查，看申请材料是否齐全、是否符合法定形式； **实质**审查，对申请材料的实质内容，就其真实性、合法性进行书面审查。如果需要对申请材料的实质内容进行核实，也可以进行实地核查，但是应当指派**两名以上工作人员**进行	税务机关审查税务行政许可申请，应当以书面审查为原则； 根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行实地核实的，应当指派**两名以上税务人员**进行核查
告知义务	进行审查时，发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。申请人、利害关系人有权进行陈述和申辩。行政机关应当听取申请人、利害关系人的意见	

（四）决定

类型	行政许可	税务行政许可
准予行政许可	决定应采用**书面形式**：《准予行政许可决定书》。 准予行政许可的决定，应当**公开**，公众有权查阅。 准予行政许可的决定，应当**自作出决定之日起10日**内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章	制作并送达《准予税务行政许可决定书》，加盖本税务机关印章（或者许可专用章）。 在作出**准予税务行政许可决定之日起7日内**，在办税服务厅或者其他办公场所以及税务机关门户网站上**公开**税务行政许可决定。 需要颁发税务行政许可证件的，应当**自作出决定之日起10日内**向申请人颁发加盖本税务机关印章的税务行政许可证件
不予行政许可	决定应当采用**书面形式**：《不予行政许可决定书》 应当**书面说明理由**，包括事实、法律以及自	制作并送达《不予税务行政许可决定书》，加盖本税务机关印章（或者许可专用章） 应当**书面说明理由**。

	由裁量是否符合法定目的，告知复议、诉讼的权利	告知申请人享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利

【提示】行政机关作出准予行政许可的决定，需要颁发行政许可证件的，应当向申请人颁发加盖本行政机关印章的下列行政许可证件：

①许可证、执照或者其他许可证书；

②资格证、资质证或者其他合格证书；

③行政机关的批准文件或者证明文件；

④法律、法规规定的其他行政许可证件。

行政机关实施检验、检测、检疫的，**可以在检验、检测、检疫合格的设备、设施、产品、物品上加贴标签或者加盖检验、检测、检疫印章**。

（五）听证

1.听证程序的两种类型

类型	行政许可	税务行政许可
依职权	**法律、法规、规章规定**实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他**涉及公共利益**的重大行政许可事项，行政机关**应当向社会公告**，并举行听证	**法律、法规**规定实施税务行政许可应当听证的事项；税务机关认为需要听证的其他**涉及公共利益**的税务行政许可事项
依申请	行政许可直接**涉及申请人与他人之间重大利益关系**的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利； 申请人、利害关系人提出听证的期限是在**被告知听证权利之日起 5 日内**，行政机关应当在收到听证申请后 20 日内组织听证	税务行政许可直接**涉及申请人与他人之间重大利益关系**，申请人、利害关系人在**被告知听证权利之日起 5 日内**提出听证申请的事项

2.程序

	行政许可	税务行政许可
听证通知	行政机关应当在**举行听证 7 日前**通知申请人、利害关系人有关听证时间、地点，必要时予以公告	
听证公开	听证**应当公开**举行	
听证回避	**审查许可申请的工作人员不得担任听证主持人；申请人、利害关系**人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，**有权申请回避**	
听证笔录	听证应当**制作笔录**，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。行政机关应当**根据听证笔录，作出行政许可决定**	
听证费用	申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用，该费用由行政主体承担	

（六）行政许可的变更与延续

	行政许可	税务行政许可

变更	变更属于被许可人的权利，随时可向作出行政许可决定的行政机关提出要求	被许可人要求变更税务行政许可事项的，税务机关应当自收到申请之日起20日内作出是否准予变更的书面决定
延续	延续须在有效期届满30日前提出申请，**法律、法规、规章**另有规定的除外。行政机关在有效期届满前决定，逾期的视为准予延续。这就是一种默视批准制度。 **默视批准只适用于延续申请，不适用于初次申请许可和变更许可**	被许可人需要延续依法取得的税务行政许可的有效期的，应当在该税务行政许可有效期届满30日前向作出税务行政许可决定的税务机关提出申请。但是，**法律、法规**另有规定的，依照其规定。 税务机关应当根据被许可人的申请，在该税务行政许可有效期届满前作出是否准予延续的书面决定。逾期未作决定的，视为准予延续

第三章 行政处罚法律制度

第一节 行政处罚法基础

【高频考点】行政处罚法的基本原则（★★★）

（一）处罚法定原则

1.处罚设定权法定。处罚设定权法定，是指哪些法律规范可以设定行政处罚及其设定哪些种类的行政处罚必须按照法律的规定进行。

2.行政处罚依据法定。凡法律、法规、规章没有规定予以处罚的行为，均不受处罚。处罚必须有法律、法规或者规章依据，否则行政处罚是违法的，应属无效。行政主体对于法定应予行政处罚的行为，应当依法定处罚种类和内容进行处罚。

3.行政处罚主体法定。行政处罚是一种行政权力，除法律、法规、规章规定有处罚权的行政机关及法律法规授权的组织外，其他机关或者组织不得行使。另外，法定主体行使处罚权时必须遵守法定的职权范围，不得越权或者滥用权力。

4.行政处罚程序法定。行政机关作出的行政处罚决定违反法定程序的，人民法院判决撤销并可以责令被告行政机关重新作出行政处罚决定。行政机关作出的行政处罚决定违反法定程序构成重大且明显违法的。如符合听证条件当事人要求听证而不举行听证的，处罚无效。

（二）处罚公开、公正、过罚相当原则

1.公开原则的含义

（1）要求行政处罚的依据要公开，凡是作为处罚依据的规定应当是事先公布的；

（2）要求实施行政处罚的执法过程要公开，如依法表明执法身份、公开举行听证会听取意见、处罚的事实和理由公开、处罚决定公开等。

2.公正原则的含义

（1）实行调查制度，要防止偏听偏信；

（2）要使当事人了解其违法行为的性质并给予其申辩的机会；

（3）要防止自查自断，实行查处分开、审执分开制度。

3.过罚相当原则要求，立法所设定的违法行为与行政处罚相适应，作出行政处罚必须以事实为根据，与违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度相当，处罚轻重适度。即重过重罚、轻过轻罚，准确适用依法从轻、减轻处罚规定，作出的处罚符合设定该处罚的目的，相同情况相同处罚；处罚应采用最必要的方式，处罚符合比例原则、合乎情理且有可行性、符合客观规律。

（三）处罚与教育相结合原则

1.行政处罚的目的是纠正违法行为，减少和消除违法行为，教育当事人自觉守法，处罚只是手段而不是目的。

2.行政机关在实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为，对情节轻微的违法行为也不一定都要实施行政处罚。但是，行政机关未责令当事人改正或者限期改正违法行为即作出行政处罚的，虽**然违反行政处罚的法律原则，但并不直接导致行政处罚程序违法，不会导致行政处罚行为的无效或撤销。**

3.处罚与教育相结合，既非意味着可以以罚代刑，也不意味着可以以教代罚。

（四）保障相对人权益原则（无救济即无处罚原则）

1.公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权；

2.对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；

3.公民、法人或者其他组织因行政机关违法给予行政处罚受到损害的，有权依法提出赔偿要求。

（五）监督制约、职能分离原则

1.行政机关对违法行为的调查与审理分离；

2.作出罚款决定的机关与收缴罚款的机构分离；

3.听证主持人与调查检查人员分离；

4.行政机关执法人员当场作出的处罚决定向所属行政机关备案，体现了监督制约原则。

（六）一事不二罚（款）原则

对违法行为人的同一个违法行为，不得以同一事实和同一依据给予两个（次）以上的同类（罚款）处罚。

《行政处罚法》第29条规定，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

第二节 行政处罚的种类和设定

【高频考点】行政处罚的种类（★★★）

理论分类	一般行政处罚的种类
财产罚	①罚款

	②没收违法所得、没收非法财物
行为罚	③限制开展生产经营活动、责令停产停业、**责令关闭、限制从业** ④暂扣许可证件、**降低资质等级、**吊销许可证件
精神罚	⑤**警告、通报批评**
人身自由罚	⑥行政拘留

【高频考点】行政处罚的设定（★★）

1.行政处罚的创设

法律渊源	权限
法律	**①可以设定各种行政处罚。** ②限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定
行政法规	**可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。**
地方性法规	**①可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。** ②法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。 ③法律、行政法规对违法行为未作出行政处罚规定，地方性法规为实施法律、行政法规，可以补充设定行政处罚。 ④拟补充设定行政处罚的，**应当**通过听证会、论证会等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明
部门规章	①国务院部门规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。 ②国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可**以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚，罚款的限额必须由国务院规定。** ③“一定数量罚款”幅度 对非经营活动中的违法行为设定罚款不得超过 1000 元； 对经营活动中的违法行为，有违法所得的，设定罚款不得超过违法所得的 3 倍，但是最高不得超过 30000 元，没有违法所得的，设定罚款不得超过 10000 元； 超过上述限额的，应当报国务院批准
地方政府规章	①尚未制定法律、法规的，地方政府规章对违反行政管理秩序的行为，可以**设定警告、通报批评或者一定数额罚款**的行政处罚。 ②罚款的限额由“省、自治区、直辖市人大常委会”规定
其他规范性文件	除法律、法规、规章外，不得设定行政处罚

第三节 行政处罚的实施主体、管辖及适用

【高频考点】行政处罚的管辖和适用（★★★）

（一）行政处罚的管辖

1.地域管辖

行政处罚由**违法行为发生地**的行政机关管辖，法律、行政法规、部门规章另有规定的，从其规定。

【例】《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》：海关行政处罚由发现违法行为的海关管辖，也可以由违法行为发生地海关管辖。

2.级别管辖

行政处罚由**县级以上地方人民政府**具有行政处罚权的**行政机关**管辖，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

3.管辖权下移

（1）省、自治区、直辖市根据当地实际情况，**可以决定**将基层管理迫切需要的县级人民政府部门的行政处罚权交由能够**有效承接**的**乡镇人民政府、街道办事处**行使，并定期组织评估。决定应当**公布**。

（2）承接行政处罚权的乡镇人民政府、街道办事处应当加强执法能力建设，按照规定范围、依照法定程序实施行政处罚。

（3）有关地方人民政府及其部门应当加强组织协调、业务指导、执法监督，建立健全行政处罚协调配合机制，完善评议、考核制度。

4.共同管辖

两个以上行政机关都有管辖权的，由**最先立案**的行政机关管辖。

5.指定管辖

对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请**共同的上一级**行政机关指定管辖；也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖。

6.协助

行政机关因实施行政处罚的需要，可以向有关机关提出协助请求。协助事项属于被请求机关职权范围内的，应当依法予以协助。

7.移送

（1）违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。

（2）对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚，但应当给予行政处罚的，司法机关应当及时将案件移送有关行政机关。

8.税务行政处罚

税务行政处罚由**税收违法行为发生地**的具有行政处罚权的主管税务机关（包括稽查局）实施。

（二）行政处罚的适用

不予处罚	1.不满 14 周岁的人有违法行为的，**不予行政处罚**，责令监护人加以管教； 2.精神病人、智力残疾人在**不能辨认或者不能控制自己行为**时有违法行为的，**不予行政处罚**，但应当责令其监护人严加看管和治疗。 3.违法行为**轻微**并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 4.**初次违法**且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚； 5.违法行为在 2 年内未被发现的，不再给予行政处罚； 6.涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，该期限延长至 5 年； 7.当事人有证据足以证明没有主观错误的，不予行政处罚。
从轻或减轻处罚	1.已满 14 周岁不满 18 周岁的未成年人有违法行为的； 2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 6.法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。

（三）行政处罚的追究时效

1.一般违法行为。

违法行为在**2 年内**未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民**生命健康安全、金融安全**且有**危害后果**的，上述期限延长至**5 年**。法律另有规定的除外。

2.起算时点。

（1）规定期限，从**违法行为发生之日**起计算。

（2）违法行为有连续或者继续状态的，从**行为终了之日**起计算。

【注意 1】连续状态，是指行为人基于同一个违法故意，连续实施数个独立的同一种类的行政违法行为。

【注意 2】继续状态，是指一个违法行为在时间上的延续。

3.税收违法行为。

《税收征收管理法》：违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为在**5 年内**未被发现的，不再给予行政处罚。

4.治安管理违法行为。

《治安管理处罚法》：违反治安管理行为在**6 个月**内没有被公安机关发现的，不再处罚。

第四节 行政处罚程序

【高频考点】行政处罚决定程序（★★★）

（一）行政处罚的一般规定

1.查明事实

公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，依法应当给予行政处罚的，行政机关必须查明事实；

违法事实不清、证据不足的。**不得**给予行政处罚。

2.电子技术监控设备

（1）行政机关依照法律、行政法规规定利用电子技术监控设备收集、固定违法事实的，应当经过法制和技术审核，确保电子技术监控设备符合标准、设置合理、标志明显，**设置地点**应当向社会**公布**。

（2）电子技术监控设备记录违法事实应当真实、清晰、完整、准确。行政机关应当审核记录内容是否符合要求；**未经审核**或者**经审核不符合要求**的，**不得**作为行政处罚的证据。

（3）行政机关应当及时告知当事人违法事实，并采取信息化手段或者其他措施，为当事人查询、陈述和申辩提供便利。不得限制或者变相限制当事人享有的陈述权、申辩权。

3.执法人员

行政处罚应当由**具有行政执法资格**的执法人员实施。执法人员**不得少于 2 人，法律**另有规定的除外。执法人员应当文明执法，尊重和保护当事人合法权益。

4.回避

（1）执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，应当回避。

（2）当事人认为执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，有权申请回避。

（3）当事人提出回避申请的，行政机关应当依法审查，由行政机关负责人决定。决定作出之前，**不停止**调查。

5.告知

行政机关在作出行政处罚决定之**前**，应当告知当事人**拟**作出的行政处罚**内容**及**事实、理由、依据**，并告知当事人依法享有的**陈述、申辩、要求听证**等权利。

6.陈述、申辩

（1）当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。

（2）行政机关**不得**因当事人陈述、申辩而给予**更重**的**处罚**。

7.证据

（1）证据类型

①书证；

②物证；

③视听资料；

④电子数据；

⑤证人证言；

⑥当事人的陈述；

⑦鉴定意见；

⑧勘验笔录、现场笔录。

（2）证据必须经查证属实，方可作为认定案件事实的根据。

（3）以**非法手段**取得的证据，**不得**作为认定案件事实的根据。

8.归档

行政机关应当依法以文字、音像等形式，对行政处罚的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录，归档保存。

9.公开

（1）**具有一定社会影响**的行政处罚决定应当依法公开。

（2）公开的行政处罚决定被依法变更、撤销、确认违法或者确认无效的，行政机关应当在**3日**内撤回行政处罚决定信息并公开说明理由。

10.突发事件

发生重大传染病疫情等突发事件，为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，行政机关对违反突发事件应对措施的行为，依法快速、从重处罚。

11.保密

行政机关及其工作人员对实施行政处罚过程中知悉的**国家秘密、商业秘密**或者**个人隐私**，应当依法予以保密。

（二）简易程序

1.适用条件

违法事实确凿并有法定依据，对**公民**处以**200元以下**、对**法人**或者**其他组织**处以**3000元以下**罚款或者**警告**的行政处罚的，可以**当场作出行政处罚决定。法律**另有规定的，从其规定。

2.行政处罚决定书

（1）执法人员**当场作出行政处罚决定**的，应当向当事人**出示执法证件**，填写**预定格式、编有号码**的行政处罚决定书，并**当场交付**当事人。当事人拒绝签收的，应当在行政处罚决定书上注明。

（2）行政处罚决定书，应当载明当事人的违法行为，行政处罚的种类和依据、罚款数额、时间、地点，申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限以及行政机关名称，并由**执法人员签名或者盖章**。

（3）执法人员当场作出的行政处罚决定，应当报所属行政机关**备案。**

（三）普通程序

1.立案。**2年**以内未发现的，一般不予立案追究。

2.调查。

（1）调查人员**不得少于2人**，并应**主动出示证件**。

（2）当事人或有关人员**有权要求**执法人员出示执法证件，执法人员**不出示**的，当事人或有关人员**有权拒绝**接受调查或者检查。

（3）当事人或有关人员**应如实回答**询问，并**协助调查**或检查，不得拒绝或阻挠。

（4）询问或者检查应当制作笔录。

3.审查。

（1）调查终结后，调查人员写出调查报告，提出进行处罚的事实依据和处罚建议。

（2）有下列情形之一，在行政机关负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

①涉及**重大公共利益**的。

②**直接**关系**当事人**或**第三人重大权益，经过听证程序**的。

③案件情况**疑难复杂**、涉及**多个法律关系**的。

④法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形。

（3）审查机构根据不同的违法情况，分别作出予以**行政处罚、不予行政处罚，**或者**移送司法机关**处理等处理建议

4.告知和说明理由。行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的权利。

5.听取当事人陈述和申辩意见。

（1）行政处罚决定之前，如**拒绝听取**当事人的陈述与申辩，该**处罚决定不成立**，当事人放弃的除外。

（2）行政机关不得因当事人陈述、申辩而加重处罚。

6.制作处罚决定书。

行政机关应当自立案之日起**90 日内**作出行政处罚决定。法律、法规规章另有规定的，从其规定。

7.送达行政处罚决定书。

（1）行政处罚决定书应当在**宣告后当场交付**当事人；

（2）当事人**不在场**的，行政机关应当在**7 日内**依照《民事诉讼法》的有关规定送达当事人；

（3）当事人**同意并签订确认书**的，行政机关**可以采用传真、电子邮件等方式送达。**

（四）听证程序

	行政处罚	税务行政处罚
听证的范围	（1）**较大数额**罚款； （2）没收**较大数额**违法所得、没收**较大价值**非法财物； （3）**降低资质等级、吊销许可证件** （4）责令停产停业、**责令关闭、限制从业；** （5）其他较重的行政处罚； （6）法律、法规、规章规定的其他情形。	（1）罚款【公民 2000 元以上（含本数）、组织 10000 元以上（含本数）】； （2）没收较大数额违法所得 （3）吊销税务行政许可证件
提出	当事人要求听证的，应当在行政机关告知后**5 日**内提出	要求听证的当事人，应当在《税务行政处罚事项告知书》送达后 **5 日**内向税务机关**书面**提出听证；逾期不提出的，视为放弃听证权利

举行期限	未明确规定	税务机关应当在收到当事人听证要求后15日内举行听证
通知	行政机关应当在举行听证的**7日**前，通知当事人及有关人员听证的时间、地点	税务机关应当在举行听证的**7日**前将《税务行政处罚听证通知书》送达当事人，通知当事人及有关人员举行听证的时间、地点
费用	当事人**不承担**行政机关组织听证的费用	——
公开举行	除涉及**国家秘密、商业秘密或者个人隐私**依法予以保密外，听证公开举行	应当公开进行。但是涉及**国家秘密、商业秘密或者个人隐私**的，听证不公开进行
主持	听证由行政机关指定的**非本案调查人员**主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避	税务机关负责人指定的**非本案调查机构的人员**主持；当事人认为听证主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避
当事人	当事人可以亲自参加听证，也可以**委托1～2人**代理	
放弃听证权利	当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听证的，**视为放弃听证权利**，行政机关**终止**听证	当事人及其代理人应当按照税务机关的通知参加听证，无正当理由拒不出席听证或者中途退出听证的，**视为放弃**听证权利，税务机关依法终止听证
申辩和质证	举行听证时，调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议，当事人进行申辩和质证	听证过程中，由本案调查人员就当事人的违法行为予以指控，并出示事实证据材料，提出行政处罚建议。当事人或者其代理人可以就所指控的事实及相关问题进行申辩和质证
笔录	听证应当制作**笔录**；笔录应当交当事人或者其代理人核对无误后签字或者盖章。当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在笔录中注明	（1）听证的全部活动，应当由记录员写成笔录，经听证主持人审阅并由**听证主持人**和**记录员**签名后，封卷上交税务机关**负责人审阅** （2）听证笔录应交当事人或者其代理人、本案调查人员、证人及其他有关人员阅读或者向他们宣读，他们认为有遗漏或者有差错的，可以请求补充或者改正。他们在承认没有错误后，

		应当签字或者盖章。拒绝签字或者盖章的，记明情况附卷
作出决定	听证结束后，行政机关**应当根据听证笔录**，依照规定，**作出决定**	——

第五节 税务行政处罚

【高频考点】税务行政处罚的种类（★★★）

税务行政处罚	不属于行政处罚的情形
罚款 没收违法所得 停止办理出口退税 吊销税务行政许可证件	（1）税务机关作出的责令限期改正——行政命令 （2）税务机关作出的收缴或者停售发票——间接强制执行措施 （3）通知有关部门阻止出境、取消一般纳税人资格、收缴税务登记证、停止抵扣等

【高频考点】税务稽查案件办理程序（★★）【2023 年新增】

（一）办理税务稽查案件的基本原则

1.原则：办理税务稽查案件应当以事实为根据，以法律为准绳，坚持公平公正、公开、效率的原则。

2.稽查局办理税务稽查案件时，实行选案、检查、审理、执行分工制约原则。

3.税务稽查人员具有《税收征管法实施细则》规定回避情形的，应当回避。

4.税务稽查人员对实施税务稽查过程中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私、个人信息，应当依法予以保密。

5.税务稽查案件办理应当通过文字、音像等形式，对案件办理的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录。

（二）选案程序

1.稽查局应当加强稽查案源管理，全面收集整理案源信息，合理、准确地选择待查对象。待查对象确定后，经稽查局局长批准实施立案检查。必要时，依照法律法规的规定，稽查局可以在立案前进行检查。

2.稽查局应当统筹安排检查工作，严格控制对纳税人、扣缴义务人的检查次数。

（三）检查程序

1.检查程序的基本要求

检查前，稽查局应当告知被查对象检查时间、需要准备的资料等，但预先通知有碍检查的除外。检查应当由**两名以上**具有执法资格的检查人员共同实施，并向被查对象出示税务检查证件、出示或者送达税务检查通知书，告知其权利和义务。检查应当依照法定权限和程序，采取实地检查、调取账簿资料、询问、查询存款账户或者储蓄存款、异地协查等方法。

2.检查取证的具体要求

检查应当依照法定权限和程序收集证据材料。收集的证据必须经查证属实，并与证明事项相关联。

不得以下列方式收集、获取证据材料：①严重违反法定程序收集；②以违反法律强制性规定的手段获取且侵害他人合法权益；③以利诱、欺诈、胁迫、暴力等手段获取。

稽查局办理税务稽查案件时，**有权调取**被查对象账簿、记账凭证、报表和其他有关资料。

调取账簿资料时，应当向被查对象出具**调取账簿资料通知书**，并填写调取账簿资料清单交其核对后**签章确认**。

调取纳税人、扣缴义务人**以前会计年度**的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料的，应当经**县以上税务局局长批准**，并在**3个月内**完整退还；调取纳税人、扣缴义务人**当年**的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料的，应当经设区的市、自治州以上税务局局长批准，并在**30日内**退还。

稽查局采取询问方式检查取证时，应当由**两名以上**检查人员实施。

除在被查对象生产、经营、办公场所询问外，应当向被询问人送达询问**通知书**。

当事人、证人可以采取书面或者口头方式陈述或者提供证言。当事人、证人口头陈述或者提供证言的，检查人员应当以笔录、录音、录像等形式进行记录。

检查人员**实地调查取证**时，可以制作现场笔录、勘验笔录，对实地调查取证情况予以记录。制作现场笔录、勘验笔录，应当载明时间、地点和事件等内容，并由检查人员签名和当事人签章。当事人经通知不到场或者拒绝在现场笔录、勘验笔录上签章的，检查人员应当在笔录上注明原因；如有其他人员在场，可以由其签章证明。

检查人员**异地调查取证**的，当地税务机关应当予以协助；发函委托相关稽查局调查取证的，必要时可以派人参与受托地稽查局的调查取证，受托地稽查局应当根据协查请求，依照法定权限和程序调查。需要取得境外资料的，稽查局可以提请国际税收管理部门依照有关规定程序获取。

检查人员查询从事生产经营的纳税人、扣缴义务人**存款账户**，应当经**县以上税务局局长**批准，凭检查存款账户许可证明向相关银行或者其他金融机构查询。查询案件涉嫌人员**储蓄存款**的，应当经**设区的市、自治州以上税务局局长**批准，凭检查存款账户许可证明向相关银行或者其他金融机构查询。

税务机关有根据认为从事生产、经营的纳税人有逃避纳税义务行为，可以在规定的纳税期之前，责令限期缴纳应纳税款；在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品货物以及其他财产或者应纳税收入迹象的，可以责成纳税人**提供纳税担保**。如果纳税人不能提供纳税担保，经县以上税务局局长批准，可以依法采取税收强制措施。

稽查局采取税收强制措施时，应当向纳税人、扣缴义务人、纳税担保人交付税收强制措施决定书，告知其采取税收强制措施的内容、理由、依据以及依法享有的权利、救济途径，并履行法律、法规规定的其他程序。其中，采取冻结纳税人在开户银行或者其他金融机构的存款措施时，应当向纳税人开户银行或者其他金融机构交付冻结存款通知书，冻结其相当于应纳税款的存款；并于作出冻结决定之日起**3个工作日内**，向纳税人交付冻结决定书。

采取查封、扣押商品、货物或者其他财产措施时，应当向纳税人、扣缴义务人、纳税担保人当场交付查封、扣押决定书，填写查封商品、货物或者其他财产清单或者出具扣押商品、货物或者其他财产专用收据，由当事人核对后签章。

采取查封、扣押有产权证件的动产或者不动产措施时，应当依法向有关单位送达税务协助执行通知书，通

知其在查封、扣押期间不再办理该动产或者不动产的过户手续。

采取查封、扣押措施的，期限一般不得超过**6个月**；重大案件有下列情形之一，需要延长期限的，应当**报国家税务总局**批准：①案情复杂，在查封、扣押期限内确实难以查明案件事实的；②被查对象转移、隐匿、销毁账簿、记账凭证或者其他证据材料的；③被查对象拒不提供相关情况或者以其他方式拒绝、阻挠检查的；④解除查封、扣押措施可能使纳税人转移、隐匿、损毁或者违法处置财产，从而导致税款无法追缴的。

其他情形下采取查封、扣押、冻结措施的，期限不得超过**30日**；情况复杂的，经**县以上税务局局长**批准，可以延长，但是延长期限不得超过**30日**。

有下列情形之一的，应当依法及时解除税收强制措施：①纳税人已按履行期限缴纳税款、扣缴义务人已按履行期限解缴税款、纳税担保人已按履行期限缴纳所担保税款的；②税收强制措施被复议机关决定撤销的；③税收强制措施被人民法院判决撤销的；④其他法定应当解除税收强制措施的。

有下列情形之一，致使检查暂时无法进行的，经稽查局局长批准后，**中止**检查：①当事人被有关机关依法限制人身自由的；②账簿、记账凭证及有关资料被其他国家机关依法调取且尚未归还的；③与税收违法行为直接相关的事实需要人民法院或者其他国家机关确认的；④法律、行政法规或者国家税务总局规定的其他可以中止检查的。中止检查的情形消失，经**稽查局局长批准**后，恢复检查。

有下列情形之一，致使检查确实无法进行的，经稽查局局长批准后，**终结**检查：①被查对象死亡或者被依法宣告死亡或者依法注销，且有证据表明无财产可抵缴税款或者无法定税收义务承担主体的；②被查对象税收违法行为均已超过法定追究期限的；③法律、行政法规或者国家税务总局规定的其他可以终结检查的。

在检查过程中，被查对象有下列情形之一的，依照《税收征管法》及其实施细则有关逃避拒绝或者以其他方式**阻挠税务检查**的规定处理：①提供虚假资料，不如实反映情况，或者拒绝提供有关资料的；②拒绝或者阻止税务机关记录、录音、录像、照相和复制与案件有关的情况和资料的；③在检查期间转移、隐匿、销毁有关资料的；④有不依法接受税务检查的其他情形的。

（四）审理程序

检查结束后，**稽查局**应当对案件进行**审理**。符合重大税务案件标准的，稽查局审理后提请税务局重大税务案件审理委员会审理。

案件审理应当**着重审核**以下内容：①执法主体是否正确；②被查对象是否准确；③税收违法事实是否清楚，证据是否充分，数据是否准确，资料是否齐全；④适用法律、行政法规、规章及其他规范性文件是否适当，定性是否正确；⑤是否符合法定程序；⑥是否超越或者滥用职权；⑦税务处理、处罚建议是否适当；⑧其他应当审核确认的事项或者问题。

稽查局区分下列情形分别作出处理：

①有税收违法行为，应当作出税务处理决定的，制作**税务处理决定书**；

②有税收违法行为，应当作出税务行政处罚决定的，制作**税务行政处罚决定书**；

③税收违法行为轻微，依法可以不予税务行政处罚的，制作不予税务行政处罚决定书；

④没有税收违法行为的，制作税务稽查结论。

稽查局办理税务稽查案件，有严格的期限规定。稽查局应当自立案之日起**90日内**作出行政处理、处罚决定

或者无税收违法行为结论。

案情复杂需要延期的，经**税务局局长批准**，可以延长不超过**90日**；特殊情况或者发生不可抗力需要继续延期的，应当经上一级分管副局长批准，并确定合理的延长期限。但下列时间不计算在内：①中止检查的时间；②请示上级机关或者征求有权机关意见的时间；③提请重大税务案件审理的时间；④因其他方式无法送达，公告送达文书的时间；⑤组织听证的时间；⑥纳税人、扣缴义务人超期提供资料的时间；⑦移送司法机关后，税务机关需根据司法文书决定是否处罚的案件，从司法机关接受移送到司法文书生效的时间。

税收违法行为涉嫌犯罪的，填制**涉嫌犯罪案件移送书**，经税务局局长批准后，稽查局依法移送公安机关，并附送以下资料：①涉嫌犯罪案件情况的调查报告；②涉嫌犯罪的主要证据材料复制件；③其他有关涉嫌犯罪的材料。

（五）执行程序

稽查局应当依法及时送达税务处理决定书、税务行政处罚决定书、不予税务行政处罚决定书、税务稽查结论等税务文书。

在执行阶段，当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，可向稽查局提出申请，经**税务局局长批准**后，可以**暂缓**或者**分期**缴纳。

具有下列情形之一的，经县以上税务局局长批准，稽查局可以依法强制执行，或者依法申请人民法院强制执行：

①纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳或者解缴税款、滞纳金，责令限期缴纳逾期仍未缴纳的；

②经稽查局确认的纳税担保人未按照规定的期限缴纳所担保的税款、滞纳金，责令限期缴纳逾期仍未缴纳的；

③当事人对处罚决定逾期不申请行政复议也不向人民法院起诉、又不履行的：

④其他可以依法强制执行的。

实施强制执行时应当向被执行人送达强制执行决定书，告知其实施强制执行的内容、理由及依据，并告知其享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

催告期间，对有证据证明有转移或者隐匿财物迹象的，可以作出立即强制执行决定。稽查局采取从被执行人开户银行或者其他金融机构的存款中扣缴税款、滞纳金、罚款措施时，应当向被执行人开户银行或者其他金融机构送达扣缴税收款项通知书，依法扣缴税款、滞纳金、罚款、并及时将有关凭证送达被执行人。拍卖、变卖被执行人商品、货物或者其他财产，以拍卖、变卖所得抵缴税款、滞纳金、罚款的，在拍卖、变卖前应当依法进行查封、扣押。

执行过程中发现有下列情形之一的，经稽查局局长批准后，**中止**执行：

①当事人死亡或者被依法宣告死亡，尚未确定可执行财产的；

②当事人进入破产清算程序尚未终结的；

③可执行财产被司法机关或者其他国家机关依法查封、扣押、冻结，致使执行暂时无法进行的；

④可供执行的标的物需要人民法院或者仲裁机构确定权属的；

⑤法律、行政法规和国家税务总局规定其他可以中止执行的。

中止执行情形消失后，经稽查局局长批准，**恢复执行**。当事人确无财产可供抵缴税款、滞纳金、罚款或者依照破产清算程序确实无法清缴税款、滞纳金、罚款，或者有其他法定终结执行情形的，经税务局局长批准后，**终结**执行。

税务处理决定书、税务行政处罚决定书等决定性文书送达后，有下列情形之一的，稽查局可以依法重新作出：

①决定性文书被人民法院判决撤销的；

②决定性文书被行政复议机关决定撤销的；

③税务机关认为需要变更或者撤销原决定性文书的；

④其他依法需要变更或者撤销原决定性文书的。

第四章 行政强制法律制度

第一节 行政强制概述

【高频考点】行政强制法的基本原则（★★★）

（一）行政强制合法性原则

1.按照法定的权限、范围、条件和程序设定行政强制

2.按照法定的权限、范围、条件和程序实施行政强制

（二）行政强制适当原则

1.行政强制的设定，应当适当。

2.行政强制的实施，应当适当。

（1）情节轻微的，能不实施就不实施（优先使用非强制手段）。

（2）查封、扣押、冻结的财物价值应当适当。

（3）行政机关依法强制执行时所选择的强制手段应当适当。

首先应当优先使用间接强制手段，包括代履行和执行罚；在代履行和执行罚无法实现行政目的时，才适用直接强制执行。

（4）多种强制手段都可以实现行政目的，应当选择对当事人损害最小的方式，即符合比例原则的要求。

（三）教育与强制相结合原则

1.违法情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。

2.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出。经催告，当事人履行行政决定的，不再实施强制执行。

3.行政机关在申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。

（四）禁止利用行政强制权谋取利益原则

1.不得使用被查封、扣押的财产

2.不得收取保管费

3.收支两条线

4.合理确定代履行费用

（五）保障当事人程序权利和法律救济权利原则

1.公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政强制，享有陈述权、申辩权；

2.有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；因行政机关违法实施行政强制受到损害的，有权依法要求赔偿行政强制的基本原则。

【高频考点】行政强制的设定（★★）

	行政强制措施					行政强制执行
	扣押财物	查封场所、设施或者财物	限制公民人身自由	冻结存款、汇款	其他	
法律	√	√	√	√	√	√
行政法规	√	√	×	×	√	×
地方性法规	√	√	×	×	×	×
地方政府规章	×	×	×	×	×	×
部门规章	×	×	×	×	×	×

第二节 行政强制措施的实施

【高频考点】行政强制措施实施的一般规定（★★★）

1.违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，行政机关可以不采取行政强制措施。

2.实施主体

（1）法律、法规规定的行政机关；

（2）法律、行政法规授权的具有管理公共事务职能的组织；

（3）行政强制实施不得委托。

3.行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定

（1）实施前须向行政机关负责人报告并经批准；情况紧急的，在24小时内向负责人报告，并补办批准手续。负责人认为不应当采取行政强制措施的，应当立即解除。

（2）由2名以上行政执法人员实施；

（3）出示执法身份证件；

（4）通知当事人到场；

（5）当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径；

（6）听取当事人的陈述和申辩；

（7）制作现场笔录；

（8）现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明；

（9）当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章；

（10）法律、法规规定的其他程序。

4.实施限制公民人身自由的行政强制措施的特殊规定

（1）当场告知或者实施行政强制措施后立即通知当事人家属实施的行政机关、地点和期限；

（2）在紧急情况下当场实施行政强制措施的，在返回行政机关后，立即向行政机关负责人报告并补办批准手续；

（3）法律规定的其他程序；

（4）实施限制人身自由的行政强制措施不得超过法定期限。对于实施行政强制措施的目的已经达到或者条件已经消失的情况，行政机关应当立即解除行政强制措施。

【高频考点】查封、扣押（★★★）

主体	由法律、法规规定的行政机关实施，其他任何行政机关或者组织不得实施
范围	（1）查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物，**不得**查封、扣押与违法行为**无关的**场所、设施或者财物； （2）**不得**查封、扣押公民个人及其所扶养家属的**生活必需品；** （3）当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，**不得重复查封**（三不得）
程序	（1）应当依据实施行政强制措施的法定程序进行，制作并**当场交付**查封、扣押**决定书**和**清单；** （2）查封、扣押清单**一式二份，**由当事人和行政机关分别保存
时限	（1）查封、扣押的期限不得超过 30 日；经批准延长的，延长期限不得超过 30 日。法律、行政法规另有规定的除外。 （2）查封、扣押的期限不包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间。 【提示 1】依照《税收征管法》第 55 条规定，税务机关采取税收保全措施的期限一般不得超过 6 个月；重大案件需要延长的，应当报国家税务总局批准。 【提示 2】检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。 【提示 3】检验、检测、检疫或技术鉴定的期间应当明确，并书面告知当事人。
保管	（1）对查封、扣押的财产，行政机关应妥善保管，**不得使用**或者损毁；未尽妥善保管义务造成损失的，应当承担赔偿责任。 （2）对查封的场所、设施或者财物，行政机关**可以委托第三人保管。** 【提示 1】因查封、扣押发生的**保管费用由行政机关承担。**

	【提示 2】对查封的场所、设施或财物，行政机关可以委托第三人保管（扣押不可以委托第三人保管）
解除	有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定： （1）当事人没有违法行为； （2）查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关； （3）行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押； （4）查封、扣押期限已经届满； （5）其他不再需要采取查封、扣押措施的情形。 解除查封、扣押应当立即退还财物；已将鲜活物品或者其他不易保管的财物拍卖或者变卖的，退还拍卖或者变卖所得款项。变卖价格明显低于市场价格，给当事人造成损失的，应当给予补偿

【高频考点】冻结（★★★）

1.冻结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施，不得委托给其他行政机关或者组织；其他任何行政机关或者组织不得冻结存款、汇款。

冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。

2.行政机关依照法律规定决定实施冻结存款、汇款的，应当履行规定的程序，并向金融机构交付冻结通知书。

金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当立即予以冻结，不得拖延，不得在冻结前向当事人泄露信息。

法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝。

3.依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在 3 日内向当事人交付冻结决定书。冻结决定书应当载明下列事项：

（1）当事人的姓名或者名称、地址；

（2）冻结的理由、依据和期限；

（3）冻结的账号和数额；

（4）申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

（5）行政机关的名称、印章和日期。

4.自冻结存款、汇款之日起 30 日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日。法律另有规定的除外。（30+30）

5.有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除冻结决定：

（1）当事人没有违法行为；

（2）冻结的存款、汇款与违法行为无关；

（3）行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要冻结；

（4）冻结期限已经届满；

（5）其他不再需要采取冻结措施的情形。

行政机关作出解除冻结决定的，应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后，应当立即解除冻结。

6.行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结。

第三节 行政强制执行的实施

【高频考点】行政强制执行的实施的一般规定（★★★）

行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关依照《行政强制法》的规定强制执行。

法规授权的具有管理公共事务职能的组织在法定授权范围内，以自己的名义实施行政强制执行，适用《行政强制法》有关行政机关的规定。

1.一般规定

（1）催告

行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：

①履行义务的期限；

②履行义务的方式；

③涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；

④当事人依法享有的陈述权和申辩权。

（2）陈述、申辩

当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。行政机关应当充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录、复核。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。

（3）强制执行决定

①经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出强制执行决定。

②在催告期间，对有证据证明有转移或者隐匿财物迹象的，行政机关可以作出立即强制执行决定。

【注意】强制执行应载明：当事人的姓名或者名称、决定书地址；强制执行的理由和依据；强制执行的方式和时间；申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；行政机关的名称、印章和日期。

（4）送达

催告书、行政强制执行决定书应当直接送达当事人。当事人拒绝接收或者无法直接送达当事人的，应当依照《民事诉讼法》的有关规定送达。

（5）执行协议

①实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议：

执行协议可以约定分阶段履行；当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金（罚款本金、税款本金、行政性收费本金不适用执行和解的减免规定）。

②当事人不履行执行协议的，行政机关应当恢复强制执行。

（6）行政强制执行的限制

行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。（对企业可以）

（7）强拆

对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的，应当由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的，行政机关可以依法强制拆除。

2.执行中止

有下列情形之一的，中止执行：

（1）当事人履行行政决定确有困难或者暂无履行能力的；

（2）第三人对执行标的主张权利，确有理由的；

（3）执行可能造成难以弥补的损失，且中止执行不损害公共利益的；

（4）行政机关认为需要中止执行的其他情形。

中止执行的情形消失后，行政机关应当恢复执行。对没有明显社会危害，当事人确无能力履行，中止执行满 3 年未恢复执行的，行政机关不再执行。

3.终结执行

有下列情形之一的，终结执行：

（1）公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承受人的；

（2）法人或者其他组织终止，无财产可供执行，又无义务承受人的；

（3）执行标的灭失的；

（4）据以执行的行政决定被撤销的；

（5）行政机关认为需要终结执行的其他情形。

第五章 行政复议法律制度

第一节 行政许可法基础

【高频考点】行政复议的基本原则（★★★）

合法原则	履行行政复议职责的主体、审理复议案件的依据以及审理复议案件的程序应当合法
公正原则	行政复议机关应当从合法性和适当性（也可称为“合理性”）两方面审

	查被申请的具体行政行为；行政复议机关应当正当、合理地行使复议裁量权。
公开原则	（1）过程公开； （2）依据公开； （3）复议的结果和决定的理由公开。
高效原则	（1）受理复议申请应当及时； （2）案件审理要严格遵守审理期限的规定； （3）作出行政复议决定应当及时； （4）对复议当事人不履行复议决定的情况，复议机关应当及时处理。
便民、为民原则	尽可能为行政复议申请人提供必要的便利，从而确保公民、法人或其他组织充分行使复议救济权。
禁止不利变更原则	在申请人的行政复议请求范围内，不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。即不得增加处罚种类或加重对申请人的处罚。

第二节 行政复议受案范围

【高频考点】行政复议受案范围（★★）

（1）对行政机关作出的**行政处罚**决定不服的。

（2）对行政机关作出的**行政强制措施、行政强制执行**决定不服的。

（3）**申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复**，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的。

（4）对行政机关作出的关于**确认自然资源的所有权或者使用权**的决定不服的。

（5）对行政机关作出的**征收征用决定及其补偿**决定不服的

（6）对行政机关作出的**赔偿决定或者不予赔偿**决定不服。

（7）对行政机关作出的**不予受理工伤认定申请的决定或者工伤认定结论**不服的。

（8）认为行政机**关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权**的。

（9）认为行政机关**滥用行政权力排除或者限制竞争**的。

（10）认为行政机关**违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务**的。

（11）申请行政机关**履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复**的。

（12）申请行政机关依法**给付抚恤金、社会保险待遇或者最低生活保障等社会保障，行政机关没有依法给付**的。

（13）认为行政机关**不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议**的。

公开工作中侵犯其合法权益的。

（15）认为行政机关的其他行政行为侵犯其合法权益的。

第三节 行政复议参加人

【高频考点】行政复议申请人（★★★）

1.只能是公民、法人或其他组织，包括外国人、无国籍人。

包括：相对人+利害关系人

2.必须是认为具体行政行为侵害其合法权益的人。

3.申请人资格的转移

（1）公民死亡的，其近亲属可以申请行政复议；

（2）法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织可以申请行政复议；

【注意】有权申请行政复议的公民为无民事行为能力或者限制民事行为能力人的，其法定代理人可以代为申请行政复议。——仅为代理，不是资格转移

4.复议申请人及复议代表人

组织名称		申请人（即以谁的名义）	具体实施人
合伙	合伙企业	核准登记的企业	执行合伙事务的合伙人
	其他合伙组织	该合伙	合伙人共同申请
不具备法人资格的其他组织		该组织	主要负责人，没有的，由共同推选的其他成员代表该组织参加
股份制企业		该企业	股东大会、股东代表大会、董事会
【注意】同一行政复议案件申请人超过5人的，推选1至5名代表参加行政复议。			

5.税务行政复议申请人

税务行政复议申请人是纳税人、扣缴义务人、纳税担保人以及其他税务当事人。

【高频考点】行政复议被申请人（★★★）

行政复议被申请人，是指作出被申请复议的具体行政行为的行政主体，包括行政机关和法律、法规授权的组织。

1.公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服，依法申请行政复议的，作出该具体行政行为的行政机关为被申请人。

2.两个或者两个以上行政机关以共同名义作出具体行政行为的，共同作出具体行政行为的行政机关为共同被申请人。

3.公民、法人或者其他组织对法律、法规授权的组织作出的具体行政行为不服，依法申请行政复议的，该

组织为被申请人。

4.行政机关与法律、法规授权的组织以共同的名义作出具体行政行为的，行政机关和法律、法规授权的组织为共同被申请人。行政机关与其他组织以共同名义作出具体行政行为的，行政机关为被申请人。

5.行政机关委托的组织作出具体行政行为的，委托的行政机关为被申请人。

6.作出具体行政行为的行政机关被撤销的，继续行使其职权的行政机关为被申请人。

7.下级行政机关依照法律、法规、规章规定，经上级行政机关批准作出具体行政行为的，批准机关为被申请人。

8.对县级以上地方人民政府依法设立的派出机关的具体行政行为不服申请行政复议的，该派出机关为被申请人。

9.对政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规或者规章规定，以自己的名义作出的具体行政行为不服申请行政复议的，该派出机构为被申请人。

10.行政机关设立的派出机构、内设机构或者其他组织，未经法律、法规授权，对外以自己名义作出具体行政行为的，该行政机关为被申请人。

第五节 行政复议程序

【高频考点】行政复议申请（★★★）

（一）申请复议的条件

1.申请人合格。申请人明确且与具体行政行为有利害关系是申请人合格的基本条件（相对人或利害关系人）。

2.有符合规定的被申请人。

3.有具体的复议请求和理由。

4.属于复议范围和受理复议机关管辖。

5.在法定申请期限内申请复议（原则上60日）。

6.法律、法规规定的其他条件。

（二）申请复议的期限

1.一般复议期限

（1）根据《行政复议法》规定，公民、法人或其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以**自知道**该具体行政行为之日起**60日内**提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限**超过60日**的除外。因**不可抗力**或者**其他正当理由**耽误法定申请期限的，申请期限**自障碍消除之日起继续**计算。

（2）公民、法人或者其他组织不服具体行政行为，在法定复议期限内向人民法院直接提起行政诉讼，人民法院依法裁判应当先申请行政复议、对复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼，公民、法人或者其他组织申请行政复议时已经超过法定行政复议申请期限的，行政复议机关可以根据《行政复议法》第20条第2款规定处理，即**公民、法人或者其他组织提起行政诉讼到人民法院生效裁判送达之日的时间，不计入法定行政复议申请期限**。

（3）由于**作出具体行政行为的行政机关没有**向申请人**依法告知**行政复议权利、行政复议机关名称或者申请

复议期限，致使申请人在法定期限内向无权受理的行政机关提出行政复议申请，接到行政复议申请的机关又没有及时将该案移送，申请人申请行政复议期限因此被耽误的，属于《行政复议法》第20条规定的“其他正当理由”情形。

根据《行政复议法实施条例》规定，该一般申请期限的具体计算方法：

（1）**当场作出**具体行政行为的，自具体行政行为**作出之日**起计算。

（2）载明具体行政行为的法律文书**直接送达**的，自受送达**人签收之日**起计算。

（3）载明具体行政行为的法律文书**邮寄送达**的，自受送达人**在邮件签收单上签收之日**起计算；没有邮件签收单的，**自受送达人在送达回执上签名之日**起计算。

（4）具体行政行为依法通过**公告**形式告知受送达人的，自**公告规定的期限届满之日**起计算。

（5）行政机关作出具体行政行为时未告知公民、法人或者其他组织，事后补充告知的，自该公民、法人或者其他组织**收到行政机关补充告知的通知之日**起计算。

（6）被申请人能够证明公民、法人或者其他组织知道具体行政行为的，自**证据材料证明其知道具体行政行为之日**起计算。

行政机关作出具体行政行为，依法应当向有关公民、法人或者其他组织送达法律文书而未送达的，视为该公民、法人或者其他组织不知道该具体行政行为。

公民、法人或者其他组织依照《行政复议法》规定申请行政机关履行法定职责，行政机关未履行的，行政复议申请期限依照下列规定计算：

①有履行期限规定的，自履行期限届满之日起计算；

②没有履行期限规定的，自行政机关收到申请满60日起计算。

公民、法人或者其他组织在紧急情况下请求行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关不履行的，行政复议申请期限不受前述规定的限制。

2.特殊复议期限

特殊复议期限**只有法律规定超过60日的才有效**。如《专利法》规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以在收到通知之日起3个月内向国务院专利行政部门请求复审。

（三）行政复议申请方式

1.**书面**申请复议

可以采取**当面递交、邮寄或者传真**等方式提出复议申请。有条件的行政复议机构可以接受以**电子邮件形式**提出的行政复议申请。

2.**口头**申请复议

申请人口头申请复议的，行政复议机构应当依照规定当场制作行政复议申请笔录交申请人核对或者向申请人宣读，并由申请人签字确认。

（四）受理

1.审查与受理

行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查：

（1）对不符合规定的行政复议申请，决定不予受理，并书面告知申请人。

（2）对符合规定，但是不属于本机关受理的行政复议申请，应当告知申请人向有关行政复议机关提出。

（3）对符合法定条件的行政复议申请，行政复议申请自行政复议机关负责法制工作的机构收到之日起即为受理。

公民、法人或者其他组织依法提出行政复议申请，行政复议机关无正当理由不予受理的，上级行政机关应当责令其受理；必要时，上级行政机关也可以直接受理。

【注意】行政复议期间（包括税务行政复议期间）有关“5日”“7日”的规定是指工作日，不含节假日。

2.行政复议申请符合下列规定的，应当予以受理：

（1）有明确的申请人和符合规定的被申请人 ；

（2）申请人与具体行政行为有利害关系 ；

（3）有具体的行政复议请求和理由；

（4）在法定申请期限内提出；

（5）属于行政复议法规定的行政复议范围；

（6）属于收到行政复议申请的行政复议机构的职责范围 ；

（7）其他行政复议机关尚未受理同一行政复议申请，人民法院尚未受理同一主体就同一事实提起的行政诉讼。

3.告知补正

行政复议申请材料不齐全或者表述不清楚的，行政复议机构可以自收到该行政复议申请之日起5日内书面通知申请人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。无正当理由逾期不补正的,视为申请人放弃行政复议申请。补正申请材料所用时间不计入行政复议审理期限。

【高频考点】行政复议审理（★★★）

行政复议的审理，是行政复议机关对受理的行政争议案件进行**合法性**和**适当性**审查，并最终作出复议决定的过程，是行政复议程序的核心。

（一）审理内容

1.既审查具体行政行为的合法性，也审查适当性。

2.包括对事实根据（证据）、主体、权限、依据、程序以及适当性的审查。

（二）审理期限

1.行政复议机关受理复议申请的，应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定；**但是法律规定的行政复议期限少于60日的除外**。

2.情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机关的负责人批准可以适当延长，并告知申请人和被申请人；**但延长期限最多不超过30日**。

3.补正申请材料所用时间、协商确定或者指定受理机关所用时间、行政复议期间专门事项鉴定所用时间以及现场勘验所用时间均不计入审理期限。

（三）审理依据

以**法律、法规、规章**以及有关行政机关依法制定和发布的具有**普遍约束力的决定、命令**为依据。

（四）审理方式

1.行政复议机构审理行政复议案件，应当由**2名**以上行政复议人员参加。

2.行政复议**原则上采取书面**审查的办法，但是**申请人提出**要求或者**行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要**时，可以向有关组织和人员调查情况，听取申请人、被申请人和第三人的意见。

3.行政复议机构**认为必要时，可以实地调查**核实证据；对**重大、复杂**的案件，申请人提出要求或者行政复议机构认为必要时，**可以采取听证**的方式审理。

4.行政复议人员向有关组织和人员调查取证时，可以**查阅、复制、调取有关文件和资料，向有关人员询问**。调查取证时，行政复议人员**不得少于2人**，并应当向当事人或有关人员**出示证件**。

（五）审理中的其他有关问题

1.复议申请的撤回

（1）申请人在行政复议决定作出前自愿撤回行政复议申请的，经行政复议机构同意，可以撤回。

（2）申请人撤回行政复议申请的，不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意思表示的除外。

2.复议期间具体行政行为的效力

（1）行政复议期间被申请人改变原具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理。但是，申请人依法撤回行政复议申请的除外。

（2）**行政复议期间具体行政行为不停止执行**；但是，有下列情形**之一**的，**可以停止执行**：

①被申请人认为需要停止执行的；

②行政复议机关认为需要停止执行的；

③申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；

④法律、法规、规章规定停止执行的。

3.被申请人证据收集的限制

在行政复议过程中，被申请人不得自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据。

4.行政复议人员在审理过程中的权利和义务

根据规定，行政复议人员向有关组织和人员调查取证时，可以查阅、复制、调取有关文件和资料，向有关人员询问。调查取证时，行政复议人员**不得少于2人**，并应当向当事人或有关人员出示证件。被调查单位和人员应当配合行政复议人员的工作，不得拒绝和阻挠。

【高频考点】行政复议决定及其执行（★★★）

（一）行政复议决定的种类

决定种类	理由
维持决定	事实清楚、证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当

履行决定	认定被申请人没有履行法定职责的（且继续履行职责确有必要的），应当决定其在一定期限内履行法定职责
撤销、变更或确认违法决定	①事实不清，证据不足的； ②适用依据错误的； ③违反法定程序的； ④超越或者滥用职权的； ⑤具体行政行为明显不当的。
责令被申请人赔偿的决定	①在申请复议时一并提出赔偿请求的。 ②申请复议时没有提出行政赔偿请求的： 撤销或者变更罚款，撤销违法集资、没收财物、征收财物、摊派费用（以及撤销或者变更税务机关确定的税款、滞纳金）以及对财产的查封、扣押、冻结等具体行政行为时，应当同时责令被申请人返还财产，解除对财产的查封、扣押、冻结措施或者赔偿相应的价款。 【注意】返还执行的罚款或罚金、追缴或者没收的金钱、解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息。
驳回决定	①申请人认为行政机关不履行法定职责，复议机关受理后发现该行政机关没有相应法定职责或者在受理前已经履行法定职责的； ②受理后，发现该复议申请不符合受理条件的。

（二）行政复议决定的执行

1.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。

2.被申请人

被申请人应当履行行政复议决定。被申请人不履行或者无正当理由拖延履行行政复议决定的，行政复议机关或者有关上级行政机关应当责令其限期履行。

3.申请人

申请人逾期不起诉又不履行行政复议决定的，或者不履行最终裁决的行政复议决定的，按照下列规定分别处理：

（1）维持具体行政行为的行政复议决定，由作出具体行政行为的行政机关依法强制执行，或者申请人民法院强制执行；

（2）变更具体行政行为的行政复议决定，由行政复议机关依法强制执行，或者申请人民法院强制执行。

第六节 税务行政复议

【高频考点】税务行政复议范围（★★★）

1.可以单独提出复议申请的事项

（1）**征税行为**，包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计

税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为，征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。

（2）行政许可、行政审批行为。

（3）发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等。

（4）税收保全措施、强制执行措施。

（5）行政处罚行为

①罚款；

②没收财物和违法所得；

③停止出口退税权。

（6）不依法履行下列职责的行为

①颁发税务登记；

②开具、出具完税凭证、外出经营活动税收管理证明；

③行政赔偿；

④行政奖励；

⑤其他不依法履行职责的行为。

（7）资格认定行为。

（8）不依法确认纳税担保行为。

（9）政府信息公开工作中的具体行政行为。

（10）纳税信用等级评定行为。

（11）通知出入境管理机关阻止出境行为。

（12）其他具体行政行为。

2.可以一并提出复议审查申请的事项

申请人认为税务机关的具体行政行为所依据的下列规定不合法，对具体行政行为申请行政复议时，可以**一并**向行政复议机关提出对有关规定的审查申请；申请人对具体行政行为提出行政复议申请时**不知道**该具体行政行为所依据的规定的，**可以在行政复议机关作出行政复议决定以前**提出对该规定的审查申请：

（1）国家税务总局和国务院其他部门的规范性文件。

（2）其他各级税务机关的规范性文件。

（3）地方各级人民政府的规范性文件。

（4）地方人民政府工作部门的规范性文件。

【注意】这里的“规范性文件”不包括税务部门规章和其他规章。

【链接】一般行政复议可以审查的“规范性文件”是指**国务院有关部门的规定、县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定**以及**乡、镇人民政府的**规范性文件等。

【高频考点】税务行政复议申请人和被申请人（★★★）

（一）税务行政复议申请人

1.税务行政复议申请人是**纳税人、扣缴义务人、纳税担保人以及其他税务当事人**。

2.特殊情况

（1）有权申请行政复议的**公民死亡**的，其**近亲属**可以申请行政复议；

（2)有权申请行政复议的**公民为无行为能力人或者限制行为能力人**，其**法定代理人**可以代理申请行政复议；

（3）有权申请行政复议的**法人或者其他组织发生合并、分立或终止的，承受其权利义务**的法人或者其他组织可以申请行政复议。

3.虽非具体行政行为的行政管理相对人，但其**权利直接被该具体行政行为所剥夺、限制或者被赋予义务的公民、法人或其他组织**，在行政管理相对人没有申请行政复议时，**可以单独申请**行政复议。

4.**同一**行政复议案件申请人**超过 5 人**的，应当推选 **1~5 名**代表参加行政复议。

（二）税务行政复议被申请人

序号	情形	被申请人
（1）	对具体行政行为不服	作出具体行政行为的税务机关
（2）	对扣缴义务人的扣缴税款行为不服	主管该扣缴义务人的税务机关
（3）	对税务机关委托的单位和个人的代征行为不服	委托税务机关
（4）	税务机关与法律、法规授权组织以共同的名义作出具体行政行为	税务机关和被授权组织为共同被申请人
（5）	税务机关与其他组织以共同名义作出具体行政行为	税务机关
（6）	税务机关经上级税务机关批准作出具体行政行为	批准机关
（7）	对经重大税务案件审理程序作出的决定不服	审理委员会所在税务机关
（8）	税务机关设立的派出机构、内设机构或者其他组织，未经法律、法规授权，以自己名义对外作出具体行政行为	税务机关

【高频考点】税务行政复议申请和受理（★★★）

（一）税务行政复议申请

1.期限条件

申请人可以在知道税务机关作出具体行政行为之日起 **60 日内**提出税务行政复议申请。因不可抗力或者被申请人设置障碍等原因耽误法定申请期限的，申请期限的计算应当扣除被耽误时间。

2.其他程序要求

（1）申请人对《税务行政复议规则》第 14 条第 1 项规定的行为不服的，应当先向行政复议机关先申请行

政复议；对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼。

征税行为：确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为，征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。

（2）申请人按照前述规定申请行政复议的，必须依照税务机关根据法律、法规确定的税额、期限，先行缴纳或者解缴税款和滞纳金，或者提供相应的担保，才可以在缴清税款和滞纳金以后或者所提供的担保得到作出具体行政行为的税务机关确认之日起 60 日内提出行政复议申请。

（3）申请人提供担保的方式包括**保证、抵押和质押**。

（4）申请人对《税务行政复议规则》第 14 条第 1 项规定以外的其他具体行政行为不服，可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，应当**先缴纳罚款和加处罚款**，再申请行政复议。

3.形式

（1）申请人**书面**申请税务行政复议的，**可以采取当面递交、邮寄或者传真等方式提出行政复议申请**。有条件的行政复议机关可以接受以电子邮件形式提出的行政复议申请。对以传真、电子邮件形式提出行政复议申请的，行政复议机关应当审核确认申请人的身份、复议事项。

（2）申请人**口头**申请行政复议的，行政复议机构应当当场制作行政复议申请笔录，交申请人核对或者向申请人宣读，并由申请人确认。

（3）申请人提出行政复议申请时错列被申请人的，税务行政复议机关应当告知申请人变更被申请人。申请人不变更被申请人的，税务行政复议机关不予受理，或者驳回行政复议申请。

（二）税务行政复议受理

1.行政复议机关收到行政复议申请以后，应当在 5 日内审查，决定是否受理。对不符合规定的行政复议申请，决定不予受理，并书面告知申请人。

2.行政复议申请符合下列规定的，行政复议机关应当受理：

（1）属于规定的行政复议范围。

（2）在法定申请期限内提出。

（3）有明确的申请人和符合规定的被申请人。

（4）申请人与具体行政行为有利害关系。

（5）有具体的行政复议请求和理由。

（6）符合《税务行政复议规则》第 33、34 条规定的条件。

（7）属于收到行政复议申请的行政复议机关的职责范围。

（8）其他行政复议机关尚未受理同一行政复议申请，人民法院尚未受理同一主体就同一事实提起的行政诉讼。

3.上级税务机关认为行政复议机关不予受理行政复议申请的理由不成立的，可以督促其受理；经督促仍然不受理的，责令其限期受理。

4.上级税务机关认为行政复议申请不符合法定受理条件的，应当告知申请人。

上级税务机关认为有必要的，可以直接受理或者提审由下级税务机关管辖的行政复议案件。

【高频考点】税务行政复议审理和决定（★★★）

1.税务行政复议机关应当对被申请人作出的税务具体行政行为所依据的事实证据、法律程序、法律依据及设定的权利义务内容之合法性、适当性进行全面审查。

2.税务行政复议审理依据：税收法律、税收法规、税收规章和合法有效的其他税收规范性文件。

3.税务行政复议机构审理行政复议案件，应当由2名以上行政复议工作人员参加。

4.税务行政复议原则上采用书面审查的办法，但是申请人提出要求或者行政复议机构认为有必要时，应当听取申请人、被申请人和第三人的意见，并可以向有关组织和人员调查了解情况。

5.对重大、复杂的案件，申请人提出要求或者行政复议机构认为必要时，可以采取听证的方式审理。

6.听证

（1）行政复议机构决定举行听证的，应当将举行听证的时间、地点和具体要求等事项通知申请人、被申请人和第三人。

（2）第三人不参加听证的，不影响听证的举行。

（3）听证应当公开举行，但是涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。

（4）行政复议听证人员不得少于2人，听证主持人由行政复议机构指定。

（5）听证应当制作笔录。申请人、被申请人和第三人应当确认听证笔录内容。

（6）行政复议听证笔录应当附卷，作为行政复议机构审理案件的依据之一。

7.申请人在行政复议决定作出以前撤回行政复议申请的，经行政复议机构同意，可以撤回。

申请人撤回行政复议申请的，不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意思表示的除外。

8.行政复议期间被申请人改变原具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理。但是，申请人依法撤回行政复议申请的除外。

9.税务行政复议期限

行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机关负责人批准，可以适当延期，并告知申请人和被申请人；但是延期不得超过30日。（60+30）

行政复议审理期限在和解、调解期间中止计算。

第六章 行政诉讼法律制度

第一节 行政诉讼法基础

【高频考点】行政诉讼的基本原则（★★★）

1.被告对行政行为合法性负举证责任原则（倒置举证）

作为行政诉讼被告的主体，对**作出的行政行为**负有举证责任，应当提供作出该行政行为的**证据**和所**依据**的规范性文件。

2.诉讼期间行政行为**不停止**执行原则

被诉行政行为原则上不因原告提起诉讼而停止执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行：

（1）**被告认为**需要停止执行的；

（2）**原告**或者**利害关系人申请**停止执行，**人民法院认为**该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；

（3）**人民法院认为**该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；

（4）**法律、法规规定**停止执行的。

3.司法依法变更原则（司法变更有限原则）

通常情况下，人民法院不得变更原行政决定，但是在特殊的条件和情形下可以变更。

【注意 1】行政裁量权的问题，司法机关一般不予审查，但是对于行政处罚行为**明显不当**的，以及涉及**款额确定、认定错误**的情形，人民法院可以判决**变更**。

【注意 2】人民法院判决变更，**不得**加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告，且诉讼请求相反的**除外**。

4.对行政行为合法性审查原则

行政行为**是否合法、是否明显不当**，都是诉讼审查的具体标准。

【注意】行政诉讼仅审查其合法性（形式合法性和实质合法性），通常不审查合理性。

第二节 行政诉讼受案范围

【高频考点】行政诉讼受理案件范围及不受理的案件（★★★）

1.《行政诉讼法》规定的受案范围

（1）对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等**行政处罚**不服的；

（2）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等**行政强制措施和行政强制执行**不服的；

（3）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关**行政许可**的其他决定不服的；

（4）对行政机关作出的关于**确认**土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等**自然资源的所有权**或者**使用权**的决定不服的；

（5）对**征收、征用**决定及其**补偿**决定不服的；

（6）申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关**拒绝履行**或者**不予答复**的；

（7）认为行政机关**侵犯其经营自主权**或者**农村土地承包经营权、农村土地经营权**的；

（8）认为行政机关**滥用行政权力排除**或者**限制竞争**的；

（9）认为行政机关**违法集资、摊派**费用或者**违法要求履行**其他义务的；

（10）认为行政机关**没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇**或者**社会保险待遇**的；

（11）认为行政机关**不依法履行、未按照约定履行**或者**违法变更、解除**政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等**协议**的；

（12）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。

除上述规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的**其他**行政案件。

2.规范性文件附带审查

公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的**国务院部门**和**地方人民政府及其部门**制定的**规范性文件**不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以**一并**请求对该规范性文件进行**审查**。前述规定的规范性文件**不含规章**。

3.行政诉讼不受理的案件范围

（1）国防、外交等**国家行为**。

（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。（抽象行政行为）

（3）行政机关对**行政机关工作人员**的奖惩、任免等决定。（内部行为）

（4）法律规定由行政机关**最终裁决**的**行政行为**。（终局裁决）

（5）公安、国家安全等机关依照**刑事诉讼法**的**明确授权实施的行为。**

（6）**调解**行为以及法律规定的**仲裁**行为。

（7）**行政指导**行为。

（8）驳回当事人对行政行为提起申诉的**重复处理行为**。

（9）行政机关作出的**不产生外部法律效力**的行为。

（10）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等**过程性行政行为**。

（11）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的**执行行为**，但行政机关**扩大执行范围**或者采取**违法方式**实施的**除外**。

（12）上级行政机关基于**内部**层级**监督**关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。

（13）行政机关针对**信访事项**作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。

（14）对公民、法人或其他组织权利义务**不产生实际影响**的行为。

第四节 行政诉讼参加人

【高频考点】行政诉讼参加人概述【2023 年新增】

行政诉讼参加人，是指依法参加行政诉讼活动，享有诉讼权利，承担诉讼义务，并且与诉讼争议或诉讼结果有利害关系的人。

依据我国行政诉讼法的规定，行政诉讼参加人具体包括**当事人**、**共同诉讼人**、诉讼中的**第三人**和**诉讼代理人**。

【高频考点】行政诉讼原告（★★★）

（一）原告资格

1.行政行为的**相对人**以及其他与行政行为有**利害关系**的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。（行政相对人，行政相关人都具有原告资格）

2.有权提起诉讼的公民死亡，其近亲属可以提起诉讼。有权提起诉讼的法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼。

【注意】有下列情形之一的，属于行政诉讼法规定的“与行政行为有利害关系”：

（1）被诉的行政行为涉及其相邻权或者公平竞争权的；

（2）在行政复议等行政程序中被追加为第三人的；

（3）要求行政机关依法追究加害人法律责任的；

（4）撤销或者变更行政行为涉及其合法权益的；

（5）为维护自身合法权益向行政机关投诉，具有处理投诉职责的行政机关作出或者未作出处理的；

（6）其他与行政行为有利害关系的情形

（二）具体情形下原告资格的确定

1.合伙企业或其他非法人组织权益受到侵害的案件的原告资格

（1）合伙企业向人民法院提起诉讼的，应当以**核准登记的字号为原告**。

（2）未依法登记领取营业执照的个人合伙的**全体合伙人为共同原告**；全体合伙人可以推选代表人，被推选的代表人，应当由全体合伙人出具推选书。

（3）**个体工商户**向人民法院提起诉讼的，以**营业执照上登记的经营者为原告。有字号的**，以**营业执照上登记的字号为原告**，并应当注明该字号经营者的基本信息。

2.联营、合资、合作企业及其各方权益受到侵害案件的原告资格

联营企业、中外合资或者合作企业的联营、合资、合作各方，认为联营、合资、合作**企业权益**或者**自己一方合法权益**受行政行为侵害的，可以**自己的名义**提起诉讼。

3.非国有企业权益受到侵害案件的原告资格

非国有企业被行政机关注销、撤销、合并、强令兼并、出售、分立或者改变企业隶属关系的，该**企业**或者**其法定代表人**可以提起诉讼。

4.股份制企业权益受到侵害案件的原告资格

股份制企业的**股东大会、股东会、董事会**等认为行政机关作出的行政行为侵犯企业**经营自主权**的，可以**企业名义**提起诉讼。

5.非营利法人权益受到侵害案件的原告资格

事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等非营利法人的**出资人、设立人**认为行政机关作出的行政行为损害法人合法权益的，可以**自己的名义**提起诉讼。

6.业主共有利益受到侵害案件的原告资格

业主委员会对于行政机关作出的涉及业主共有利益的行政行为，可以**自己的名义**提起诉讼

【高频考点】行政诉讼被告（★★★）

（一）行政诉讼被告的特殊性

1.对原告的诉讼请求没有反诉权；

【注意】民事诉讼中被告有反诉权。

2.承担被诉行政行为合法性的举证责任；

3.有权执行或者改变被诉的行政行为。

（二）具体情形下被告资格的确定

1.一般性规定

行政行为不服	**被告**
行政机关作出行政行为	行政机关
由法律、法规、规章授权的组织所作的行政行为	该组织
行政机关委托的组织所作的行政行为	委托的行政机关
经上级行政机关批准的行政行为	在对外发生法律效力的文书上署名的机关
两个以上行政机关作出同一行政行为	共同作出行政行为的行政机关是共同被告

2.行政机关组建机关、内设机构、派出机构等

行政行为不服	**被告**
行政机关组建并被赋予行政管理职能但**不具有独立承担法律责任能力**的机构，以自己的名义作出行政行为	组建该机构的行政机关
法律、法规或者规章授权行使行政职权的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织，**超出法定授权范围**实施行政行为（幅度越权）	实施该行为的机构或者组织
行政机关的内设机构或者派出机构在**没有**法律、法规或者规章的授权下，以自己的名义作出行政行为（种类越权）	该行政机关
没有法律、法规或者规章规定，行政机关授权其内设机构、派出机构或者其他组织行使行政职权（属于行政诉讼法规定的委托）	该行政机关

3.开发区管理机构

行政行为不服		**被告**
国务院、省级人民政府批准设立的开发区管理机构	开发区管理机构作出的行政行为	该开发区管理机构
	所属职能部门作出的行政行为	其职能部门
其他开发区管理机构所属**职能部门**作出的行政行为	开发区管理机构**具有行政主体资格**	开发区管理机构
	开发区管理机构**没有行政主体资格**	设立该机构的地方人民政府

4.其他

<table>
<tr><th colspan="2">行政行为不服</th><th colspan="2">被告</th></tr>
<tr><td rowspan="3">行政机关被撤销或者职权变更</td><td>有继续行使其职权的行政机关</td><td colspan="2">继续行使其职权的行政机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">没有继续行使其职权的行政机关</td><td>非垂直领导</td><td>所属的人民政府</td></tr>
<tr><td>垂直领导</td><td>垂直领导的上一级行政机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">村民委员会或者居民委员会</td><td>村民委员会或者居民委员会</td><td colspan="2">村民委员会或者居民委员会</td></tr>
<tr><td>受行政机关委托作出的行为</td><td colspan="2">委托的行政机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">高等学校等事业单位以及律师协会、注册会计师协会等行业协会</td><td>依据授权实施的行政行为</td><td colspan="2">该事业单位、行业协会</td></tr>
<tr><td>受行政机关委托作出的行为</td><td colspan="2">委托的行政机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">房屋征收</td><td>市、县级人民政府确定的房屋征收部门组织实施房屋征收与补偿工作过程中作出行政行为</td><td colspan="2" rowspan="2">房屋征收部门</td></tr>
<tr><td>征收实施单位受房屋征收部门委托，在委托范围内从事的行为</td></tr>
</table>

（二）经复议案件被告资格的确定

（1）经复议的案件，复议机关决定**维持**原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是**共同被告**；复议机关**改变**原行政行为的，**复议机关**是**被告**。（复议维持共同告，复议改变告复议）

【注意 1】“复议机关改变原行政行为”，是指复议机关改变原行政行为的处理结果、确认原行政行为无效以及确认原行政行为违法。

【注意 2】复议机关改变原行政行为所认定的主要事实和证据、改变原行政行为所适用的规范依据，但未改变原行政行为处理结果的，视为复议机关维持原行政行为。

第五节 行政诉讼证据

【高频考点】行政诉讼中的举证责任（★★★）

举证责任是诉讼当事人对自己提出的诉讼主张提交证据加以证明的一种法定责任，否则将承担败诉的后果。

（一）被告的举证责任

1.被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的**证据**和**所依据**的规范性文件。

2.原告可以提供证明被诉行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告对被诉行政行为合法性的举证责任。

（二）被告的举证规则

1.举证期限及不举证的法律后果

（1）被告应当在**收到**起诉状副本之日起**15日内**提交答辩状，并提供据以作出被诉行政行为的全部证据和所依据的规范性文件；被告**不提供或者无正当理由逾期提供证据的，视为被诉行政行为没有相应的证据**。但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外。

（2）被告因不可抗力或者客观上不能控制的其他正当事由，不能在规定期限内提供证据的，应当在收到起诉状副本之日起15日内以**书面方式**向人民法院提出延期提供证据的申请。人民法院准许延期提供的，被告应当在正当事由消除后15日内提供证据。逾期提供的，视为被诉行政行为没有相应的证据。

（3）当事人申请延长举证期限，应当在**举证期限届满前向人民法院提出书面申请**。是否准许，由人民法院根据申请理由是否成立的具体情况决定。

2.举证范围

（1）被告举证的范围是被告作出行政行为所依据的事实材料和规范性文件。前者包括被告**依法收集的各种证据**，后者包括**正式公开的法律、法规、规章以及其他规范性文件**。人民法院根据审查案件的需要，可以要求被告提交规章以下的其他规范性文件。

（2）复议机关决定维持原行政行为的，人民法院应当在审查原行政行为合法性的同时，一并审查复议程序的合法性。作出原行政行为的行政机关和复议机关对原行政行为合法性共同承担举证责任，可以由其中一个机关实施举证行为。复议机关对复议程序的合法性承担举证责任。复议机关作共同被告的案件，复议机关在复议程序中依法收集和补充的证据，可以作为人民法院认定复议决定和原行政行为合法的依据。

（三）原告的举证规则

原告在行政诉讼中的举证情形有：

1.公民、法人或者其他组织向人民法院起诉时，应当提供其符合法定条件的相应的证据材料。但被告认为原告起诉超过起诉期限的除外。

2.在起诉被告不作为的案件中，原告应当提供其在行政程序中曾经提出申请的证据材料，但有**下列情形的除外：**

①被告应当依职权主动履行法定职责的；

②原告因被告受理申请的登记制度不完备等正当事由不能提供相关证据材料并能够作出合理说明的。

3.在行政赔偿

补偿诉讼中，原告应当对被诉行政行为造成损害的事实提供证据。因被告的原因导致原告无法举证的，由被告就该损害情况承担举证责任。

【提示】对于各方主张损失的价值无法认定的，应当由负有举证责任的一方当事人申请鉴定，但法律、法规、规章规定行政机关在作出行政行为时依法应当评估或者鉴定的除外；负有举证责任的当事人拒绝申请鉴定的，由其承担不利的法律后果。当事人的损失因客观原因无法鉴定的，人民法院酌情确定赔偿数额。

4.原告的举证期限

（1）原告应当在开庭审理前或者人民法院指定的交换证据清单之日提供证据。

（2）因正当事由申请延期提供证据的，经人民法院准许可以在法庭调查中提供。

（3）逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，视为放弃举证权利。

（4）原告在一审程序中无正当事由未提供而在二审程序中提供的证据，人民法院不予采纳。

第六节 行政诉讼程序

【高频考点】行政诉讼的起诉与受理（★★★）

（一）起诉

1.起诉的期限

（1）经过行政复议案件的起诉期限

公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在**收到复议决定书之日**起15日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不作决定的，申请人可以在**复议期满之日**起15日内向人民法院提起诉讼。法律另有规定的除外。

（2）直接提起行政诉讼的起诉期限

①公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自**知道**或者**应当知道作出行政行为之日**起6个月内提出。**法律**另有规定的除外。（知道行政行为，知道起诉期限）

②因**不动产**提起诉讼的案件自**行政行为作出之日**起超过20年，**其他**案件**自行政行为作出之日**起超过5年提起诉讼的，人民法院不予受理。

③行政机关作出行政行为时，**未告知**公民、法人或者其他组织**起诉期限**的，起诉期限从公民、法人或者其他组织**知道**或者**应当知道起诉期限之日**起计算，**但从知道**或者**应当知道行政行为内容之日起最长不得超过1年**。（知道行政行为，但不知道起诉期限）

④公民、法人或者其他组织不知道行政机关作出的行政行为内容的，其起诉期限从**知道**或者**应当知道该行政行为内容之日**起计算，但最长不得超过②定的起诉期限。（不知道行政行为，不知道起诉期限）

（3）起诉行政机关不作为案件的起诉期限

对行政机关不履行保护其人身权、财产权等合法权益的法定职责提起诉讼的，应当在行政机关**履行法定职责期限届满之日**起6个月内提出。

（4）起诉期限延长

公民、法人或者其他组织因不可抗力或者其他不属于其自身的原因耽误起诉期限的，被耽误的时间不计算在起诉期限内。因前述规定以外的其他特殊情况耽误起诉期限的，在障碍消除后10日内，可以申请延长期限，是否准许由人民法院决定。

2.起诉的条件与方式

（1）起诉的一般条件

提起诉讼应当符合下列条件：

①原告是符合行政诉讼法规定的公民、法人或者其他组织；

②有明确的被告；

③有具体的诉讼请求和事实根据；

④属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。

（2）起诉方式

起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，**可以口头起诉**，由人民法院记入笔录，出具注明日期的书面凭证，并告知对方当事人。

3.行政复议与行政诉讼

（1）复议前置

法律、法规规定应当先申请复议，公民、法人或者其他组织**未申请复议**直接提起诉讼的，人民法院裁定**不予立案**。

依照行政诉讼法规定，复议机关**不受理**复议申请或者在**法定期限内不作出复议决定**，公民、法人或者其他组织不服，依法向人民法院提起诉讼的，人民法院**应当受理**。

（2）自由选择

法律、法规未规定行政复议为提起行政诉讼必经程序，公民、法人或者其他组织既提起诉讼又申请行政复议的，由**先立案**的机关管辖；同时立案的，由公民、法人或者其他组织选择。公民、法人或者其他组织已经申请行政复议，在法定复议期间内又向人民法院提起诉讼的，人民法院不予受理。

（3）自由选择：先复议再撤回，可以提起行政诉讼

法律、法规未规定行政复议为提起行政诉讼必经程序，公民、法人或者其他组织向复议机关申请行政复议，在复议机关受理后，行政复议决定作出前，申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回行政复议申请，申请人在法定起诉期限内对原行政行为提起诉讼的，人民法院应当受理。

（二）立案

1.立案

（1）人民法院对符合起诉条件的案件应当立案，依法保障当事人行使诉讼权利。

（2）能够判断符合起诉条件的，应当当场登记立案；**当场**不能判断是否符合起诉条件的，应当在接收起诉状后**7日**内决定是否立案；7日内仍不能作出判断的，应当**先予立案**。

【注意】立案的期限，从受诉人民法院收到起诉状之日起计算；因起诉状内容欠缺而责令原告补正的，从人民法院收到补正材料之日起计算。

2.一次性告知补正

起诉状内容欠缺或者有其他错误的，应当给予指导和释明，并**一次性告知**当事人需要补正的内容。**不得**未经指导和释明即以起诉不符合条件为由不接收起诉状。

3.不接收起诉状

对于不接收起诉状、接收起诉状后不出具书面凭证，以及不一次性告知当事人需要补正的起诉状内容的，当事人可以向**上级**人民法院**投诉**。

4.裁定不予立案

（1）**不符合起诉条件**的，作出**不予立案**的裁定。裁定书应当载明不予立案的理由。原告对裁定不服的，可

以提起上诉。

（2）人民法院裁定准许原告撤诉后，原告以同一事实和理由重新起诉的，人民法院**不予立案**。准予撤诉的裁定确有错误，原告申请再审的，人民法院应当通过审判监督程序撤销原准予撤诉的裁定，重新对案件进行审理。

5.不裁不立

受诉人民法院自收到起诉状之日起**7日**内既**不立案**，又**不作出不予立案裁定**的，当事人可以**向上一级**人民法院**起诉**。上一级人民法院认为符合起诉条件的，应当立案、审理，也可以指定其他下级人民法院立案、审理。

6.裁定驳回起诉（纠错）

有下列情形之一，已经立案的，**裁定驳回起诉**：

（1）不符合行政诉讼法规定的起诉条件的；

（2）超过法定起诉期限且无行政诉讼法规定情形的；

（3）错列被告且拒绝变更的；

（4）未按照法律规定由法定代理人、指定代理人、代表人为诉讼行为的；

（5）未按照法律、法规规定先向行政机关申请复议的；

（6）重复起诉的；

（7）撤回起诉后无正当理由再行起诉的；

（8）行政行为对其合法权益明显不产生实际影响的；

（9）诉讼标的已为生效裁判或者调解书所羁束的；

（10）其他不符合法定起诉条件的情形。

【高频考点】行政诉讼第一审程序（★★★）

（一）审理前的准备

1.提交答辩状

（1）人民法院应当在立案之日起**5日内**，将起诉状副本和应诉通知书发送被告。被告应当在收到起诉状副本之日起**15日**内向人民法院提交作出行政行为的证据和所依据的规范性文件，并提出答辩状。人民法院应当在收到答辩状之日起**5日**内，将答辩状副本发送原告。

（2）被告不提出答辩状的，**不影响**人民法院审理。

2.组成合议庭（不可以审判员独任审理）

人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭。合议庭的成员，应当是**3人以上的单数**。

3.审核诉讼材料，调查收集证据。

4.确定开庭审理的时间地点，并通知当事人和其他诉讼参与人。

人民法院应当在开庭3日前用传票传唤当事人。对证人、鉴定人、勘验人、翻译人员，应当用通知书通知其到庭。

（二）开庭审理

第一审程序一律实行开庭审理，**不得书面审理**。

1.人民法院公开审理行政案件，但涉及**国家秘密、个人隐私**和**法律**另有规定的除外。

2.合议庭在审判长的主持下进行活动，实行集体审理、共同评议，按少数服从多数的原则表决案件审理中的重大事宜。

（三）判决

1.驳回原告的诉讼请求

行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，人民法院判决驳回原告的诉讼请求。

2.撤销判决

行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：

（1）主要证据不足的；

（2）适用法律、法规错误的；

（3）违反法定程序的；

（4）超越职权的；

（5）滥用职权的；

（6）**明显不当**的。

人民法院判决被告重新作出行政行为的，被告**不得以**同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为，但被诉行政行为因**违反法定程序**被人民法院判决撤销，被告重新作出行政行为**不受此限**。

行政行为有下列情形之一的，人民法院判决**确认违法**，但**不撤销**行政行为：

（1）行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；

（2）行政行为程序轻微违法（如处理期限轻微违法、通知或送达等程序轻微违法情形），但是对原告依法享有的听证、陈述、申辩等重要程序性权利**不产生实质损害**的。

3.履行判决

（1）原告请求被告履行法定职责的理由成立，被告违法拒绝履行或者无正当理由逾期不予答复的，人民法院可以判决在**一定期限**依法**履行**原告请求的**法定职责**；尚需被告调查或者裁量的，应当判决被告针对原告的请求重新作出处理。

（2）原告申请被告依法履行支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇等给付义务的理由成立，被告依法负有给付义务而拒绝或者拖延履行义务的，人民法院可以根据行政诉讼法的规定，判决被告在**一定期限内履行**相应的**给付义务**。

（3）人民法院经审理认为原告所请求履行的法定职责或者给付义务明显不属于行政机关权限范围的，可以**裁定驳回起诉。**

4.变更判决

行政处罚**明显不当**，或者其他行政行为涉及对**款额的确定、认定确有错误**的，人民法院可以判决**变更**。法院审理行政处罚案件时**不得**变更行政行为，加重对原告的处罚，包括加重处罚幅度或增加处罚内容；对行政机

关未处罚的相对人，法院**不得**判决直接给予处罚。

【注意】人民法院判决变更，不得加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告，且诉讼请求相反的**除外。**

5.确认违法判决

（1）行政行为有下列情形之一，不需要撤销或者判决履行的，人民法院判决确认违法：

①被告不履行或者拖延履行法定职责，但判决履行没有意义的；

②行政行为违法，但不具有可撤销内容的；

③被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的。

（2）原告起诉被告不作为，在诉讼中被告作出行政行为，原告不撤诉的，人民法院应当继续审查被告的不作为是否合法。

6.确认无效判决

（1）行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等**重大且明显违法**情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决确认无效。

有下列情形之一的，属于“重大且明显违法”：

①行政行为实施主体**不具有行政主体资格**；

②减损权利或者增加义务的行政行为**没有法律规范依据**；

③行政行为的内容**客观上不可能实施**；

（2）对于原告起诉请求确认无效或撤销行政行为，人民法院经审查认为行政行为无效的，人民法院均应作出**确认无效**判决。

（四）案件审理中需要注意的几个问题

1.撤回起诉

（1）申请撤诉

①人民法院对行政案件宣告判决或者裁定前，原告申请撤诉的，或者被告改变其所作的行政行为，原告同意并申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。

②人民法院裁定准许原告撤诉后，原告以同一事实和理由重新起诉的，人民法院不予立案。原告撤回起诉后无正当理由再行起诉，人民法院已经立案的，应当裁定驳回起诉。

（2）按撤诉处理

①经人民法院传票传唤，原告无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的；

②原告在法定期限内未缴纳诉讼费用且又未提出暂不缴纳诉讼费用申请的。

2.缺席判决

（1）针对原告的缺席判决

原告或上诉人申请撤诉，法院裁定不予准许，原告或上诉人经人民法院传票传唤无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

【提示】第三人经传票传唤无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，不发生阻止案件审理的

效果。

（2）针对被告的缺席判决

被告经人民法院传票传唤无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院可依法缺席判决。

3.诉讼中止和诉讼终结

（1）诉讼中止，是指在诉讼进行过程中，诉讼程序因特殊情况的发生而暂时停止。当中止诉讼的情况消除后，再恢复诉讼程序，中止前已进行的诉讼行为仍然有效。下列情况下，诉讼中止：

①原告死亡，须等待其近亲属表明是否参加诉讼的；

②原告丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的；

③作为一方当事人的行政机关、法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；

④一方当事人因不可抗力的事由不能参加诉讼的；

⑤案件涉及法律适用问题，需要送请有权机关作出解释或者确认的；

⑥案件的审判须以相关民事、刑事或者其他行政案件的审理结果为依据，而相关案件尚未审结的；

⑦其他应当中止诉讼的情形。

（2）诉讼终结，是指在诉讼程序因特殊情况的发生不能继续或者继续进行毫无意义的情况下，结束正在进行的诉讼程序。导致诉讼终结的情况是：

①原告死亡，没有近亲属或者近亲属放弃诉讼权利的；

②作为原告的法人或其他组织终止后，其权利义务的承受人放弃诉讼权利的；

③因原告死亡，须等待其近亲属表明是否参加诉讼或原告丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人或因作为一方当事人的行政机关、法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人而中止诉讼满 90 日仍无人继续诉讼的，裁定终结诉讼，但有特殊情况的除外。

4.财产保全与先予执行

（1）人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，裁定驳回申请。

（2）人民法院对起诉行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障金和工伤、医疗社会保险金的案件，权利义务关系明确、不先予执行将严重影响原告生活的，可以根据原告的申请，裁定先予执行。当事人对先予执行裁定不服的，可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

5.合并审理

合并审理的诉讼有“必须合并审理的诉讼”和“可以合并审理的诉讼”。

有下列情形之一的，人民法院可以决定合并审理：

（1）两个以上行政机关分别对同一事实作出行政行为，公民、法人或者其他组织不服向同一人民法院起诉的；

（2）行政机关就同一事实对若干公民、法人或者其他组织分别作出行政行为，公民、法人或者其他组织不服分别向同一人民法院起诉的；

（3）在诉讼过程中，被告对原告作出新的行政行为，原告不服，向同一人民法院起诉的；

（4）人民法院认为可以合并审理的其他情形（如：在涉及行政许可、登记、征收、征用和行政机关对民事

争议所作的裁决的行政诉讼中，当事人申请一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理）。

6.审理依据

（1）人民法院审理行政案件，以法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例为依据，参照适用规章。

（2）适用最高人民法院司法解释的，应当在裁判文书中援引。

（3）人民法院审理行政案件，可以在裁判文书中引用合法有效的规章及其他规范性文件。

（4）规范性文件不合法的，人民法院可以在裁判生效之日起3个月内，向规范性文件制定机关提出修改或者废止该规范性文件的司法建议。

【提示】规范性文件不合法，是指下列情形之一：

①超越制定机关的法定职权或者超越法律、法规、规章的授权范围的；

②与法律、法规、规章等上位法的规定相抵触的；

③没有法律、法规、规章依据，违法增加公民、法人和其他组织义务或者减损公民、法人和其他组织合法权益的；

④未履行法定批准程序、公开发布程序，严重违反制定程序的；

⑤其他违反法律、法规以及规章规定的情形。

7.调解

人民法院审理行政案件，不适用调解。但是行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。调解过程不公开，但当事人同意公开的除外。调解协议内容原则上不公开，但有例外。

【提示】调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解书生效日期根据最后收到调解书的当事人签收的日期确定。

（五）简易程序

1.简易程序适用范围

（1）人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：

①被诉行政行为是依法**当场作出**的；

②案件涉及款额**2000元以下**的；

③属于**政府信息公开**案件的。

除前述规定以外的第一审行政案件，当事人**各方同意适用**简易程序的，可以适用简易程序。

2.适用简易程序审理的行政案件，由审判员**1人独任审理**，并应当在立案之日起**45日**内审结。

3.人民法院在审理过程中，发现案情复杂不宜适用简易程序的，裁定**转为普通程序**。（只能简易转普通，不得普通转简易）

4.适用简易程序案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经人民法院准许，但**不得超过15日**。

第七章 民法总论

第一节 民法概述

【高频考点】民事责任的类型和免征事由（★★★）

1.民事责任的概念

民事主体因**违反**法定或者约定**民事义务**的，依法应当承担的民事法律后果。

2.民事责任的特征

（1）民事责任是违反民事义务的法律后果。

（2）民事责任具有直接救济性。填补受害人所受到的损害，其补偿范围与加害人所造成的损害大致相当（填平原则）。

（3）民事责任具有强制性。

3.民事责任的分类

（1）根据民事责任的产生原因划分

①侵权责任：因违反法律规定的义务致使他人损害，依法所应承担的民事责任。

②违约责任：因违反合同当事人约定的义务所应承担的民事责任。

③缔约过失责任：违反先合同义务致他人信赖利益损失所应承担的民事责任。

（2）根据民事责任的内容划分

①财产责任：支付违约金、赔偿损失。

②非财产责任：赔礼道歉、恢复名誉、消除影响。

（3）根据复数责任人之间的对外关系划分

①按份责任：复数责任人中的任何一个人仅按其确定份额对外承担责任，对**超出**其份额的部分**不**承担责任。二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。

②连带责任：复数责任人中的任何一个人均有义务应权利主体的请求而承担部分或者全部的民事责任；二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任；实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人**追偿**。

（4）根据侵权责任的构成要件和举证方式划分

①过错责任：以过错作为主观要件的侵权责任（加害人的过错须由受害人举证证明）（法律若无特别规定，侵权责任皆为过错责任）

②推定过错责任：以法律推定的过错作为主观要件的侵权责任（举证责任倒置：加害人须自证无过错方能免责，加害人若不能自证无过错，法律即推定其有过错）（适用须有法律的特别规定）

③无过错责任：不以过错作为主观要件的侵权责任（免除了受害人对加害人过错的举证责任，同时，加害

人也不得以自证无过错而免责）（适用须有法律的特别规定）

（5）根据出资人承担责任的财产范围划分

①有限责任：出资人仅以其**出资财产为限**对企业债务所承担的责任，如：有限责任公司和股份有限公司**股东**对公司债务所承担的责任、**有限合伙人**对合伙债务所承担的责任。

②无限责任：出资人须以其包括出资财产在内的**全部财产**对企业债务所承担的责任，如：**普通合伙人**对合伙债务所承担的责任（法律另有规定除外）。

4.民事责任的承担方式

（1）停止侵害；

（2）排除妨碍；

（3）消除危险；

（4）返还财产；

（5）恢复原状；

（6）修理、重作、更换；

（7）继续履行；

（8）赔偿损失；

（9）支付违约金；

（10）消除影响、恢复名誉；

（11）赔礼道歉。

5.民事责任的免责事由

（1）不可抗力。①不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。②因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任（法律另有规定的，依照其规定）。

（2）正当防卫。①因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。②防卫过当：正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫人应当承担适当的民事责任。

（3）紧急避险。①因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任，②危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当补偿。

（4）紧急救助行为。因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。

（5）受害人故意。损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。

（6）第三人至害。损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。

（7）自甘冒险。自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任。

（8）自助行为。合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。

第二节 民事主体

【高频考点】自然人的民事权利能力和民事行为能力（★★★）

1.自然人的民事权利能力

法律赋予自然人享有民事权利、承担民事义务的法律**资格**。

（1）自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务；自然人的民事权利能力一律平等。

（2）涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

2.自然人的民事行为能力

完全民事行为能力人	能够独立实施任何民事法律行为	年龄：≥18
		16周岁以上不满18周岁但以自己的**劳动收入**为**主要生活来源**（16≤X＜18）
限制民事行为能力人	①与其年龄、智力、精神健康状况相适应 ②纯获利	年龄：8≤X＜18
		不能完全辨认自己行为的成年人
无民事行为能力人	不能独立实施任何民事法律行为	年龄：＜8
		8周岁以上不能辨认自己行为的未成年人
		不能辨认自己行为的成年人

【注意1】纯获利益的行为，限制行为能力人仍可实施。

【注意2】与民事行为能力制度密切相关的是监护制度。**【2023年新增】**

【注意3】监护是保障限制行为能力人和无行为能力人这两类行为能力欠缺者的合法权益，弥补其民事行为能力不足的法律制度。**【2023年新增】**

【高频考点】法人（★★★）

1.法人的概念和特征

（1）法人是团体。

（2）法人是由民法赋予民事权利能力和民事行为能力的团体。

（3）法人具有独立人格

（4）法人具有独立的财产。

法人的财产**独立于其他法人和自然人**的财产；**独立于法人成员**的财产；独立于其捐助人或出资人的其他财产。

（5）法人**以自己的名义**参加民事法律关系。法人有自己的名称，得以自己的名义参加民事活动，为自己设定权利、承担义务。

（6）法人**独立承担民事责任**。

2.法人的类型

营利法人	有限责任公司 股份有限公司 其他企业法人	（1）依法登记成立。 （2）由登记机关发给营利法人营业执照。 （3）**营业执照签发日期为营利法人的成立日期。** （4）设立营利法人应当依法制定法人章程。
非营利法人	事业单位法人	（1）经依法登记成立，取得事业单位法人资格； （2）依法**不需要办理法人登记**的，从成立之日起，具有事业单位法人资格
	社会团体法人	（1）基于会员共同意愿，为公益目的或者会员共同利益等非营利目的设立的社会团体，**经依法登记成立，取得社会团体法人资格；** （2）依法**不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有社会团体法人资格**
	捐助法人	为公益目的以捐助财产设立的基金会、社会服务机构等。捐助人有权向捐助法人查询捐助财产的使用、管理情况，并提出意见和建议
特别法人	机关法人	有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。
	农村集体经济组织法人 城镇农村的合作经济组织法人 基层群众性自治组织法人	--

3.法人的成立

（1）依法成立。

（2）有自己的财产和经费。

（3）有自己的名称、组织机构和住所。

法人住所	主要办事机构所在地为住所
组织机构 （亦称法人机关）	①意思机关（权力机关），如股份有限公司的股东大会
	②执行机关，如股份有限公司的董事会
	③代表机关，主要指**法定代表人**

	④监督机关，如股份有限公司的监事会
法定代表人	①法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受； ②法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人； ③法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿

4.法人的权利能力和行为能力

法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

5.法人的变更

法人变更，是指法人的登记事项、组织形式发生变更以及法人的合并和分立。

6.法人的终止

法人的终止，是指法人的民事主体资格的丧失，即法人全部民事能力丧失。

（1）法人终止的法定事由

有下列原因之一并依法完成清算、注销登记的，法人终止：

①法人解散；

②法人被宣告破产；

③法律规定的其他原因。

法人终止，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。

（2）法人解散

有下列情形之一的，法人解散：

①法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现；

②法人的权力机构决议解散；

③因法人合并或者分立需要解散；

④法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或者被撤销；

⑤法律规定的其他情形。

第三节 民事权利

【高频考点】民事权利的取得、变更和消灭（★★★）

（一）民事权利的取得

依是否源自前手权利的让渡，可将民事权利的取得方式划分为原始取得和继受取得。

1.原始取得，是指不以他人既存的权利为前提的权利取得，也称"权利的最初取得”“权利的第一次发生”，是民事权利的绝对发生。原始取得的发生原因：

①法律的直接规定。如善意取得动产或者不动产物权、无主物的法定归属；

②事实行为。如基于先占而取得无主动产的所有权、基于添附而取得添附物的所有权、基于建造而取得不

动产的所有权、基于无因管理而取得必要费用的返还请求权、基于侵权行为而取得损害赔偿请求权；

③事件。如基于不当得利而取得不当利益的返还请求权；

④民事法律行为。如基于合同而取得合同债权。

2.继受取得，是指自前手权利人处承受而来的权利取得，也称“权利的传来取得”，是民事权利的相对发生。

（1）继受取得的发生原因主要是**民事法律行为。**如基于交付而受让或者设定动产物权、基于登记而受让或者设定不动产物权、基于合同而设定用益物权或者担保物权；

（2）继受取得的发生原因也可以是民事法律行为之外的**法律事实。**如基于继承而取得遗产的所有权。

（二）民事权利的变更

民事权利的变更，是指权利的内容、效力于存续期间发生变化的情形。

1.民事权利内容的变更。

分类	举例
量变	所有权因添附而扩大、因标的物部分灭失而缩小； 债权因部分清偿而缩小
部分质变	所有权因标的物出租或者抵押而产生负担从而变得不再圆满； 无息债权变为有息债权

2.民事权利效力的变更。

效力变更，是指权利源自法律所赋之强制性作用力的增、减变化。如原本具备公力救济请求权的债权因债务人行使诉讼时效抗辩权而成为自然债权、抵押权顺位的变化等。

（三）民事权利的消灭

1.绝对消灭，即权利本身不复存在。

2.相对消灭，是指权利由前手移转于后手，权利本身并不因此而消灭。

第四节 民事法律行为和代理

【高频考点】民事法律行为的成立和生效（★★★）

（一）民事法律行为的成立要件

1.一般成立要件

（1）一般成立要件，是指所有法律行为成立均须具备的要件。该要件只有一个，即**意思表示。**

（2）对于单方法律行为而言，当事人意思表示完成，法律行为即告成立；对于双方或者多方法律行为而言，须双方或者多方意思表示达成一致，法律行为始告成立。

（3）意思表示的生效时间

①以**对话方式**作出的意思表示，**相对人知道其内容时**生效。

②以**非对话方式作**出的意思表示，**到达相对人时**生效。

③以**非对话方式**作出的采用**数据电文形式**的意思表示，相对人**指定特定系统**接收数据电文的，该数据电文**进入该特定系统时**生效；**未指定特定系统**的，**相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时**生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。

④**无相对人**的意思表示，**表示完成时**生效。法律另有规定的，依照其规定。

⑤以**公告方式**作出的意思表示，**公告发布时**生效。

2.特别成立要件

特别成立要件，是指法律对特定类型法律行为的成立于一般成立要件之外特别要求具备的条件。

（1）**要物法律行为的**特别成立要件：**标的物的交付。**

（2）**要式法律行为**的特别成立要件：书面或者公证形式的制作。

（二）民事法律行为的生效要件

1.一般生效要件

一般生效要件，是指所有法律行为生效皆须具备的要件。法律行为的一般生效要件包括：

（1）行为人**具有相应的民事行为能力。**

（2）**意思表示真实。**

（3）**不违反**法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

2.特别生效要件

特别生效要件，是指法律对特定类型法律行为的生效于一般生效要件之外特别要求具备的条件。这些特别生效要件或来自当事人的特别约定，或来自法律的特别规定。

（1）**附停止条件法律行为**的特别生效要件：**所附条件成就。**

（2）**附始期法律行为**的特别生效要件：**所附期限届至。**

（3）**公示行为**的特别生效要件：**采行法定公示方式。**

（4）**效力待定行为**的特别生效要件：**第三人同意。**

（5）**遗嘱**的特别生效要件：**遗嘱人死亡。**

（6）法律规定须经批准方能生效的法律行为：获得批准。

【高频考点】民事法律行为附款（★★★）

附条件民事法律行为	（1）即指**包含条件附款**的法律行为。 （2）条件，是由行为人选定，用以控制法律行为中意思表示效果发生或消灭的、**成就与否并不确定**的将来事实。包括“延缓条件”（“停止条件”）和“解除条件”； （3）停止条件成就，法律行为开始生效。解除条件成就，法律行为效力消灭。 **【注意】**当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。 民事法律行为所附条件的特征：①条件须是将来发生的事实；②条件成就与否须不确

	定；③条件须为合法事实；④条件须为当事人约定的事实。
附期限民事法律行为	（1）附期限的法律行为，即指包含有期限附款的法律行为。 （2）期限，是由行为人选定的、用以控制法律行为中意思表示效果发生或消灭的、**将来确定发生**的事实。其中，控制民事法律行为生效的期限称“生效期限”“始期”或者“延缓期限”；控制民事法律行为失效的期限称“终止期限”“终期”或者“解除期限”。 （3）始期届至，民事法律行为开始生效。终期届满，民事法律行为效力消灭。

【高频考点】民事法律行为的效力样态（★★★）

（一）完全生效民事法律行为

完全生效民事法律行为，是指完全具备法律规定和当事人约定的生效要件的民事法律行为。

（二）尚未完全生效民事法律行为

尚未完全生效民事法律行为，亦称"待生效民事法律行为"，是指存在法定或者约定的特别生效要件，而该特别生效要件尚未成就的民事法律行为。

1.该类民事法律行为已成立且具备一般生效要件，但因其特别生效要件尚未齐备，故其效力状态属于待生效。

2.该类民事法律行为已具备一般生效要件，对双方具有一定的拘束力，任何一方不得擅自撤回、解除或者变更。只是在法定或者约定的特别生效要件成就前，不能产生民事法律行为的固有效力。

3.尚未完全生效的民事法律行为包括：

（1）尚未满足**法定特别生效要件**的民事法律行为。如法律、行政法规规定须办理批准等手续方能生效的民事法律行为，尚未办理批准等手续。

（2）尚未满足**约定特别生效要件**的民事法律行为。如附停止条件或附始期的民事法律行为，所附停止条件尚未成就或所附期限尚未届至。

4.尚未完全生效民事法律行为，**若其法定或者约定的特别生效要件确定的不能成就，则其即转化为“确定不生效民事法律行为”。**前者如法律、行政法规规定须办理批准等手续方能生效的民事法律行为，终未获批准；后者如附停止条件的民事法律行为，所附停止条件确定不能成就。

（三）可撤销民事法律行为

可撤销民事法律行为，是指由于存在**法定的重大意思表示瑕疵**而**可以请求法院或者仲裁机构予以撤销**的民事法律行为。

1.可撤销民事法律行为**在被撤销前为生效民事法律行为，**且在撤销权人行使撤销权之前，该生效效力持续存在。

2.**被撤销**的民事法律行为**自始没有**法律约束力。

3.撤销权应当由当事人行使。当事人未请求撤销的，人民法院不应当主动依职权予以撤销。

4.可撤销民事法律行为包括：

（1）基于**重大误解**所实施的民事法律行为。

行为人对行为的性质、对方当事人或者标的物的品种、质量、规格、价格、数量等产生错误认识，按照通常理解如果不发生该错误认识，行为人就不会作出相应意思表示的，可以认定为重大误解。

（2）**一方以欺诈手段，**使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。

故意告知虚假情况，或者负有告知义务的人故意隐瞒真实情况，致使当事人基于错误认识作出意思表示的，可以认定为欺诈。

（3）**第三人实施欺诈**行为使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，且对方知道或者应当知道该欺诈行为的。

（4）**一方或者第三人以胁迫**手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。

（5）一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形所实施的**显失公平**的民事法律行为。

显失公平的民事法律行为限于财产法律行为。

（6）行为人的意思表示存在第三人转达错误情形下所实施的民事法律行为。

5.撤销权作为**形成权，**受除斥期间的限制。有下列情形之一的，**撤销权消灭：**

（1）当事人**自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内、重大误解**的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 **90 日**内没有行使撤销权；

（2）当事人**受胁迫，自胁迫行为终止之日起 1 年内**没有行使撤销权；

（3）当事人**知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃**撤销权；

（4）当事人自民事法律行为**发生之日起 5 年**内没有行使撤销权。

（四）效力待定民事法律行为

效力待定民事法律行为，是指民事法律行为的效力**有待第三人以行为使之确定**的民事法律行为。

1.效力待定民事法律行为的效果效力最终取决于第三人（承认权人或者同意权人）的行为（承认、同意或者拒绝）。若第三人承认或者同意，则效力待定民事法律行为的效果效力即确定地自始发生。若第三人拒绝，则效力待定民事法律行为的效果效力即确定地自始不发生。

2.效力待定民事法律行为包括：

（1）**无权处分**行为；

（2）**狭义无权代理；**

（3）**债务承担；**

（4）**限制**民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况**不相适应的、有待其法定代理人同意或者追认**的民事法律行为。

3.**相对人可以催告**法定代理人**自收到通如之日起 30 日**内予以追认。法定代理人**未作表示的，视为拒绝追认。**民事法律行为被追认前，善**意**相对人**有撤销**的权利。撤销应当以通知的方式作出。

（五）无效民事法律行为

无效民事法律行为，是指虽已成立，但严重欠缺《民法典》第 143 条所规定的一般生效要件，**自始、确定**和**当然**不发生民事法律行为固有效力的民事法律行为。

1.民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

2.无效民事法律行为包括：

（1）**无民事行为能力人实施**的民事法律行为。

（2）行为人与相对人**恶意串通，**损害他人合法权益的民事法律行为。

（3）行为人与相对人以**虚假的意思表示**实施的民事法律行为。

（4）**违反法律、行政法规的强制性规定**的民事法律行为，但该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

（5）**违背公序良俗**的民事法律行为。

根据裁判实务归纳的违背公序良俗的行为类型主要包括：

①危害国家政治、经济、财政、税收、金融、治安等秩序类型；②危害家庭关系行为类型；③违反性道德行为类型④违反人权和人格尊重行为类型；⑤限制经济自由行为类型；⑥违反公平竞争行为类型；⑦违反消费者保护行为类型；⑧违反劳动者保护行为类型等。

【高频考点】狭义无权代理和表见代理（★★★）

无权代理，是指**在没有代理权的情况下，以他人名义**实施的旨在**将其法律效果归属于该他人**的代理行为。无权代理有广义和狭义之分。广义的无权代理包括狭义无权代理和表见代理。

1.狭义无权代理

（1）狭义无权代理的类型：

①**没有代理权**的无权代理，是指既没有委托授权，又没有法律规定，而以他人名义实施民事法律行为的代理。

②**超越代理权**的无权代理，是指代理人超越代理权限范围而进行的代理。

③代**理权终止后**的无权代理，是指代理人在代理期限届满或者约定的代理事务完成甚至被解除代理权后，仍以被代理人的名义进行的代理。

（2）狭义无权代理的法律效果：

①狭义无权代理属于**效力待定**法律行为，其对被代理人有效与否取决于被代理人的意思。

②**若被代理人未予追认，则对被代理人不发生效力。相对人可以催告**被代理人自**收到通知之日起30日内**予以追认。被代理人**未作表示的，视为拒绝追认。**

③行为人实施的行为被追认前，**善意**相对人**有撤销**的权利。撤销应当以通知的方式作出。

④行为人实施的行为**未被追认的，善意**相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿。但是，赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。

⑤相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。

2.表见代理

表见代理，是指行为人虽**无代理权**但**存在足以使相对人相信其有代理权**的表征，从而须**由本人负授权之责**的代理。

（1）表见代理的构成要件

①行为人无代理权但以本人名义实施民事法律行为；

②须客观上存在使相对人相信行为人有代理权的表征；

③相对人须为善意，即无过失地不知行为人无代理权；

④具备民事法律行为的生效要件。

（2）表见代理的类型

①授权表示型表见代理，即代理人虽事实上未获授权而实施、但存在使相对人善意信赖其具有代理权外观的无权代理。

②权限逾越型表见代理，即代理人超越代理权限范围而实施、且存在使相对人善意信赖其未超越代理权限外观的无权代理。

③权限延续型表见代理，即代理人在代理期限届满后或者约定的代理事务完成后，或者代理权被撤销后实施的，且存在使相对人善意信赖其仍具有代理权外观的无权代理。

（3）表见代理的法律效果

法律规定**表见代理发生有权代理之效果，**即由本人而非行为人承受代理行为的效果。

《民法典》第 172 条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，**代理行为有效。**

第五节 诉讼时效和除斥期间

【高频考点】诉讼时效（★★★）

（一）诉讼时效概述

诉讼时效，是指**请求权人在法定期间内不行使请求权，**即**导致义务人永久抗辩权**发生效果的时效。

1.诉讼时效的适用对象：**请求权，**包括债权请求权和物权请求权，但下列请求权**不适用诉讼时效：**

①请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；

②不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；

③请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；

④支付存款本金及利息请求权；

⑤兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；

⑥基于投资关系产生的缴付出资请求权；

⑦依法不适用诉讼时效的其他请求权。

2.诉讼时效期间届满的法律效果：义务人取得永久抗辩权。诉讼时效期间届满的，**义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得**以诉讼时效期间届满为由抗辩；**义务人已经自愿履行的，不得**请求返还。

3.**人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。**

（二）诉讼时效期间的类型

1.普通诉讼时效期间，是指可以普遍适用于一般民事法律关系的诉讼时效期间。

《民法典》第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为**3年。**法律另有规定的，依照其规定。

2.特殊诉讼时效期间，是指法律规定仅适用于某些特定民事法律关系的诉讼时效期间。

《民法典》第594条规定，因**国际货物买卖合同和技术进出口合同争议**提起诉讼或者申请仲裁的时效期间为**4年。**

（三）诉讼时效期间的起算

1.一般情形下，诉讼时效期间自权利人**知道或者应当知道权利受到损害**以及**义务人**之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到**侵害之日**起超过**20年**的，人民法院不予保护。

【提示】《民法典》规定的“20年期间”并非诉讼时效期间，而是对诉讼时效期间予以限制的最长权利保护期间，该期间性质上属于不变期间。

2.当事人约定同一债务**分期履行**的，诉讼时效期间自**最后一期履行期限届满之日**起计算。

3.**无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人**的请求权的诉讼时效期间，自该**法定代理终止之日**起计算。

4.**未成年人**遭受**性侵害**的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人**年满18周岁之日**起计算。

5.**无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的权利受到损害的，**诉讼时效期间自其法**定代理人知道或者应当知道权利受到损害**以及**义务人**之日起计算，但是法律另有规定的除外。

（四）诉讼时效期间中止

诉讼时效期间的中止，是指在诉讼时效期间的**最后6个月内，**因法定障碍事由的发生使权利人无法行使清求权，从而**暂时**停止计算诉讼时效期间的制度。发生诉讼时效中止的，**自中止时效的原因消除之日起满6个月，**诉讼时效期间届满。

诉讼时效期间中止的法定事由：

（1）不可抗力；

（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；

（3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；

（4）权利人被义务人或者其他人控制；

（5）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

（五）诉讼时效期间中断

诉讼时效期间中断，是指在诉讼时效期间进行中，因法定事由的发生致使**已经进行的诉讼时效期间全部归于无效，**诉讼时效期间**重新开始计算的**制度。诉讼时效期间因法定事由而中断的，从中断有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算。

诉讼时效期间中断的法定事由：

（1）**权利人向义务人提出履行请求。**可以认定为该类法定事由的情形还包括：

①当事人一方直接向对方当事人**送交主张权利文书，对方当事人在文书上签名、盖章、按指印**或者虽未签

名、盖章、按指印但**能够以其他方式证明该文书到达对方当事人**的。

②当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，**信件或者数据电文到达或者应当到达对方当事人**的。

③当事人**一方为金融机构，**依照法律规定或者当事人约定**从对方当事人账户中扣收欠款本息的。**

④当事人一方下落不明，对方当事人在**国家级**或者下落不明的当事人一方**住所地的省级**有影响的媒体上刊登具有主张权利内容的公告的，但法律和司法解释另有特别规定的，适用其规定，

⑤权利人**向义务人的代理人、财产代管人或者遗产管理人等提出履行请求。**

（2）**义务人同意履行义务。**可以认定为该类法定事由的情形还包括：**义务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或者行为。**

（3）**权利人提起诉讼或者申请仲裁。**与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形包括：申请支付令、申请破产、申报破产债权、为主张权利而申请宣告义务人失踪或者死亡、申请诉前财产保全、申请诉前临时禁令、申请强制执行、申请追加当事人或者被通知参加诉讼、在诉讼中主张抵销等。

【提示】诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。

第八章 物权法

第一节 物权总论

【高频考点】物权特征（★★★）

1.物权是对物的直接支配权

支配，是指依权利人的意思，对标的物加以管领和处分。

直接，物权人对标的物的支配权，无需他人行为和意思的介入即可径直实现。

2.物权是排他性财产权

（1）物权具有直接排除不法妨碍的效力

（2）一物之上不能同时存在两个以上互不相容的物权，但并不排除：

①多人共享一个物权，如共有。

②一物之上所有权和他物权同时存在，如所有权与抵押权。

③一物之上有互不影响的数个他物权同时存在，如一个抵押物上同时存在数个抵押权。

④法律针对物权所规定的限制，如相邻权。

3.物权是对世权

物权的权利主体是特定的，而义务主体是不特定的。

4.物权是绝对权

物权的实现，无须义务人以积极行为予以协助，仅由权利人对标的物进行直接支配即可（义务人所负担的

是不作为的义务）。

【高频考点】物权法的基本原则（★★★）

1.物权客体特定原则（一物一权原则）	是指一个物上只能有一个所有权，不允许有互不相容的两个以上的物权同时存在。如一物之上只能设立一个所有权
2.物权法定原则	物权的种类、内容均由法律规定，不得由当事人自由创设
3.公示、公信原则	物权的存在与变动均应当具备法定的公示方式。 不动产：登记。动产：占有。 即法律推定不动产的登记人或动产的占有人为财产的真正权利人

【高频考点】物权的效力（★★★）

1.物权的排他支配力

指法律赋予物权的、保障物权人对标的物直接为一定行为并享受其利益的作用力。

（1）自物权具有完全的排他支配力，在合法范围内，自物权人能够依自己的意思自由支配标的物。

（2）他物权具有不完全的排他支配力，他物权人只能在法律规定或者合同约定的时空范围内，对他人之物享有一定的支配权。

2.物权优先力

（1）物权原则上优于债权

当同一标的物上，物权和债权并存时，无论物权设立先后，其效力通常优于债权。

【例外】

①让与不得击破租赁：租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。【2023 年调整】

②预告登记请求权：当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。

（2）物权相互间的优先力

当同一物上两个以上物权并存时，成立在先的物权通常优于成立在后的物权。

【限制】

①基于当事人意思的限制：用益物权或者担保物权优于在先存在的所有权。

②基于法律规定的价款优先权（购置款超级优先权）的限制：动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后 10 日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

③基于法律规定的法定担保物权优于约定担保物权的限制：同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。

3.物权的妨害排除力——“物上请求权”

是指物权的圆满状态受到妨害或有被妨害的危险时，物权人为恢复其物权的圆满状态可以请求妨害人为一

定行为或不为一定行为的权利。

【注意】物上请求权不适用诉讼时效抗辩。

4.物权的追及效力

物权的标的物无论辗转落入何人之手，物权人皆可追及物的所在并对物的占有人主张物权、请求返还的效力。

【限制】第三人的善意取得可以阻断物权的追及效力、未按法定方式公示的物权不得对抗善意第三人、错误登记的物权不得对抗善意第三人以及正常经营买受人特别保护规则等。

【高频考点】物权变动（★★★）

（一）物权变动的意义

物权变动，是指物权的设立、变更和终止的变化状态。

1.物权的设立

物权的设立，又称“物权的发生”，是指民事主体依法设立新的物权。为自己设立物权，称为“物权的取得”；为他人设立物权，称为“物权的设定”。

（1）原始取得，是指权利人不依赖他人既有的权利和意志，而是基于法律规定的特定法律事实而取得物权。

【举例】
①基于法律规定而由国家取得无人认领的遗失物、漂流物、埋藏物或者隐藏物的所有权；
②因加工、附合、混合而取得加工物或者合成物的所有权；
③因先占而取得无主动产的所有权等。

（2）继受取得，是指基于他人既有的权利而取得物权。

①移转型继受取得。如基于买卖、赠与等原因而受让他人所有权，或者基于继承而取得遗产所有权。

②创设型继受取得。如在他人之物上设定用益物权或者担保物权。

2.物权的变更

物权的变更，是指物权的客体、内容的部分改变。如标的物数量的增减、权利范围的扩大或者缩减等。

3.物权的终止

物权的终止，是指物权归于消灭。

（1）**绝对消灭，**是指物权不但与原权利人相分离，而且在客观上不复存在。如房屋被洪水冲毁。

（2）**相对消灭，**是指物权虽与原权利人相分离，但客观上并未丧失其存在，而是与新的权利人相结合。如所有权转让，对转让人而言是所有权的消灭，对受让人而言则是所有权的继受取得。

（二）物权变动的原因

1.民事法律行为。如基于买卖、互易、赠与、遗赠等原因而完成的物权让与行为，抛弃物权及设定、变更或者终止他物权的各种民事法律行为。

2.民事法律行为之外的法律事实。如房屋建造、先占、添附、继承、无主物的法定取得、天然孳息收取、标的物消费、标的物灭失及混同等。

3.公法上的原因。如公用征收、没收、罚款等。

（三）物权变动的原则

公示原则	物权变动须以法定公示方式进行方能生效的原则。 ①动产物权——交付标的物； ②不动产物权——登记。但法律另有规定的除外
公信原则 （善意取得制度建立的基础）	指物权变动公示的，即取得法律上的公信力。 ①动产物权：占有人转让动产物权，受让人不知道且无义务知道其无处分权的，取得了标的物的占有，就取得了物权。 ②不动产物权：经登记转让的，受让人不知道且无义务知道登记有瑕疵的，办理完登记手续就取得了物权。

（三）我国的物权变动立法

1.我国《民法典》对于物权变动原则上采取了“公示生效主义”立场，同时也规定了若干“公示对抗主义”的例外情形。

2.根据《民法典》规定，可将我国物权变动立法的基本内容归纳如下：

（1）**不动产物权变动，**以**登记**为生效要件，但是法律另有规定的除外。

（2）**动产物权变动，**以**交付**为生效要件，但是法律另有规定的除外。

3.法律另有规定的情形主要包括：

（1）《民法典》第209条第2款规定，依法属于**国家所有的自然资源，所有权可以不登记。**

（2）《民法典》第225条规定，**船舶、航空器和机动车**等的物权的设立、变更、转让和消灭，**未经登记，不得对抗善意第三人。**

（3）《民法典》第226条规定，动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力。

（4）《民法典》第227条规定，动产物权设立和转让前，第三人占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。

（5）《民法典》第228条规定，动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力。

（6）《民法典》第229条规定，**因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定**等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，**自法律文书或者征收决定等生效时**发生效力。

（7）《民法典》第230条规定，因**继承**取得物权的，**自继承开始时**发生效力。

（8）《民法典》第231条规定，因**合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时**发生效力。

（9）《民法典》第333条规定，土地承包经营权自**土地承包经营权合同生效时**设立。

（10）《民法典》第374条规定，地役权**自地役权合同生效时**设立。

（四）不动产登记

《民法典》规定的不动产登记类型主要有：

1.变动登记

（1）不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。

（2）不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自**记载于不动产登记簿时**发生效力。

2.更正登记

更正登记，是指为了**消除登记内容的错误或者遗漏**而对既有的登记内容进行订正和补充的一种登记。更正登记是**对原登记权利的涂销登记**，同时是对真正权利的初始登记。

《民法典》第220条第1款规定,权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人**书面同意更正**或者**有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。**

3.异议登记

异议登记，也称“异议抗辩登记”，不动产登记簿记载的**权利人不同意更正的，**利害关系人**可以申请异议登记。**登记机构予以异议登记，申请人**自异议登记之日起15日内不提起诉讼的，异议登记失效。**异议登记**不当，**造成权利人损害的，**权利人可以向申请人请求损害赔偿。**

4.预告登记

（1）《民法典》第221条第1款规定，当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。**预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。**

（2）《民法典物权编的解释（一）》第4条规定，**未经预告登记的权利人同意，转让不动产所有权等物权，**或者设**立建设用地使用权、居住权、地役权、抵押权等其他物权的，**应当依照《民法典》第221条第1款的规定，认定其**不发生物权效力。**

（3）《民法典》第221条第2款规定，预告登记后，**债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起90日内**未申请登记的，**预告登记失效**。可以认定为“债权消灭”的情形主要有：

①预告登记的买卖不动产物权的协议被认定无效；

②预告登记的买卖不动产物权的协议被撤销；

③预告登记的权利人放弃债权。

（五）动产交付

交付是移转标的物占有的行为。包括现实交付和交付替代。

1.现实交付

现实交付，是指在设立和转让动产物权时，由出让人将其直接管理支配下的动产现实地移转给受让人，使受让人取得对动产的直接占有。

在动产物权以仓单、提单等物权凭证为表现形式时，动产物权的变动通常无需对动产进行现实交付，而是以仓单、提单的交付来代替动产的现实交付，民法理论上，称此种交付为“拟制交付”。在法律效果上，拟制交付与现实交付完全相同。

2.交付替代——“观念交付”

观念交付，是指在设立或转让动产物权时，出让人和受让人之间对于动产的占有仅仅在观念上发生移转，在外观上并未现实地发生变化。

（1）简易交付，是指在设立和转让动产物权之前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力。

（2）指示交付，也称“返还请求权的让与”。是指在设立或转让动产物权之前，第三人占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。

（3）占有改定，是指在动产物权转让时，出让人与受让人约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力。占有改定使受让人基于 媒介关系取得对该动产的间接占有，以代替现实交付。

第二节 所有权

【高频考点】所有权的取得和消灭（★★★）

（一）所有权的取得

根据是否以他人既存所有权为前提，可将所有权的取得方式划分为两类：

①原始取得，是指**非依他人既存的权利和意志**而是**基于法律规定直接**取得所有权，包括先占、生产、收取孳息、添附物的归属、无主物和罚没物的法定归属、善意取得、没收等。

②继受取得，是指**基于他人既存的权利和意志**而取得所有权，如买受人自出卖人处受让标的物所有权。

1.不动产所有权取得的法律原因

（1）依**民事法律行为**而取得

①双方民事法律行为，如基于买卖、赠与、互易等原因而受让不动产所有权；

②单方法律行为，如因受遗赠而取得不动产所有权。

（2）依**民事法律行为以外的法律事实**而取得。继承；建造；法院判决、强制执行；公用征收、没收等行政行为；善意取得。

2.动产所有权取得的法律原因

（1）依民事法律行为而取得

①双方法律行为，如基于买卖、赠与、互易等原因而受让动产所有权；

②单方法律行为，如因受遗赠而取得动产所有权。

（2）依民事法律行为以外的法律事实而取得。

①继承。

②法院判决、强制执行。

③公用征收、没收罚款等行政行为。

④收取孳息。

天然孳息，由**所有权人**取得；既有所有权人又有用益物权人的，由**用益物权人**取得。当事人另有约定的，

按照其**约定**。**法定孳息，**当事人有约定的，按照**约定**取得；没有约定或者约定不明确的，按照**交易习惯**取得。

⑤无主物的法定归属。

遗失物、漂流物、埋藏物、隐藏物自**发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有。**无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有，用于公益事业；死者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所有。

⑥先占，是指以所有的意思，先于他人占有无主动产而取得其所有权的法律事实。

⑦善意取得。

⑧添附，是指不同所有人的物因附合、混合或者加工而形成不可分割的物或者具有新质的物，从而引起所有权变动的法律事实。

附合	是指不同所有人的物因结合形成难以分割之物，非毁损不能分离或者分离于经济上不合理	
	情形	**动产与不动产**附合，如甲将乙的钢筋建造自己的房屋
		动产与动产附合，如甲乙各出木板装订成木箱；甲将油漆漆于乙的木板上
混合	是指不同所有人的**动产**因相互混杂或者交融，难以识别或者识别于经济上不合理。如把水和酒精混合起来	
加工	是指对他人之物加以制作或者改造，使之成为具有更高价值之物。如将他人木板加工为板凳	

《民法典》第 322 条规定，因加工、附合、混合而产生的物的归属，**有约定的，按照约定；**没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予赔偿或者补偿。

3.善意取得

无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：

（1）受让人受让该不动产或者动产时是善意；

（2）以合理的价格转让；

（3）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。

受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。

4.善意取得的适用规则

（1）受让人受让不动产或者动产时，**不知道转让人无处分权，且无重大过失的，**应当认定受让人为善意。真实权利人主张受让人不构成善意的，应当承担举证证明责任。

（2）具有下列情形之一的，**应当认定不动产受让人知道**转让人无处分权：

①登记簿上存在有效的异议登记；

②预告登记有效期内，未经预告登记的权利人同意；

③登记簿上已经记载司法机关或者行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制不动产权利的有关事项；

④受让人知道登记簿上记载的权利主体错误；

⑤受让人知道他人已经依法享有不动产物权。

（3）真实权利人**有证据证明**不动产受让人应当知道转让人无处分权的，应当认定受让人具有重大过失。

（4）受让人受让动产时，交易的对象、场所或者时机等不符合交易习惯的，应当认定受让人具有重大过失。

（5）“受让人受让该不动产或者动产时”，是指依法**完成不动产物权转移登记或者动产交付之时。**

当事人以**简易交付**方式交付动产的，**转让动产民事法律行为生效时**为动产交付之时；当事人以**指示交付**方式交付动产的，转让人与受让人之间有关**转让返还原物请求权的协议生效时**为动产交付之时。

法律对不动产、动产物权的设立另有规定的，应当按照法律规定的时间认定权利人是否为善意。

【提示】占有改定不符合善意取得制度上的交付要求。

（6）“合理的价格”，应当根据转让标的物的性质、数量以及付款方式等具体情况，参考转让时交易地市场价格以及交易习惯等因素综合认定。

（7）转让人将**船舶、航空器和机动车**等交付给受让人的，应当认定符合善意取得的条件。

（8）具有下列情形之一，受让人主张依据《民法典》第 311 条规定取得所有权的，不予支持：

①转让合同被认定无效；

②转让合同被撤销。

（二）所有权的消灭

1.因法律行为而消灭

（1）所有权的**抛弃；**

（2）所有权的出让（如赠与、出卖、互易）。

2.因法律行为以外的法律事实而消灭

（1）作为所有人的自然人**死亡**或法人**终止；**

（2）标的物**灭失；**

（3）判决、强制执行、罚款、没收、纳税等；

（4）添附。如动产因添附于他人的不动产或动产，依法由他人取得动产的所有权，原所有权即消灭。

【高频考点】共有（★★★）

（一）共有物的有关规定

1.共有形态

（1）按份共有。按份共有人对共有的不动产或者动产按照其份额享有所有权。

（2）共同共有。共同共有人对共有的不动产或者动产共同享有所有权。

【注意】共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为按份共有。

2.共有份额

按份共有人对共有的不动产或者动产享有的份额，没有约定或者约定不明确的，按照出资额确定；不能确定出资额的，视为等额享有。

3.处分、重大修缮共有物

处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外（约定→≥2/3 以上份额按份共有人全体共同共有人）。

4.因共有物产生的债权债务

（1）对外：共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外

（2）对内：除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务，共同共有人共同享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿

5.分割共有物

（1）共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，但是共有人有重大理由需要分割的，可以请求分割。

（2）没有约定或者约定不明确的，按份共有人可以随时请求分割，共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割（共同共有关系存续期间，共同共有人原则上无权请求分割共有物请求权，也无优先购买权）。

（3）共有人可以协商确定分割方式。达不成协议，共有的不动产或者动产可以分割且不会因分割减损价值的，应当对实物予以分割；难以分割或者因分割会减损价值的，应当对折价或者拍卖、变卖取得的价款予以分割。

6.设定担保

按份共有人可在其份额上设定担保物权。

（二）按份共有的特别规定

1.共有份额的权利主体因继承、遗赠等原因发生变化时，其他按份共有人主张优先购买的，不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外。

2.“同等条件”，应当综合共有份额的转让价格、价款履行方式及期限等因素确定。

3.优先购买权的行使期间，按份共有人之间有约定的，按照约定处理；没有约定或者约定不明的，按照下列情形确定：

（1）转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行使期间的，以该期间为准。

（2）通知中未载明行使期间，或者载明的期间短于通知送达之日起 15 日的，为 15 日。

（3）转让人未通知的，为其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件之日起 15 日。

（4）转让人未通知，且无法确定其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件的，为共有份额权属转移之日起 6 个月。

4.按份共有人向共有人之外的人转让其份额，其他按份共有人根据法律、司法解释规定，请求按照同等条

件优先购买该共有份额的，应予支持。其他按份共有人的请求具有下列情形之一的，不予支持：

（1）未在约定或法定的期间内主张优先购买，或者虽主张优先购买，但提出减少转让价款、增加转让人负担等实质性变更要求；

（2）以其优先购买权受到侵害为由，仅请求撤销共有份额转让合同或者认定该合同无效。

5.按份共有人之间转让共有份额，其他按份共有人主张依据规定优先购买的，不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外。

6.两个以上其他共有人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。

第四节 担保物权

【高频考点】抵押权（★★★）

一、抵押权的概念

抵押权，是指债权人于**债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，可以对**债务人或者第三人提供的、**不移转占有**的担保财产进行变价处分并**优先受偿的权利。**

在抵押权关系中，提供担保财产的债务人或者第三人为抵押人；享有抵押权的债权人为抵押权人；提供担保的财产为抵押财产或者抵押物，该财产可以是不动产，也可以是动产。

二、抵押权的设立

（一）抵押合同

1.设立抵押权，当事人**应当采用书面形式**订立抵押合同。

2.抵押合同的书面形式，既可以是单独存在的抵押合同，也可以是债权合同中附设的抵押条款。

3.《民法典》规定，抵押权人在债务履行期限届满前，与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的，**只能依法就抵押财产优先受偿。**该规定对抵押合同中“绝押条款”的效力作出了明确限定，即只发生担保物权效力，而不发生抵押财产所有权移转效力。

（二）抵押财产

1.可以抵押的财产包括：

（1）建筑物和其他土地附着物；

（2）建设用地使用权；

（3）海域使用权；

（4）生产设备、原材料、半成品、产品；

（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；

（6）交通运输工具；

（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

抵押人可以将以上所列财产一并抵押。

【提示】“房随地走”或者“地随房走”的特别规定：

①以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未依据法律规定将房、地一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押。

②乡镇、村企业的建设用地使用权不得单独抵押。以乡镇、村企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的建设用地使用权一并抵押。

2.**不得抵押**的财产包括：

（1）土地**所有权；**

（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；

（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

（三）抵押登记

1.采取法定**登记**模式设立抵押权的抵押财产包括：

（1）建筑物和其他土地附着物；

（2）建设用地使用权；

（3）海域使用权；

（4）正在建造的建筑物。

以上述财产抵押的，应当办理抵押登记。**抵押权自登记时设立。**

2.采取自愿登记模式设立抵押权的抵押财产包括：

（1）生产设备、原材料、半成品、产品；

（2）正在建造的船舶、航空器；

（3）交通运输工具；

（4）其他可以抵押的动产。

以上述财产抵押的，登记与否完全自愿。**抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。**

三、抵押权的效力

1.抵押权所担保的债权范围

抵押权是意定担保物权，其担保范围当事人可在抵押合同中明确约定。若无约定，抵押权所担保的债权范围依法应当包括：**主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实行抵押权的费用。**

2.抵押权所及标的物的范围

抵押权及于抵押财产本身及其从物、从权利、孳息；及于抵押财产因加工、附合、混合而形成的添附物；及于抵押财产因侵权行为、保险事故、征收、添附等原因毁损、灭失所获得的赔偿金、补偿金、保险金等代位物。

3.抵押权人的权利

（1）变价处分权。

（2）优先受偿权。

抵押权人就抵押财产卖得的价金，优先于无担保物权的债权人受领清偿。

（3）保全抵押财产价值权。

抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求抵押人停止其行为；抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求恢复抵押财产的价值，或者提供与减少的价值相应的担保。

（4）抵押权的处分权。

①抵押权人可以放弃抵押权或者抵押权的顺位。

②抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响。

③债务人以自己的财产设定抵押，抵押权人放弃该抵押权、抵押权顺位或者变更抵押权的，其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外。

4.抵押人的权利

（1）抵押财产的用益权。

（2）抵押财产的处分权。《民法典》规定，抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。

5.抵押权的优先效力

（1）抵押财产拍卖、变卖所得的价款应当优先清偿抵押权人的债权，清偿后有剩余的，才能清偿债务人的其他债权人的债权。

（2）同一财产向两个以上债权人重复抵押时，抵押权的清偿顺序：

①抵押权**已经登记**的，按照**登记的时间先后**确定清偿顺序；

②抵押权**已经登记的先于未登记的**受偿；

③抵押权**未登记的**，按照**债权比例**清偿。

（3）抵押权相互间优先效力的法律限制（“时间在先，效力优先’规则的例外）：

1）“价款优先权”（也称“购置款超级优先权”）

《民法典》第416条规定，**动产**抵押担保的主债权是**抵押物的价款，**标的物**交付后10日内办理抵押登记**的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

2）《民法典担保制度解释》第57条规定，担保人在设立动产浮动抵押并办理抵押登记后又购入或者以融资租赁方式承租新的动产，下列权利人为担保价款债权或者租金的实现而订立担保合同，并在该动产交付后10日内办理登记，主张其权利优先于在先设立的浮动抵押权的，人民法院应予支持：

①在该动产上设立抵押权或者保留所有权的出卖人；

②为价款支付提供融资而在该动产上设立抵押权的债权人；

③以融资租赁方式出租该动产的出租人。

买受人取得动产但未付清价款或者承租人以融资租赁方式占有租赁物但是未付清全部租金，又以标的物为

他人设立担保物权，上述所列权利人为担保价款债权或者租金的实现而订立担保合同，并在该动产交付后 10 日内办理登记，主张其权利优先于买受人为他人设立的担保物权的，人民法院应予支持。

同一动产上存在多个价款优先权的，人民法院应当按照**登记的时间先后确定清偿顺序。**

6.抵押权的保全效力

（1）抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求抵押人停止其行为。

（2）抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求恢复抵押财产的价值，或者提供与减少的价值相应的担保。

（3）抵押人不恢复抵押财产的价值，也不提供担保的，抵押权人有权请求债务人提前清偿债务。

7.抵押权的物上代位效力

《民法典》规定，担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

8..抵押权的追及效力

抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。可见，抵押权对抵押财产的受让人具有追及效力。

抵押权追及效力的法律限制：

（1）善意取得制度的限制。第三人善意取得抵押财产的，可以阻断抵押权的追及效力。

（2）抵押权未按法定方式公示的限制。未按法定方式公示的抵押权不得对抗善意第三人。《民法典》规定，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

（3）正常经营买受人规则的限制。《民法典》规定，以动产抵押的，**不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人。**

《民法典担保制度解释》第 56 条规定，买受人在出卖人**正常经营活动**中通过支付合理对价取得已被设立担保物权的动产，担保物权人请求就该动产优先受偿的，人民法院**不予支持，**但是有下列情形之一的除外：

①购买商品的数量明显超过一般买受人；

②购买出卖人的生产设备；

③订立买卖合同的目的在于担保出卖人或者第三人履行债务；

④买受人与出卖人存在直接或者间接的控制关系；

⑤买受人应当查询抵押登记而未查询的其他情形。

四、抵押权的消灭原因

1.主债权消灭。

2.抵押权实现。

3.抵押财产因不可归责于任何人的事由而灭失。

4.抵押权人放弃抵押权。

五、特殊抵押

1.最高额抵押

（1）《民法典》规定，为担保债务的履行，债务人或者第三人对**一定期间内将要连续发生的债权**提供担保

财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。

（2）最高额抵押中的最高债权额，是指包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管抵押财产的费用、实现债权或者实现抵押权的费用等在内的全部债权。

（3）最高额抵押的特征

①最高额抵押是限额抵押。最高额抵押权设立时，其所担保的**实际债权额虽不确定，**但**所担保的最高债权额则是确定的。**

②最高额抵押权所担保的债权通常是将来发生的债权。即设定最高额抵押权时，主债合同尚未实际发生。但**经当事人同意，最高额抵押权设立前已经存在的债权，可以转入**最高额抵押担保的债权范围。

③最高额抵押权并不随部分债权的移转而发生移转。即最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，最高额抵押权不得转让。除非当事人另有约定。

（4）最高额抵押所担保的债权得以确定的法定事由

①约定的债权确定期间届满；

②没有约定债权确定期间或者约定不明确，抵押权人或者抵押人自最高额抵押权设立之日起满二年后请求确定债权；

③新的债权不可能发生；

④抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押；

⑤债务人、抵押人被宣告破产或者解散；

⑥法律规定债权确定的其他情形。

2.浮动抵押

《民法典》规定，企业、个体工商户、农业生产经营者可以将**现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，**债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就抵押财产确定时的动产优先受偿。

（1）浮动抵押的特征

①抵押人限于企业、个体工商户、农业生产经营者；

②抵押财产限于生产设备、原材料、半成品、产品等动产；

③抵押财产不固定，可以是现有的也可以是将有的，在抵押权实行前一直处于不断增减变化的浮动状态，直到抵押权实现时才固定下来；

④抵押期间，抵押人对抵押财产的使用、收益及处分不受抵押权的影响。

（2）浮动抵押中抵押财产得以确定的法定事由

①债务履行期限届满，债权未实现；

②抵押人被宣告破产或者解散；

③当事人约定的实现抵押权的情形；

④严重影响债权实现的其他情形。

【高频考点】质权（★★★）

（一）动产质权

1.动产质权的设立

（1）设立质权，当事人应当采用书面形式订立质押合同。

（2）《民法典》第428条规定，质权人在债务履行期限届满前，与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有的，**只能依法就质押财产优先受偿。**该规定对质押合同中“流质条款”的效力作出了明确限定，即只发生担保物权效力，而不发生质押财产所有权移转效力。

（3）出质人与质权人可以协议设立最高额质权。最高额质权除适用动产质权的有关规定外，还可参照适用最高额抵押的有关规定。

（4）质权自出质人**交付**质押财产时设立。此处的“交付”，可以是现实交付，也可以是简易交付、指示交付等作为交付替代的“观念交付”。

（二）权利质权

权利	质权设立
汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单（三票三单一券）	有权利凭证→**交付**时设立 无权利凭证→**登记**时设立
应收账款/**知识**产权/**基**金份额/**股**权 （口诀：**应吃鸡**骨）	**登记**时设立

第五节 占有

【高频考点】占有的效力（★★★）

1.不动产或者动产被占有人占有的，权利人可以请求返还原物及其孳息，但应当支付善意占有人因维护该不动产或者动产支出的必要费用。

2.占有人因使用占有的不动产或者动产，致使该不动产或者动产受到损害的，恶意占有人应当承担赔偿责任。

3.占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起1年内未行使的，该请求权消灭。（该1年为除斥期间）

4.占有的不动产或者动产毁损、灭失，该不动产或者动产的权利人请求赔偿的，占有人应当将因毁损、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等返还给权利人；权利人的损害未得到足够弥补的，恶意占有人还应当赔偿损失。

5.对妨害占有的行为，占有人有权请求排除妨害或者消除危险；因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿。

第九章 债法

第一节 债法总论

【高频考点】债的发生（★★★）

债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

（一）合同

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的双方法律行为。

合同之债的特点：①由双方法律行为引起；②基于双方当事人意思表示一致而成立；③双方当事人意思表示的内容相向；④合同之债属于意定之债，具有任意性。

【注意】合伙合同不同于一般合同。合伙合同由共同法律行为引起，基于多方当事人意思表示一致而成立，且多方当事人意思表示的内容相同。【2023 年新增】

（二）缔约过失

当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方信赖利益损失的，应当承担赔偿责任：

1.假借订立合同，恶意进行磋商；

2.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

3.泄露或者不正当地使用在订立合同过程中知悉的对方的商业秘密或者应当保密的其他信息；

4.有其他违背诚信原则的行为。

（三）单方允诺

1.单方允诺，是指表意人向相对人作出的，为自己设定某种义务，使相对人取得某种权利的意思表示。

【例】悬赏广告：悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完成该行为的人可以请求其支付。

2.单方允诺之债的特点：单方允诺是表意人向不特定相对人发出的要约，相对人践行允诺内容则构成承诺，表意人与相对人之间的债权债务关系于相对人践行允诺内容之时发生。

（四）侵权行为

侵权行为，是指不法侵害他人民事权益造成损害，依法应当承担民事责任的致害行为。被侵权人有权请求侵权人予以赔偿，侵权人也应当向被侵权人进行赔偿，双方因此形成以损害赔偿为主要内容的债权债务关系。

（五）无因管理

1.无因管理的概念

管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管

理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。

管理事务不符合受益人真实意思的，管理人不享有上述规定的权利；但是，受益人的真实意思违反法律或者违背公序良俗的除外。

2.无因管理之债的特点

（1）由管理人的管理行为引起。

（2）管理的手段或措施，可以是事实行为，也可以是法律行为。

（3）属于法定之债。

3.构成要件

（1）管理他人事务；

（2）管理人有为他人利益而管理的意思；

（3）管理人无法定或约定的义务。

4.无因管理的类型

（1）适法（正当）无因管理。

①主观适法的无因管理。

②客观适法的无因管理。

（2）不适法（正当）无因管理。

5.无因管理之债的效力

（1）必要费用偿还请求权。

（2）损失补偿请求权。

（3）负债清偿请求权。

（4）妥善管理义务。

（5）通知义务。

（6）报告和结算义务。

（7）准合同效力转换。

6.不真正无因管理

不真正无因管理，是指或者欠缺无因管理的主观要件，或者欠缺无因管理的客观条件的事务管理行为，亦称“准无因管理”。

包括：

（1）误信管理，指误将他人事务当作自己事务进行管理。

（2）不法管理，指明知是他人事务，却为自己利益而进行管理。

（3）幻想管理，指误将自己事务当作他人事务进行管理。

（六）不当得利

1.不当得利的概念

得利人没有合法根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一

的除外：

（1）为履行道德义务进行的给付；

（2）债务到期之前的清偿；

（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。

2.构成要件

（1）一方取得财产利益

（2）他方受有损失

（3）获得利益与受有损失之间存在因果关系

（4）一方获取利益没有合法根据

3.不当得利的类型

（1）给付不当得利

①因法律行为无效、不成立、被撤销、不被追认而发生的不当得利；

②因合同解除而发生的不当得利；

③因非债清偿而发生的不当得利；

④因合同所附解除条件成就而发生的不当得利；

⑤因合同所附终期届至而发生的不当得利。

（2）非给付不当得利

①受益人的行为，如：税务机关多收税款；

②受损人的行为，如：纳税人多缴税款；

③第三人的行为，如：送报员将甲订的报纸投入乙的报箱；

④自然事件，如：因连降暴雨致鱼塘水位升高，甲鱼塘中的鱼跃入相邻的乙鱼塘中；

⑤法律的直接规定，如：基于添附而发生的不当得利。

4.不当得利之债的效力

（1）受损人的损失利益返还请求权。受损人有权请求得利人返还其所取得的不当利益。

（2）善意得利人的返还义务及其免除。得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，仅返还现存利益。获得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务。

（3）恶意得利人的返还义务和赔偿义务。得利人知道或者应当知道获得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其获得的利益并依法赔偿损失。

（4）第三人的返还义务。得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。

【高频考点】债的效力（★★★）

债的效力，是指债的关系发生后，为了保障债的实现而由法律赋予的强制性作用力。包括债权效力（对债权人的效力）和债务效力（对债务人的效力）。

（一）债权的效力

效力	含义	备注
请求力	债权人依其债权请求债务人履行债务以实现债权的效力	任何债权均需具有
执行力	债务人不履行依给付之诉判决所确定的债务时，债权人可以请求法院通过执行程序强制债务人履行以实现其债权的效力。	只有请求力不足时才需要
保持力	债权人可以永久保持所受领债务人给付的效力	虽不具有请求力与执行力，但仍具有保持力。如诉讼时效届满的债权

不完全债权主要包括：

1.欠缺请求力的债权。

如诉讼时效期间届满且债务人提出时效抗辩的债权。

2.欠缺执行力的债权。

如以债务人提供劳务为给付标的的债权。

（二）债权人受领迟延

含义	（1）债权人对债务人已提出的给付，未受领或者未为给付完成提供必要协助的事实。 （2）受领迟延是债权人对协助义务的违反
构成要件	（1）须有履行上需要债权人协助的债务； （2）须债务人已按债的内容提出给付，使债权人处于可予受领的状态； （3）须债权人未予受领，包括不能受领和拒绝受领两种情况
法律后果	（1）减免债务人的责任； （2）使债权人承受不利益。如债务人注意义务减轻、停止支付利息、孳息返还范围缩小、危险负担转移、费用赔偿产生及债务人可以自行消灭债务等

（三）债务的效力

债务的效力是以给付义务为核心的义务群。

1.给付义务（最主要的义务）

主给付义务与从给付义务	主给付义务：债的关系所固有的、必备的并决定债的关系类型的基本义务。 如交付汽车、交付房屋、付款
	从给付义务：辅助义务，它并不决定债的关系类型。 如交付车的相关文件或者资料
原给付义务与次给付义务	原给付义务：指债原本存在的给付义务。
	次给付义务：指当原给付义务在履行过程中，因特定事由发生变化而产生的义务。 例如，因合同解除而产生的恢复原状的义务

2.附随义务

依债的关系发展情形所发生的对相对人的告知、照顾、保护等义务。例如，旅馆对旅客人身和财产安全的
保障义务。

3.前合同义务

（1）当事人为订立合同而进行接触、磋商阶段所负担的说明、告知、保护、注意等义务。

（2）该义务是法定义务，是缔约过失责任的构成基础。

4.后合同义务

合同之债消灭后，当事人为了维护给付效果或者为了协助相对方终了善后事务所负担的作为或者不作为义务。如受雇人离职后不得泄露雇主的商业秘密。

5.不真正义务

（1）不真正义务是指在债之关系中，为使己方权利或利益完全实现，而由债权人负担的义务或风险。

（2）不真正义务的承担人为债权人。

（3）对不真正义务通常不得请求履行，违反它他也不发生损害赔偿责任，仅使债权人遭受权利减损或丧失的不利益。

【高频考点】债的保全权（★★★）

当责任财产因债务人与第三人的行为发生不当减损，影响债权实现时，为了维持债务人的责任财产并确保债权人的利益，法律赋予债权人的两项特别权利。包括：代位权和撤销权。

（一）债权人的代位权（债务人当为而不为）

1.含义

指债权人为了保全其债权不受影响，而以自己的名义代债务人行使其对第三人权利的权利。

2.构成要件

（1）债务人怠于行使权利；

（2）债权人有保全自己债权的必要；

（3）债权已届履行期。

3.代位权行使

（1）行使方法：必须通过诉讼方式行使。

（2）代位权行使的范围：以债务人的债权额和债权人的债权额为限。

（3）代位行使的权利：以非专属于债务人自身的权利为限。

专属于债务人的财产权利：抚养费、赡养费或者扶养费请求权；人身损害赔偿请求权；劳动报酬请求权，超过债务人及其所扶养家属的生活必须费用的部分除外；请求支付基本养老保险、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生活权利；其他专属于债务人自身的权利。

4.代位权行使的效力

（1）由债务人的相对人直接向债权人履行义务；

（2）债权人接受债务人的相对人履行后，债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权力义务终止；

（3）相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张；

（4）债权人行使代位权的必要费用（如诉讼费、律师费），由债务人负担。

（二）债权人撤销权

1.债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

2.债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

3.撤销权的行使范围以债权人的债权为限

4.债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。

5.除斥期间

（1）撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。

（2）自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

6.债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的，自始没有法律约束力。

【高频考点】债的担保（★★★）

<table>
<tr><td>含义</td><td colspan="3">指以第三人的信用或者债务人或者第三人的特定财产确保债务人履行义务、债权人实现权利的制度。</td></tr>
<tr><td>特征</td><td colspan="3">（1）从属性；
（2）相对独立性；
（3）除当事人另有约定外，主债无效，担保亦无效。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">分类</td><td rowspan="2">（1）</td><td>信用担保</td><td>保证</td></tr>
<tr><td>财产担保</td><td>抵押、质押、留置、定金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（2）</td><td>法定担保</td><td>留置</td></tr>
<tr><td>约定担保</td><td>保证、抵押、质押、定金</td></tr>
</table>

（一）保证

1.保证的概念

（1）含义

指第三人与债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，由第三人按照约定履行债务或者承担连带责任的担保方式。

2.保证合同的成立与范围

（1）保证合同属于单务、无偿、诺成、要式合同、从合同。

（2）保证合同的成立

①债权人与保证人单独订立书面保证合同；

②主债权债务合同中的保证条款；

③保证人在主债权债务合同上以保证人的身份签字或者盖章；

④第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议。

3.不得成为保证人的情形：

（1）机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

（2）以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

4.保证的特征

（1）从属性。

保证合同是所担保的主债权债务合同的从合同。

主债权债务合同无效，保证合同亦无效。

主合同	担保合同	债权人	保证人	责任承担
有效	无效	有过错	无过错	保证人不承担赔偿责任
		无过错	有过错	保证人对债务人不能清偿的部分承担责任
		有过错	有过错	保证人承担不超过债务人不能清偿部分的 1/2
无效	无效	--	有过错	保证人承担不超过债务人不能清偿部分的 1/3
		--	无过错	保证人不承担责任

（2）补充性。保证人仅在债务人不履行到期债务的情况下，方才承担保证责任。

（3）独立性。保证合同虽附从于主债权债务合同，但并非主债权债务合同的一部分，而是一个独立的债。

5.保证的方式

	内容	不能行使先诉抗辩权的情形
一般保证	保证人享有先诉抗辩权。债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任	①债务人下落不明，且无财产可供执行； ②人民法院已经受理债务人破产案件； ③债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力； ④保证人书面表示放弃先诉抗辩权。
连带保证	当事人在合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证	
【注意】 当事人对保证责任没有约定或约定不明确时，视为一般责任保证。		

6.保证期间

（1）保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。（保证期间系不变期间，不

是诉讼时效）

（2）债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。

（3）债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。

（4）一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。

（5）连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。

7.保证期间与诉讼时效

一般保证的债权人在保证期间届满前，对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。

连带责任保证的债权人在保证期间届满前，请求保证人承担保证责任的，从债权人请求保证人承担保证责任之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。

8.主债权债务合同变更对保证责任的影响

（1）债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。

（2）保证人与债权人约定禁止债权转让，债权人未经保证人书面同意转让债权的，保证人对受让人不再承担保证责任。

（3）债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任，但是债权人和保证人另有约定的除外。

（4）第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。

（二）定金

1.定金的含义	（1）合同的一方为确保合同的履行而预先向他方交付的金钱或其他替代物。 （2）定金合同是实践合同，定金合同自交付定金之日起生效。 （3）定金的数额可由当事人约定，但超过合同标的额 20%的，超过部分法院不予支持。

2.定金与预付款

	定金	预付款
作用	预先支付性＋担保作用	单纯的预付款不起担保作用
成立要件 / 履行	交付定金是成立定金合同的要件	交付预付款是合同履行的一部分
是否适用定金罚则	适用	不适用
适用合同	不仅适用金钱履行义务的合同,还适用其他合同	只能适用以金钱履行义务的合同
交付	一次性交付	可以分期交付

3.定金与违约金

	定金	违约金
给付时间	订立合同之时 / 订立合同后未履行前	违约时支付
功能不同	有证约和预先给付作用	没有证约和预先给付作用
作用不同	主要是担保作用	反映的是合同的责任
数额限制	不超过主合同标的额的 20%，超过部分无定金罚则作用	没有类似限制
特别注意	二者不能同时并用，只能二者选其一	

【高频考点】债的移转（★★★）

债的转移，是指在不改变债的内容或者客体的前提下，债的主体发生的变更。

债的转移方式：

①概括承受，债权和债务作为财产的整体而一并转移，如继承、法人合并。

②特定承受，特定债权或债务的单独转移，如债权让与、债务承担。

（一）债权让与

1.成立要件

（1）须存在有效债权；

（2）须让与人对被让与的债权享有处分权；

（3）须被让与的债权具有可转让性；

（4）法律、行政法规规定债权让与合同应当办理批准、登记等手续才能生效的，当事人须办理相应的手续。

2.不得让与的债权

（1）根据合同性质不得转让的债权。例如，基于当事人之间的特别信赖关系产生的债权、以债务人不作为为内容的债权。

（2）按照当事人约定不得转让的债权。

（3）依照法律规定不得转让的债权。

【注意】债权让与不需征得债务人的同意，只需通知债务人而已。

（二）债务承担

1.债务承担合同的生效要件

（1）须存在有效的债务；

（2）须债务具有可移转性；

（3）须经债权人同意（限债务人与承担人签订的债务承担合同）；——效力待定的行为

（4）法律、行政法规规定债务承担合同应当办理批准、登记等手续才能生效的，当事人须办理相应的手续。

2.不得转移的债务

（1）根据合同性质不得移转的债务。

（2）按照当事人约定不得移转的债务。

（3）依照法律规定不得转移的债务。例如，《民法典》第 791 条规定：“建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”

【高频考点】债的消灭（★★★）

债的关系在客观上不复存在，即为债的消灭。引起债消灭的法律原因很多，最主要的有：清偿、抵销、提存、免除、混同和解除。

（一）清偿

1.清偿人。

（1）债务人、债务人的代理人、第三人（该第三人仅为清偿人，不具有债务人身份）。

（2）基于法律规定或者合同约定，清偿可以由第三人进行；若第三人的清偿能使债权人得到满足，且对债权人并无不利时，第三人的清偿应为有效，债权人无正当理由不得拒绝。

（3）《民法典》第 523 条：当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任。

（4）《民法典》第 524 条：债务人不履行债务，第三人对履行该债务具有合法利益的，第三人有权向债权人代为履行；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外。

债权人接受第三人履行后，其对债务人的债权转让给第三人，但是债务人和第三人另有约定的除外。

2.受领清偿人。

（1）包括债权人、债权人的代理人、债权受领证书的持有人和第三人。

（2）《民法典》第 522 条：当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。

法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，第三人可以请求债务人承担违约责任；债务人对债权人的抗辩，可以向第三人主张。

3.清偿标的。

债务人原则上应以债的原定给付为全部清偿以满足债权，不得以他种给付代替；但债务人若以他种给付代替原定给付为清偿，并经债权人同意的，也可以发生债之清偿的效力。

4.清偿地。

清偿地可由双方合意选择确定，也可依给付的性质确定；若双方没有约定或者约定不明确的：

（1）给付货币的，在接受货币一方所在地履行；

（2）交付不动产的，在不动产所在地履行；

（3）其他给付，在履行义务一方所在地履行。

5.清偿期。

当事人有约定的，从其约定；

当事人未约定或者约定不明确的：债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必

要的准备时间。

6.清偿费用。

除法律有特别规定或者当事人有特别约定外，清偿费用由债务人承担；但因债权人原因增加的清偿费用，由债权人承担。

（二）抵销

1.法定抵销

（1）当事人互负债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外。

（2）当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。

2.合意抵销

当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经协商一致，也可以抵销

（三）提存

1.提存情形

有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：

（1）债权人无正当理由拒绝受领；

（2）债权人下落不明；

（3）债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人；

（4）法律规定的其他情形。

【注意】标的物不适于提存或提存费用过高的，债务人依法可以拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。

2.成立。债务人将标的物或者将标的物依法拍卖、变卖所得价款交付提存部门时，提存成立。

3.提存效力

（1）自提存成立之日起，债权人和债务人之间的债权债务关系即归于消灭。

（2）提存物的所有权自提存成立之时起移转于债权人。

（3）提存物在提存期间所产生的孳息归债权人所有。

（4）提存物在提存期间毁损、灭失的风险由债权人承担。

（5）提存费用由债权人负担。

（6）债权人可以随时领取提存物。《民法典》第574条规定，债权人领取提存物的权利自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

（7）提存期间，债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。

（8）提存期间，债权人未履行对债务人的到期债务，或者债权人向提存部门书面表示放弃领取提存物权利的，债务人负担提存费用后有权取回提存物。

（四）免除

1.免除，是指债权人放弃债权的法律行为。免除可以附条件、附期限。

2.债权人免除债务人部分或者全部债务的，债权债务部分或者全部终止，但是债务人在合理期限内拒绝的除外。

（五）混同

1.混同，是指债权和债务同归于一人的事实。

如：企业合并、继承、债权债务的概括承受等。

2.债权和债务同归于一人的，债权债务终止，但是损害第三人利益的除外。

第二节 合同法

【高频考点】合同的订立（★★★）

合同的订立，从法律上可分为要约与承诺两个阶段。

（一）要约

1.概念与构成要件

定义	要约是希望和他人订立合同的意思表示
要约的要求	（1）内容具体确定； （2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
要约邀请	（1）是希望他人向自己发出要约的意思表示。 （2）拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请

2.要约的法律效力

（1）要约的生效时间

要约到达受要约人时生效。

以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。

以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。

（2）要约的拘束力

要约的效力	对要约人的拘束力	要约一经生效，要约人就不得随意撤销或变更要约
	对受要约人的拘束力	受要约人取得依承诺而成立合同的权利

3.要约的撤回与撤销

撤回	（1）指要约人对尚未生效的要约所作的阻止其发生法律效力的意思表示。 （2）撤回通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。
撤销	（1）指要约人在要约生效后获承诺前所作的消灭要约法律效力的意思表示。

	（2）撤销要约的意思表示以对话方式作出的，该意思表示的内容应当在受要约人作出承诺之前为受要约人所知道。 （3）撤销要约的意思表示以非对话方式作出的，应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人。 （4）要约不得撤销： ①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销； ②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

4.要约的失效

（1）要约被拒绝；

（2）要约被依法撤销；

（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；

（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。

【注意】实质性变更包括：有关合同的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议的方法。

（二）承诺

1.概念及构成要件

（1）承诺必须由受要约人作出。

（2）承诺的内容应当与要约的内容一致。

（3）承诺必须是在有效期内到达要约人。

2.承诺的迟到和延迟

迟到	（1）指承诺在承诺期限届满后才发出承诺（承诺人的原因导致）。 （2）原则上为新要约。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效
迟延	（1）指因承诺人以外的原因，导致本应在承诺期限内到达的承诺，在承诺期限届满后才到达要约人。 （2）原则上该承诺有效。除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺。

3.承诺的方式及生效

承诺的方式	（1）应当以通知的方式作出； （2）根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出的，可以行为作出。
生效及效力	承诺通知到达要约人=承诺生效=合同成立

【高频考点】双务合同履行中的抗辩权（★★★）

（一）同时履行抗辩权

1.当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。

一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。

一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

2.同时履行抗辩权的成立条件：

（1）须双方债务基于同一合同而发生且未约定履行先后顺序；

（2）须双方互负的债务均已届清偿期

（3）须相对人有不履行或履行不符合约定的行为

（4）须合同具备能履行的客观条件

（二）后履行抗辩权

1.当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

2.后履行抗辩权的成立条件：

（1）双方当事人因同一合同互负债务

（2）两个债务之间存在先后履行顺序

（3）先履行一方未履行或其履行不符合约定

（三）不安抗辩权

1.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

（1）经营状况严重恶化；

（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

（3）丧失商业信誉；

（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

2.不安抗辩权的成立条件：

（1）须双方当事人因同一双务合同互负债务，且互负债务有先后履行顺序；

（2）须先履行债务人有确切证据证明后履行债务人发生了丧失或可能丧失履行债务能力的情形。

3.不安抗辩权行使的效力：

（1）当事人依据前条规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行；

（2）中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任；

（3）当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

【高频考点】合同的变更与解除（★★★）

（一）合同的变更

合同的变更，是指在主体保持不变的情况下，当事人对合同内容所作的修改或补充。如标的物数量的少量增减、履行地点的改变、履行期限的顺延等。

合同变更的原因包括：①当事人双方合意；②法律规定；③法院、仲裁机构的裁决；④当事人一方依约行

使变更权。

（二）合同的解除

1.约定解除

（1）双方约定解除：当事人协商一致，可以解除合同。

（2）单方约定解除：当事人可以约定一方解除合同的事由。

解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。

2.法定解除

（1）法定解除的情形

①因不可抗力致使不能实现合同目的；

②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

⑤法律规定的其他情形。

（2）解除的法律效力

①尚未履行的，终止履行；

②已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

【高频考点】典型合同（★★★）

（一）买卖合同

1.双方当事人的义务

（1）出卖人的义务

①交付标的物并转移标的物所有权

②单证、资料的交付

出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料（主要应当包括保险单、保修单、普通发票、增值税专用发票、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明书、使用说明书、装箱单等）。

【注意】出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。

③瑕疵担保义务

包括品质瑕疵担保义务和权利瑕疵担保义务。

1）品质瑕疵担保，是指出卖人就其所交付的标的物应保证其符合法定或约定的品质。即标的物交付于买受人之后，应保证不发生减少其价值和效用的瑕疵。

2)权利瑕疵担保，是指出卖人就移转的标的物负有保证不受他人追夺以及不存在未告知的权利负担的义务。

（2）买受人的义务

①支付价款

付方式、时间、地点支付价款。

②受领标的物

对于出卖人交付的标的物及有关权利凭证，买受人应及时受领。否则将负受领迟延的责任。

③对标的物的检验、通知和保管义务

买受人受领标的物后，应在法定或者约定的期限内及时检验标的物。如发现存在应由出卖人负担责任的瑕疵时，应立即通知出卖人并妥善保管标的物。

2.风险负担、孳息归属、特别解除规则

（1）标的物的风险负担

风险负担，是指买卖合同订立后，对标的物因不可归责于双方当事人的事由而发生毁损、灭失的损失的承担。

①一般规则：风险随标的物的交付而转移

标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。

②买受人承担

1）因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。

2）出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

3）出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

4）出卖人按照约定或者依据规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。

③出卖人承担

因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

（2）孳息

标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。但当事人另有约定的除外。

（3）买卖合同的特别解除

①主从物

因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。

②标的物为数物

标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受

损害的，买受人可以就数物解除合同。

③分批交付

1）出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。

2）出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除。

3）买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除。

（二）赠与合同

1.合同性质

赠与合同是诺成合同、单务合同、无偿合同、不要式合同，但订立赠与合同属于双方法律行为。

2.赠与人的瑕疵担保责任

（1）一般情形：赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。

（2）特殊情形：

①附义务的赠与：赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。

②赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担赔偿责任。

3.赠与人的穷困抗辩权

赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务。

4.任意撤销和法定撤销

权利	行使时间	适用情形 / 例外情形
（1）赠与人的任意撤销权	在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与	【例外】具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同不得撤销
（2）赠与人的法定撤销权（履行前＋履行后）	自知道或者应当知道撤销原因之日起 1 年内行使	①严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属； ②对赠与人有扶养（抚养、赡养）义务而不履行； ③不履行赠与合同约定的义务
（3）赠与人的继承人或者法定代理人的撤销权	自知道或者应当知道撤销原因之日起 6 个月内行使	因受赠人的违法行为致使赠与人死亡或者丧失民事行为能力
（4）赠与财产返还请求权	撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人要求返还赠与的财产	
（5）赠与人的穷困抗辩权	赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务	

（三）借款合同

1.概念及特征

商业借贷	概念	由商业银行或国家认可的其他金融机构作为贷款人的借款合同
	特征	诺成、要式、有偿合同
民间借贷	概念	指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为
	特征	践成或者诺成、不要式合同，可有偿也可无偿

2.民间借贷的利息和利率

（1）借贷双方没有约定利息的，视为没有利息。

（2）自然人之间借贷对利息约定不明的，视为没有利息。自然人之间借贷之外的民间借贷对利息约定不明的，人民法院应当结合民间借贷合同的内容，并根据当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素确定利息。

（3）禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。

借贷双方约定的利率超过合同成立一年期贷款市场报价利率 4 倍的，人民法院不予支持。

（4）借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

3.民间借贷合同无效的情形

（1）套取金融机构贷款转贷的；

（2）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；

（3）未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的；

（4）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；

（5）违反法律、行政法规强制性规定的；

（6）违背公序良俗的。

（四）租赁合同

1.租赁期限及合同形式

类型	法律规定	法律后果
定期租赁	租赁期限不得超过 20 年	超过 20 年的，超过部分无效。 可续订，续订也不得超过 20 年
	租赁期限 6 个月以上的，应采用书面形式	未采用书面形式的，视为不定期租赁
不定期租赁	（1）当事人没有约定租赁期限； （2）定期合同期限届满，续用未续租的； （3）租赁期限 6 个月以上，未采用书面形式的	当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人

2.当事人的义务与权利

义务	出租人	（1）交付租赁物，保持租物的适用性； （2）瑕疵担保责任；

		（3）维修租赁物的义务； （4）维修费用的偿还义务和租金减免的义务。 （5）返还押金的义务
	承租人	（1）支付租金； （2）按照约定使用租赁物； （3）妥善保管租赁物； （4）有关事项通知； （5）返还租赁物
承租人的权利	（1）租赁物的使用收益权。 （2）经出租人同意改善租赁物的权利。 （3）经出租人同意转租的权利。 （4）租金减少请求权。 （5）房屋承租人的优先购买权。 （6）房屋承租人的优先承租权。 【注意】房屋承租人不得行使优先购买权： ①房屋共有人行使优先购买权的； ②出租人将房屋出卖给近亲属的； ③出租人履行告知后，承租人在 15 日内未明确表示愿意购买的； ④购买房屋的第三人出于善意并已办理登记手续的。	
承租人的解除权	①租赁物非因承租人原因被司法机关或者行政机关依法查封、扣押，致使租赁物无法使用的； ②租赁物非因承租人原因发生权属争议，致使租赁物无法使用的； ③租赁物具有违反法律、行政法规关于使用条件的强制性规定情形且不可归责于承租人，致使租赁物无法使用的； ④因不可归责于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失，且不能实现合同目的的。 【注意】承租人可以随时解除租赁合同： ①租赁合同为不定期租赁合同或者视为不定期租赁合同的； ②租赁物危及承租人的安全或者健康的。	

（五）融资租赁合同

1.概念

出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。

2.特征

诺成、双务、有偿、要式合同

3.形式

融资租赁合同应当采用书面形式

4.标的物交付

出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。

5.不得擅自变更

出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

6.索赔

出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的，出租人应当协助。

7.所有权

出租人对租赁物享有的所有权，未经登记，不得对抗善意第三人

8.瑕疵担保

租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任。但是，承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。

9.保管、使用、维修

承租人应当妥善保管、使用租赁物；承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

10.租金

承租人应当按照约定支付租金。承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以请求支付全部租金；也可以解除合同，收回租赁物。

11.期限届满租赁物归属

出租人和承租人可以约定租赁期限届满租赁物的归属；对租赁物的归属没有约定或者约定不明确，依据《民法典》规定仍不能确定的，租赁物的所有权归出租人。

（六）保理合同

1.概念

应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账款债务人付款担保等服务的合同。

2.特征

诺成、要式、双务、有偿合同

【注意】保理合同是由债权让与和融资、债权管理、债权催收或者付款担保等服务结合而成的复合合同

3.形式

保理合同应当采用书面形式

4.通知

保理人向应收账款债务人发出应收账款转让通知的，应当表明保理人身份并附有必要凭证。

5.有追索权保理

当事人约定有追索权保理的，保理人可以向应收账款债权人主张返还保理融资款本息或者回购应收账款债权，也可以向应收账款债务人主张应收账款债权。保理人向应收账款债务人主张应收账款债权，在扣除保理融资款本息和相关费用后有剩余的，剩余部分应当返还给应收账款债权人。

6.无追索权保理

当事人约定无追索权保理的，保理人应当向应收账款债务人主张应收账款债权，保理人取得超过保理融资款本息和相关费用的部分，无须向应收账款债权人返还。

7.多个保理

应收账款债权人就同一应收账款订立多个保理合同，致使多个保理人主张权利：

（1）已经登记的先于未登记的取得应收账款

（2）均已经登记的，按照登记时间的先后顺序取得应收账款

（3）均未登记的，由最先到达应收账款债务人的转让通知中载明的保理人取得应收账款

（4）既未登记也未通知的，按照保理融资款或者服务报酬的比例取得应收账款

（七）承揽合同

1.概念

承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。

2.特征

诺成、有偿、双务合同，其形式依法律规定或者约定，即可要式亦可不要式。

3.加工工作

（1）承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但是当事人另有约定的除外

（2）承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同

【注意】承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。

4.材料提供

承揽人提供材料的，应当按照约定选用材料，并接受定作人检验

（1）定作人提供材料的，应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施

（2）承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件

5.通知

承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

6.变更

定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

7.留置

定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付，但是当事人另有约定的除外。

8.保管

承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

9.共同承揽

共同承揽人对定作人承担连带责任，但是当事人另有约定的除外。

10.随时解除权

定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

（八）建设工程合同

概念	承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
特征	诺成、双务、有偿、要式合同
形式	建设工程合同应当采用书面形式
招标	（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 （2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 （3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
主体结构	建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
分包	总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任
禁止	发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人
	承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人
	禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位
	禁止分包单位将其承包的工程再分包
工程价款优先受偿权	发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

（九）运输合同

从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。

2.特征

（1）运输合同的客体是承运人的运送行为；

（2）是双务、有偿合同；

（3）客运合同可为诺成合同或者践成合同，生活中以交易惯例确定；货运合同通常为诺成合同。

（4）多为定型化合同。

3.货运合同主要规则

（1）托运人的任意变更、解除权。在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。

（2）承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担赔偿责任。

（3）货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。法律另有规定的，依照其规定。

（4）托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。

（5）收货人不明或者收货人无正当理由拒绝受领货物的，承运人可以提存货物。

（十）保管合同

1.特征

（1）是践成合同；

（2）客体是保管行为；

（3）既可有偿，也可无偿；

（4）是不要式合同、继续性合同

2.保管人的责任

因保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任；但是，无偿保管中，保管人证明自己没有故意或重大过失的，不承担损害赔偿责任。

3.保管人的留置权

寄存人未按照约定支付保管费以及其他费用的，保管人对保管物享有留置权，但当事人另有约定的除外。

（十一）物业服务合同

1.特征

（1）物业服务合同主体具有特殊性。物业服务合同的当事人为业主和物业服务人。

（2）物业服务合同是以劳务给付为客体的合同。

（3）物业服务合同的服务内容具有综合性和专业性。

双务、要式、继续性合同。

2.物业服务合同的类型

划分标准	类型	含义
根据物业服务提供的时间	前期物业服务合同	是在物业销售前，由建设单位依法与物业服务人签订的合同
	普通物业服务合同	是在建设单位销售并交付的物业达到一定数量时，依法成立业主委员会，由业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务人签订的合同
根据物业的性质	居住性物业服务合同	
	经营性物业服务合同	

3.物业服务人的权利和义务

（1）对物业实施管理的权利；

（2）收取物业费的权利；业主不支付物业费的，物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁，但不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费；

（3）将物业服务区域内的部分专项服务事项委托给专业性服务组织或者其他第三人的权利；

（4）亲自提供物业服务义务。物业服务人不得将全部物业服务转委托给第三人或将全部物业服务支解后分别转委托给第三人；

（5）妥善提供物业服务义务；

（6）报告义务；

（7）后合同义务。

①物业服务合同终止后，在新物业服务人或决定自行管理的业主接管之前，原物业服务人应当继续处理物业服务事项，并可以请求业主支付该期间的物业费。

②物业服务合同终止的，原物业服务人应当在约定期限或者合理期限内退出物业服务区域，将相关资料交还给业主委员会、决定自行管理的业主或者其指定的人，配合新物业服务人做好交接工作，并如实告知物业的使用和管理状况。

（8）有权随时解除不定期物业服务合同，但是应当提前 60 日书面通知对方。

4.业主的权利和义务

（1）选择物业服务人的权利。

（2）与物业服务人签订物业服务合同的权利。

（3）监督物业服务人的服务的权利。

（4）支付物业费义务。

（5）告知义务。业主装饰装修房屋、转让、出租物业专有部分、设立居住权或者依法改变共有部分用途的，

应当告知物业服务人。

（6）有权随时解除不定期物业服务合同，但是应当提前 60 日书面通知对方。

（十二）行纪合同

1.行纪合同的概念和特征

行纪合同，是指行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的合同。

（1）行纪人应具有从事行纪业务的资格。

（2）行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动。

行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务。第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担赔偿责任，但行纪人与委托人另有约定的除外。

（3）行纪合同是双务、有偿、诺成、不要式合同。

（4）行纪合同的客体是行纪人为委托人从事的买入、卖出等商事法律行为。

没有依照委托人制定价格买卖	（1）行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意；未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力 （2）行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬；没有约定或者约定不明确，依据民法典的规定仍不能确定的，该利益属于委托人
介入权	行纪人卖出或者买入具有市场定价的商品，除委托人有相反的意思表示外，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人；行纪人有前述情形的，仍然可以请求委托人支付报酬
及时受领、取回、处分、提存	（1）行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人依法可以提存委托物 （2）委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不处分该物的，行纪人依法可以提存委托物
报酬	行纪人完成或者部分完成委托事务的，委托人应当向其支付相应的报酬

（十三）中介合同

概念	中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同
特征	双务、有偿、诺成、不要式合同
中介人义务	（1）中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告 （2）中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任
报酬请求权	（1）中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。对中介人的报酬没有约定或者约定不明确，依据《民法典》规定仍不能确定的，根据中介人的劳务合理确定。因中

	介人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的，由该合同的当事人平均负担中介人的报酬 （2）中介人促成合同成立的，中介活动的费用，由中介人负担
必要 费用 请求权	中介人未促成合同成立的，不得请求支付报酬；但是，可以按照约定请求委托人支付从事中介活动支出的必要费用（此处支付必要费用的前提是中介合同中存在“相关约定”）

（十四）合伙合同

概念	2 个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议
合伙人	合伙人可以是自然人、法人或者非法人组织。合伙人是自然人的，应具有完全民事行为能力
特征	诺成、不要式、继续性合同
出资	合伙人应当按照约定的出资方式、数额和缴付期限，履行出资义务
合伙 财产	（1）合伙人的出资、因合伙事务依法取得的收益和其他财产，属于合伙财产 （2）合伙合同终止前，合伙人不得请求分割合伙财产
合伙事务	决定：合伙人就合伙事务作出决定的，除合伙合同另有约定外，应当经全体合伙人一致同意 合伙事务的执行： （1）合伙事务由全体合伙人共同执行。按照合伙合同的约定或者全体合伙人的决定，可以委托一个或者数个合伙人执行合伙事务；其他合伙人不再执行合伙事务，但是有权监督执行情况 （2）合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议；提出异议后，其他合伙人应当暂停该项事务的执行
损益分配	合伙的利润分配和亏损分担，按照合伙合同的约定办理；合伙合同没有约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担
债务承担	对外：合伙人对合伙债务承担连带责任 对内：清偿合伙债务超过自己应当承担份额的合伙人，有权向其他合伙人追偿
对外转让	除合伙合同另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其全部或者部分财产份额的，须经其他合伙人一致同意
合伙期限	除合伙合同另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其全部或者部分财产份额的，须经其他合伙人一致同意
合伙合同终止	合同期届满；合伙人死亡、丧失民事行为能力或者终止的，合伙合同终止；但是，合伙合

	同另有约定或者根据合伙事务的性质不宜终止的除外；合伙人解除合伙合同

第三节 侵权责任法

【高频考点】侵权责任的归责原则（★★★）

1.过错责任原则

行为人因**过错**侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。

（1）过错责任原则，以过错作为归责的依据或者标准。**无过错即无责任。**

（2）行为人因其过错而担责，其过错须由**被侵权人举证证明。**

（3）**除法律另有规定外，**侵权行为**均适用过错责任原则**予以归责。

2.过错推定责任原则

依照**法律规定推定行为人**有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

（1）损害发生后，**行为人须证明自己没有过错**方能免责，否则，法律即推定行为人有过错并确定行为人须对损害承担赔偿责任。

（2）过错推定责任原则**仍属于过错责任原则**范畴。

3.无过错责任原则

行为人造成他人民事权益损害，**不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，**依照其规定。

【高频考点】侵权责任的构成要件（★★★）

归责原则	构成要件
过错责任原则	①损害； ①加害行为违法； ②加害行为与损害之间存在因果关系； ③行为人的过错
推定过错责任原则	
无过错责任原则	①损害； ②加害行为违法； ③加害行为与损害之间的因果关系

（一）损害

1.损害是侵害民事权益行为所造成的**不利后果。**

2.具体体现为被侵权人的死亡、人身伤害、社会评价降低、精神痛苦、疼痛以及各种形式的财产损失。

3.在侵权责任的认定中，损害应当由被侵权人予以举证和证明。

（二）加害行为违法

1.加害行为**违法，**是指加害行为**违反法律规定的义务、违反公序良俗、违反在特定环境条件下加害人依常识或者诚信原则**所应当承担的义务。

2.违法性阻却事由主要包括：①依法执行职务；②正当防卫；③紧急避险；④自助行为；⑤权利行使行为；

⑥受害人同意；⑦紧急救助；⑧自甘冒险。加害行为具有上述违法性阻却事由即不构成侵权。

（三）过错

过错，是指加害人于行为之际主观上具有的可归责的**心理状态**，包括故意和过失。

（1）**故意**，是指行为人**预见到**损害后果的发生并**希望**或者**放任**该结果发生的心理状态。

（2）**过失**，是指行为人对自己行为的致害后果**应当预见**或者**能够预见**却因**疏忽**而**没有预见**，或者**虽然预见到**自己行为的致害后果却**轻信能够避免**的心理状态。

（四）因果关系

侵权责任法中的因果关系，是指**加害行为**与**损害事实**之间**前者引起后者**的这种**引起与被引起**的客观联系。

【高频考点】免责和减轻责任事由（★★★）

1.“依法”执行职务（如依法拆除违章建筑）

2.正当防卫

（1）为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，属于正当防卫。

（2）因正当防卫造成损害的，不承担民事责任；但正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫人应当承担适当的民事责任。

3.紧急避险

（1）为了使本人或者第三人的人身、财产或者公共利益免遭正在发生的、实际存在的危险而不得已采取的一种加害他人的致害行为，称为紧急避险。

（2）因紧急避险造成损害的，由“引起险情发生的人”承担民事责任；如果危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当的补偿；紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的损害的，紧急避险人应当承担适当的民事责任。

4.紧急救助

因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。

5.自甘冒险

自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。

6.自助行为

（1）合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。

（2）受害人采取的措施不当造成他人损害的，应当承担侵权责任。

7.受害人过错

（1）被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。

（2）损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。

8.受害人故意

损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。

9.第三人过错

损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。

10.不可抗力

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任；

法律另有规定的，依照其规定。

【高频考点】法律特别规定的侵权责任类型（★★★）

（一）数人侵权

1.教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。

2.教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任；

【注意】该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护责任的，应当承担相应的责任。

3.二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。

（二）特殊主体责任

1.监护人责任（无过错责任的归责原则）

（1）无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。同时法律规定，监护人尽到监护责任的，可以减轻其侵权责任。

（2）有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用。不足部分，由监护人赔偿。

2.意识暂时丧失人侵权

（1）完全民事行为能力人对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害有过错的，应当承担侵权责任；没有过错的，根据行为人的经济状况对受害人进行适当补偿。

（2）完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的，应当承担侵权责任。

3.雇主责任

（1）用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。

（2）劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。

（3）个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。

接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。

（4）提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任，也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后，可以向第三人追偿。

4.网络用户、网络服务提供者责任（过错责任）

（1）网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依
照其规定。

（2）网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

（3）网络服务提供者知道或应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

5.安全保障义务人责任

（1）宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任（过错责任）。

（2）因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任（过错责任）；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。

6.教育机构责任

（1）内部侵权

①过错推定责任：“无民事行为能力人”在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任，但是能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任。

②过错责任：“限制民事行为能力人”在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担侵权责任。

（2）外部侵权

过错责任（补充责任）：无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其他教育机构以外的第三人人身损害的，由第三人承担侵权责任；幼儿园、学校或者其他教育机构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任。幼儿园、学校或者其他教育机构承担补充责任后，可以向第三人追偿。

（三）危险活动及物件致害责任

1.产品责任（无过错责任原则）

（1）生产者责任

因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。

（2）因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求生产者、销售者承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。

（3）产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。

（4）惩罚性赔偿。明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依法采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

2.医疗损害责任

（1）诊疗活动（过错责任原则）

患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。

【注意】诊疗活动的判断标准：医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。

（2）必要的说明义务

医务人员在诊疗活动中对患者或者其近亲属未尽到必要的说明义务，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。

（3）医疗产品责任（无过错责任原则）

因药品、消毒产品、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液造成患者损害的，患者可以向药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。

（4）患者隐私和个人信息（过错责任原则）

医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私和个人信息保密。泄露患者的隐私和个人信息，或者未经患者同意公开其病历资料的，应当承担侵权责任。

3.环境污染和生态破坏责任（无过错责任原则）

（1）因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。

（2）侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

（3）因第三人的过错污染环境、破坏生态的，被侵权人可以向侵权人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。侵权人赔偿后，有权向第三人追偿。

4.高度危险责任

【注意】作业人适用无过错责任原则，作业人与所有人、管理人不一致时，对作业人仍采用无过错责任原则，对所有人、管理人应根据规定具体确定。

（1）高度危险作业

①民用核设施或者运入运出核设施的核材料发生核事故造成他人损害的，民用核设施的营运单位应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因战争、武装冲突、暴乱等情形或者受害人故意造成的，不承担责任。

②民用航空器造成他人损害的，民用航空器的经营者应当承担侵权责任，但能够证明损害是因受害人故意造成的，不承担责任。

③从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任，但能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任。被侵权人对损害的发生有重大过失的，可以减轻经营者的责任。

（2）高度危险物

①占有或者使用易燃、易爆、剧毒、高放射性、强腐蚀性、高致病性等高度危险物造成他人损害的，占有

人或者使用人应当承担侵权责任；但能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任；被侵权人对损害的发生有重大过失的，可以减轻占有人或者使用人的责任。

②遗失、抛弃高度危险物造成他人损害的，由所有人承担侵权责任（无过错责任）。

所有人将高度危险物交由他人管理的，由管理人承担侵权责任；

所有人有过错的，与管理人承担连带责任（管理人：无过错责任；所有人：无过错责任）。

③非法占有高度危险物造成他人损害的，由非法占有人承担侵权责任（无过错责任）。所有人、管理人不能证明对防止非法占有尽到高度注意义务的，与非法占有人承担连带责任（过错推定）。

（3）未经许可进入高度危险活动区域或者高度危险物存放区域受到损害，管理人能够证明已经采取足够安全措施并尽到充分警示义务的，可以减轻或不承担责任。

5.饲养动物损害责任（无过错责任）

（1）饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任，但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

（2）违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。

（3）禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。

（4）动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任；但是，能够证明尽到管理职责的，不承担侵权责任。（过错推定责任）

（5）遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由动物原饲养人或者管理人承担侵权责任。

（6）因第三人的过错致使动物造成他人损害的，被侵权人可以向动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。动物饲养人或者管理人赔偿后，有权向第三人追偿。

6.建筑物和物件损害责任

（1）脱落、坠落：建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任（过错推定责任）。

（2）倒塌、塌陷：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。（过错推定责任）

（3）高空抛物：禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的以外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿（基于公平补偿）。

（4）堆放物：堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任（过错推定责任）。

（5）公共道路妨碍通行：在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的，由行为人承担侵权责任（立法仍未明确）。

公共道路管理人不能证明已经尽到清理、防护、警示等义务的，应当承担相应的责任（过错推定责任）。

（6）林木：因林木折断、倾倒或者果实坠落等造成他人损害，林木的所有人或者管理人不能证明自己没有

过错的，应当承担侵权责任（过错推定责任）。

（7）地面施工：在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，应当承担侵权责任。（过错推定责任）

（8）地下设施：窨井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任（过错推定责任）。

第十章 婚姻家庭与继承法

第一节 婚姻家庭法

【高频考点】结婚制度（★★★）

（一）婚姻

1.结婚的必备条件

（1）结婚应当男女双方完全自愿，禁止任何一方对另一方加以强迫，禁止任何组织或者个人加以干涉。

（2）结婚年龄，男不得早于 22 周岁，女不得早于 20 周岁。

（3）符合一夫一妻制。

2.结婚的程序

要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。符合法律规定的，予以登记，发给结婚证。完成结婚登记，即确立婚姻关系。

（二）婚姻无效

1.有下列情形之一的，婚姻无效：

（1）重婚；

（2）有禁止结婚的亲属关系；

（3）未到法定婚龄。

【注意】我国对无效婚姻采用宣告无效主义，只有人民法院有权宣告婚姻无效。

2.有权依据民法典规定向人民法院就已办理结婚登记的婚姻请求确认婚姻无效的主体，包括婚姻当事人及利害关系人。其中，利害关系人包括：

（1）以重婚为由的，为当事人的近亲属及基层组织；

（2）以未到法定婚龄为由的，为未到法定婚龄者的近亲属；

（3）以有禁止结婚的亲属关系为由的，为当事人的近亲属。

3.对婚姻效力的审理不适用调解，应当依法作出判决。涉及财产分割和子女抚养的，可以调解。调解达成协议的，另行制作调解书；未达成调解协议的，应当一并作出判决。

4.人民法院受理离婚案件后，经审理确属无效婚姻的，应当将婚姻无效的情形告知当事人，并依法作出确认婚姻无效的判决。

（二）可撤销婚姻

撤销婚姻须有撤销行为，仅有可撤销的事由而无撤销行为的，婚姻的效力并不消灭。撤销权人行使撤销权的意思表示须向人民法院作出，而非向相对人作出。

1.胁迫婚姻

因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

2.隐瞒重大疾病

一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

（三）婚姻无效和可撤销的法律后果

1.无效的或者被撤销的婚姻自始没有法律约束力，当事人不具有夫妻的权利和义务。

2.同居期间所得的财产，由当事人协议处理；协议不成的，由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。对重婚导致的无效婚姻的财产处理，不得侵害合法婚姻当事人的财产权益。

3.当事人所生的子女，适用法律关于父母子女的规定。婚姻无效或者被撤销的，无过错方有权请求损害赔偿。

（四）事实婚姻和同居

1.未办理结婚登记的，应当补办登记。

2.未办理结婚登记即以夫妻名义同居生活的男女双方之间，如果当事人补办了婚姻登记，期间为合法的婚姻关系；如果没有补办婚姻登记，期间就不是合法的婚姻关系，仅属于同居关系，而不是事实婚姻。男女双方依据《民法典》规定补办结婚登记的，婚姻关系的效力从双方均符合《民法典》所规定的结婚的实质要件时起算。

【注意】有配偶者与他人同居属于非法同居，为我国民事法律所禁止。

【高频考点】家庭关系（★★★）

（一）夫妻关系

夫妻关系，是指男女因结婚而形成的具有权利义务内容的社会关系。包括夫妻人身关系和夫妻财产关系。

1.夫妻人身关系

（1）夫妻独立姓名权和婚姻姓氏权。

（2）夫妻人身自由权。夫妻双方都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或者干涉。

（3）夫妻双方有平等的婚姻住所决定权

（4）夫妻日常家事代理权。日常家事代理权，是指夫妻一方因日常家庭生活或者家庭共同事务在与第三人进行民事交往活动时所为法律行为，被视为夫妻共同的意思表示，另一方承担连带责任。

（5）夫妻之间有相互继承遗产的权利。

（6）配偶同居、忠实的权利和义务。

2.夫妻财产关系

（1）夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：

①工资、奖金、劳务报酬；

②生产、经营、投资的收益；

③知识产权的收益；

④继承或者受赠的财产，但是法律特别规定属于夫妻一方的个人财产的除外；

⑤其他应当归共同所有的财产。

夫妻对共同财产，有平等的处理权。

（2）个人财产

下列财产为夫妻一方的个人财产：

①一方的婚前财产；

②一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿；

③遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；

④一方专用的生活用品；

⑤其他应当归一方的财产。

（3）约定财产制

男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。

（4）夫妻共同债务

夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。

（二）父母子女关系

1.婚生子女

婚生子女，是指在婚姻关系存续期间所生的子女。

2.非婚生子女

非婚生子女，是指没有合法婚姻关系的男女所生的子女。

3.继父母、继子女

继父母，是指父亲的后妻或母亲的后夫。继子女，是指夫与前妻或者妻与前夫所生的子女。

4.父母与人工生育子女

人工生育子女，是指采用人工方法取出精子或者卵子，然后用人工方法将精子或者受精卵、胚胎注入妇女子宫内，使其受孕所生子女。

5.父母与子女间的权利和义务

（1）父母对子女有抚养教育的义务。

（2）成年子女对父母有赡养扶助的义务，缺乏劳动能力或生活困难的父母，有要求成年子女给付赡养费的

权利。

（3）子女应当尊重父母的婚姻权利，不得干涉父母离婚、再婚以及婚后的生活。

（4）父母子女之间有相互继承遗产的权利。

（三）其他近亲属关系

1.祖孙间的扶养

（1）有负担能力的祖父母、外祖父母，对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年的孙子女、外孙子女，有抚养的义务；

（2）有负担能力的孙子女、外孙子女，对于子女已经死亡或者子女无力赡养的祖父母、外祖父母，有赡养的义务；

（3）祖孙之间依据《民法典》的规定，祖父母、外祖父母作为第二顺序继承人享有继承权。

2.兄弟姐妹间的扶养

（1）有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年的弟、妹，有扶养的义务；

（2）由兄、姐扶养长大的有负担能力的弟、妹，对于缺乏劳动能力又缺乏生活来源的兄、姐，有扶养的义务；

（3）兄弟姐妹之间作为第二顺序继承人相互享有继承权。

【高频考点】离婚制度（★★★）

1.协议离婚

（1）夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。

（2）自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起30日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

前款规定期限届满后30日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。

2.判决离婚（诉讼离婚）

（1）夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。

人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。

有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：

①重婚或者与他人同居；

②实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；

③有赌博、吸毒等恶习屡教不改；

④因感情不和分居满2年；

⑤其他导致夫妻感情破裂的情形。

一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

（2）经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满 1 年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

（3）现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但是军人一方有重大过错的除外。

（4）女方在怀孕期间、分娩后 1 年内或者终止妊娠后 6 个月内，男方不得提出离婚；但是，女方提出离婚或者人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的除外。

【注意】完成离婚登记，或者离婚判决书、调解书生效，即解除婚姻关系。

3.离婚的法律后果

（1）父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。

（2）离婚后，父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。

（3）离婚后，不满 2 周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满 2 周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。

（4）离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。

上述规定的协议或者判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。

（5）离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成的，由人民法院判决。

父或者母探望子女，不利于子女身心健康的，由人民法院依法中止探望；中止的事由消失后，应当恢复探望。

第二节 继承法

【高频考点】法定继承（★★★）

法定继承（又称无遗嘱继承）是指在被继承人没有对其遗产的处理立有遗嘱的情况下，由法律直接规定继承人的范围、继承顺序、遗产分配的原则的一种继承形式。

【特征】

①法定继承是遗嘱继承的补充和限制。遗嘱继承的效力优先于法定继承，法定继承是对遗嘱继承的补充；法律规定，遗嘱应当对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。

②法定继承中的继承人与被继承人间存在亲属关系。

③法定继承中对继承人、继承顺序以及遗产的分配原则的规定具有法定性。

（一）法定继承的适用范围

按照《继承法》的规定，遗嘱继承优先于法定继承适用。

在下列情况下，遗产中的有关部分按照法定继承办理：

1.遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠的；

2.遗嘱继承人丧失继承权的；

3.遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡的；

4.遗嘱无效部分所涉及的遗产；

5.遗嘱未处分的遗产。

（二）法定继承人的继承顺序

继承顺序是指法律规定的法定继承人继承遗产的先后次序。我国《民法典》规定，遗产按照下列顺序继承：

第一顺序：配偶、子女、父母。

第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。

《民法典》所说的子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。

（三）代位继承

1.代位继承的概念和特征

代位继承，是指继承人先于被继承人死亡时，由继承人的直系晚辈血亲代替先亡的直系尊血亲继承被继承人遗产的法定继承制度。

先于被继承人死亡的继承人称为被代位继承人或本位继承人，代替被代位继承人取得遗产的直系卑血亲称为代位继承人。

代位继承的特征：

（1）被代位继承人只限于被继承人的先亡子女或者先于被继承人死亡又享有继承权的兄弟姐妹。

（2）代位继承人只限于被代位继承人的直系晚辈血亲或者先于被继承人死亡的，并对被继承人享有继承权的兄弟姐妹的子女。

（3）代位继承人作为第一顺序继承人参加继承，只能继承被代位继承人应继承的遗产份额。

（4）先于被继承人死亡的子女具备丧失继承权的条件且被法院判决丧失继承权的，其晚辈直系血亲不得代位继承。

（四）转继承

转继承是指继承人在被继承人死亡之后，遗产分割之前，因为某种缘故尚未实际取得遗产而死亡或被宣告死亡，其应继份额转由他的法定继承人继承。

1.转继承的特征：

①转继承发生在被继承人死亡之后，遗产分割之前，继承人也相继死亡的情形下。

②继承人因死亡而未实际取得遗产，继承人并未放弃继承权。

③由继承人的法定继承人直接分割被继承人的遗产。

④转继承人一般只能继承其被转继承人应得的遗产份额。

⑤转继承人可以是被继承人的直系血亲，也可以是被继承人的其他合法继承人。

2.转继承的适用条件：

①继承人于被继承人死亡后遗产分割前死亡。

②继承人未丧失继承权，也未放弃继承权。

3.转继承与代位继承的区别

（1）性质不同。代位继承只发生一次继承，转继承发生两次继承。转继承是在继承开始，继承人直接继承后，又转给转继承人继承被继承人的遗产，转继承具有连续继承的性质。

（2）发生时间和成立条件不同。转继承发生在继承开始后遗产分割前，并且任何一个继承人都可能成为被转继承人。代位继承的前提只能是被代位继承人先于被继承人死亡而发生。

（3）主体不同。转继承人是被转继承人死亡时生存的所有法定继承人，被转继承人可以是被继承人的任一继承人。代位继承中的代位继承人只能是被代位继承人的直系卑血亲，其他法定继承人不能成为代位继承人。

（4）适用范围不同。转继承可以发生在法定继承中，也可以发生在遗嘱继承中；代位继承只适用于法定继承，在遗嘱继承中不适用。

【高频考点】遗嘱继承、遗赠和遗嘱扶养协议（★★★）

（一）遗嘱继承

1.概念

遗嘱继承，是指按照被继承人所立的合法有效的遗嘱而承受其遗产的继承方式。

2.遗嘱继承的特征

（1）被继承人生前立有合法有效的遗嘱和立遗嘱人死亡是遗嘱继承的事实构成。

（2）遗嘱继承直接体现着被继承人的遗愿。

（3）遗嘱继承人和法定继承人的范围相同，但遗嘱继承不受法定继承顺序和应继份额的限制。

（4）遗嘱继承的效力优于法定继承的效力。

3.遗嘱的内容

（1）遗产的名称和数量。

（2）指定继承人、受遗赠人。没有指定继承人或受遗赠人的遗嘱不具有法律效力。指定的继承人可以是第一顺序或第二顺序法定继承人中的任何一人或者数人；受遗赠人是法定继承人以外的国家、集体或者个人。

（3）指定继承人、受遗赠人享有财产的份额或者遗产的分配办法。

（4）指定候补继承人、受遗赠人。

（5）指定遗嘱执行人。遗嘱执行人，是指有权按照遗嘱人的意志执行遗嘱的人。

4.遗嘱的形式

（1）自书遗嘱。

自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。自然人在遗书中涉及死后个人财产处分的内容，确为死者的真实意思表示，有本人签名并注明了年、月、日，又无相反证据的，可以按自书遗嘱对待。

（2）代书遗嘱。

代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。

（3）打印遗嘱。

打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，遗嘱和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。

（4）录音录像遗嘱。

以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、日。

（5）口头遗嘱。

遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录像形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。

（7）公证遗嘱。公证遗嘱由遗嘱人经公证机关办理。

5.遗嘱的效力

（1）有效遗嘱。

遗嘱的有效，是指遗嘱符合法律规定的条件。

有效遗嘱必须具备的条件：

①立遗嘱时，遗嘱人必须具有遗嘱能力。

②遗嘱人的意思表示真实。

③遗嘱的内容不违反法律和公序良俗。

④遗嘱的形式应当符合法律规定的要求。

（2）无效遗嘱

①无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无效；

②遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效；

③伪造的遗嘱无效；

④遗嘱被篡改的，篡改的内容无效；

⑤遗嘱没有为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额的，对应当保留的必要份额处分无效。

（3）遗嘱不生效的情形

①遗嘱继承人、受遗赠人先于被继承人死亡，但遗嘱另有规定的除外，如指定有候补继承人或者候补受遗赠人。

②遗嘱继承人、受遗赠人在遗嘱成立之后、丧失继承权或者受遗赠权。

③附解除条件的遗嘱，在遗嘱人死亡之前该条件已经成就。

④附停止条件的遗嘱，遗嘱继承人、受遗赠人在条件成就前死亡。

⑤遗嘱人死亡时，遗嘱处分的财产标的已经不复存在。

6.遗嘱的撤回、变更

（1）遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。

（2）立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗嘱相关内容的撤回。

（3）立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。

7.附义务遗嘱

遗嘱继承或者遗赠附有义务的，继承人或者受遗赠人应当履行义务。没有正当理由不履行义务的，经利害关系人或者有关组织请求，人民法院可以取消其接受附义务部分遗产的权利。

附义务的遗嘱继承或者遗赠，如义务能够履行，而继承人、受遗赠人无正当理由不履行，经受益人或者其他继承人请求，人民法院可以取消其接受附义务部分遗产的权利，由提出请求的继承人或者受益人负责按遗嘱人的意愿履行义务，接受遗产。

（二）遗赠

遗赠，是遗嘱人用遗嘱的方式将个人财产赠给国家、集体或者法定继承人以外的自然人，而于其死后发生法律效力的一种单方民事法律行为。

（三）遗赠扶养协议

1.自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠扶养协议。按照协议，该组织或者个人承担该自然人生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。

2.遗赠扶养协议是双方民事法律行为，从协议成立之日起发生法律效力。

3.遗赠扶养协议签订后，扶养人应当按照约定尽扶养义务，扶养标准应当按照协议确定，协议未约定的.应当不低于当地的最低生活水平为标准。

第十一章 个人独资企业法

第二节 个人独资企业的设立、变更与终止

【高频考点】个人独资企业的事务管理（★★★）

（一）个人独资企业的投资人及其企业的权利和义务

1.权利

（1）投资人对本企业的财产依法享有所有权，其有关权利可以依法进行转让或者继承。

（2）投资人可以依法享有自主经营和对企业的管理权。

（3）个人独资企业可以申请贷款、取得土地使用权。

（4）个人独资企业有权拒绝任何单位和个人违法的强制摊派。

2.义务

（1）遵守法律、法规，遵守诚实信用原则，不得损害社会公共利益。

（2）依法履行纳税义务。

（3）个人独资企业应当依法设置会计账簿，进行会计核算。

（4）个人独资企业应当依法保障职工权益。个人独资企业招用职工的，应当依法与职工签订劳动合同，保障职工的劳动安全，按时、足额发放职工工资。

（5）个人独资企业应当按照国家规定参加社会保险，为职工缴纳社会保险费。

（二）个人独资企业投资人对企业事务的管理

投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。

【企业变更】个人独资企业存续期间登记事项发生变更的，应当办理变更登记。

第十二章 合伙企业法

第二节 普通合伙企业

【高频考点】合伙企业的事务执行（★★★）

合伙企业事务执行，是指合伙企业的经营管理及对内对外关系中的事务处理的活动。

1.合伙事务执行的形式

（1）全体合伙人共同执行合伙事务。

（2）委托一个或者数个合伙人执行合伙事务。

（3）聘任合伙人以外的人执行合伙事务。

【注意】由合伙协议约定或者经过全体合伙人一致同意，可以聘请合伙人以外的人执行合伙事务。

2.合伙人在执行合伙事务中的权利

（1）合伙人在合伙企业中具有平等的管理权、经营权、表决权、监督权和代表权。

（2）执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业。

（3）不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

（4）合伙人有查阅合伙企业会计账簿等财务资料的权利。

（5）合伙人有撤销委托和提出异议的权利。

3.合伙人在执行合伙事务中的义务

（1）向其他合伙人的报告义务。

（2）竞业禁止义务。

①合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。

②除合伙协议另有约定或者经全体合伙人一致同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易。

（3）自我交易的禁止义务。

【注意】合伙人违反法律规定或者合伙协议的约定，从事与本合伙企业进行交易的，该收益归合伙企业所有；给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

（4）合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

4.合伙企业决议的表决

合伙人对合伙企业有关事项的决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：

（1）改变合伙企业的名称；（2）变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（5）以合伙企业名义为他人提供担保；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

5.合伙企业的利润分配及亏损分担

有约定	（1）按约定的比例分配和分担
未约定或约定不明确	（2）首先由合伙人协商决定
	（3）协商不成的，由合伙人按照“实缴出资”比例分配、分担
	（4）无法确定出资比例的，由合伙人“平均”分配、分担

【注意1】合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。

【注意2】有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人；但是，合伙协议另有约定的除外。

【高频考点】入伙、退伙（★★）

（一）入伙

1.新合伙人入伙，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议；合伙协议另有约定除外。

2.新合伙人对入伙前（后）合伙企业的债务承担无限连带责任。

（二）退伙

1.退伙类型



（1）协议退伙

合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：

①合伙协议约定的退伙事由出现；

②经全体合伙人一致同意；

③发生合伙人难以继续参加合伙的事由；

④其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

【注意】合伙协议未约定合伙期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前30日通知其他合伙人。

（2）声明退伙

声明退伙，是指合伙人基于自己的意愿而表示退伙。合伙人声明退伙应当有正当的理由，没有正当理由的被视为违规退伙。

（3）法定退伙（当然退伙）

普通合伙人	有限合伙人
①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡； ②个人丧失偿债能力； ③作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者被宣告破产； ④法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格 ⑤合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。	①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡； ②作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产； ③法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格； ④合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。 【提示】不存在丧失偿债能力的问题

【注意 1】普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以依法转为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。

其他合伙人未能一致同意的，该无民事行为能力或者限制民事行为能力的合伙人退伙。

【注意 2】作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。

（4）除名退伙

①未履行出资义务；

②因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；

③执行合伙事务时有不正当行为；

④发生合伙协议约定的事由。

【注意】对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。

被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。

被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起 30 日内，向人民法院起诉。

2.退伙的法律规则

（1）普通合伙人死亡

继承人： 完全民事行为能力人	按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得普通合伙人资格
	退伙（一财产继承；二退伙结算）
继承人： 无、限制民事行为能力人	经全体合伙人一致同意，可以依法成为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。
	退伙：全体合伙人未能一致同意的，合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还该继承人

（2）有限合伙人死亡

其继承人或者权利承受人可以“依法取得”该有限合伙人在有限合伙企业中的资格。

【注意】直接取得，无需任何人同意，不看继承人行为能力。

第三节 特殊普通合伙企业

【高频考点】特殊普通合伙企业的责任形式（★★★）

1.有限责任与无限连带责任相结合：

如果是合伙人因故意或重大过失造成合伙企业债务的，该合伙人应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担有限责任。

2.无限连带连带责任

如果是合伙人非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

【追责】合伙人执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对给合伙企业造成的损失承担赔偿责任。

【注意 1】特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金、办理职业保险。

【注意 2】执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务。

【注意 3】执业风险基金应当单独立户管理。

第四节 有限合伙企业

【高频考点】有限合伙企业的设立（★★）

1.设立

（1）有限合伙企业由 2 个以上 50 个以下合伙人设立；但是，法律另有规定的除外。

（2）有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人。

（3）有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样。

【注意】有限合伙企业合伙人有上限，普通合伙没有。

2.出资：有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。

【注意】有限合伙人不得以劳务出资。

3.事务执行

（1）有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。

有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。

（2）有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：

①参与决定普通合伙人入伙、退伙；

②对企业的经营管理提出建议；

③参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所；

④获取经审计的有限合伙企业财务会计报告；

⑤对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料；

⑥在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；

⑦执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；

⑧依法为本企业提供担保。

4.有限合伙企业的其他特殊规定

	有限合伙人	普通合伙人
关联交易	有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易；有约定的除外（约定→可以）	合伙人不得同本合伙企业进行交易，有约定或全体合伙人一致同意除外（约定→不得）
竞业禁止	有限合伙人可以自营或同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务；合伙协议另有约定的除外（约定→可以）	合伙人不得自营或同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务（强制）
出质	有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质；约定的除外。（约定→可以）	普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意（强制）
对外转让	有限合伙人可以向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，应提前 30 日通知其他合伙人。（对外转让通知）	除合伙协议另有约定外，普通合伙人向合伙人以外的人转让财产份额时，须经其他合伙人一致同意（对外转让同意）

5.入伙、退伙和身份转变责任承担

	普通合伙企业	有限合伙企业
入伙	新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。	新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。
退伙	退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。	有限合伙人退伙后，对基于其退伙前原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任
身份转变	有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任（有→普：前后都无限）	
	普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任 （普→有：前无限，后有限）	

第五节 合伙企业解散、清算

【高频考点】合伙企业解散（★★★）

1.概念

合伙企业解散，是指合伙企业因某种法律事实的发生而使其民事主体资格归于消灭的法律行为。

2.合伙企业解散的事由

（1）合伙期限届满，合伙人决定不再经营；

（2）合伙协议约定的解散事由出现；

（3）全体合伙人决定解散；

（4）合伙人已不具备法定人数满 30 日；

（5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；

（6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（7）法律、行政法规规定的其他原因。

第十三章 公司法

第三节 公司股东

【高频考点】股东出资（★★★）

（一）出资方式

总体规定	股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产出资；但不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。
货币出资	①有限责任公司股东，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户； ②股份有限公司发行股份的股款缴足后，须经依法设立的验资机构验资并出具证明。
非货币 财产出资	①应当评估作价，核实财产，依法办理财产权的转移手续。 ②评估作价时，不得高估或者低估作价
债权出资	①债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定； ②经人民法院生效裁判或者仲裁机构裁决确认； ③公司破产重整或者和解期间，列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议。
股权出资	出资条件：

	①由出资人合法持有并依法可以转让； ②无权利瑕疵或者权利负担； ③出资人已履行股权转让的法定手续； ④出资的股权已依法进行了价值评估。
	出资限制： 具有下列情形的，股权不得用作出资： ①已被设立质权 ②股权所在公司章程约定不得转让 ③法律、行政法规或国务院决定规定，转让股权应批准而未经批准 ④法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形

（二）出资责任

1.虚假出资

有限责任公司股东不按规定缴纳出资	①对公司：股东向公司足额缴纳； ②对其他股东：向已缴股东承担违约责任； ③对公司债权人：公司设立时的其他股东承担连带责任。
股东未履行或者全面履行出资义务	①公司或者其他股东可以请求其向公司依法 全面履行出资义务； ②公司债权人可以请求未履行或者未全面履行出资义务的股东，在未出资本息范围内，对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。
公司设立时未履行或未全面履行出资义务	①全面履行出资义务（对公司） ②在未出资本息范围内对公司债务承担补充赔偿责任 ③公司发起人与未出资股东承担连带责任
公司增资时未履行或未全面履行出资义务	①向公司依法全面履行出资义务； ②在未出资本息范围内对公司债务承担补充赔偿责任； ③未尽忠实义务和勤勉义务而使出资未缴足的董事、高级管理人员承担相应责任
股东未履行或者未全面履行出资义务，公司可以根据公司章程或者股东会决议，对其利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等股东权利作出相应的合理限制。	

有限责任公司的股东未履行出资义务，经公司催告缴纳或者返还，其在合理期间内仍未缴纳或者返还出资，公司可以股东会决议形式解除该股东的股东资格，并及时办理法定减资程序或者由其他股东或者第三人缴纳相应的出资。

2.出资不实

出资人的出资情形	法律责任
以实际价额显著低于公司章程所规定价额	①交付该出资的股东或发起人补足其差额； ②公司设立时的其他股东或发起人承担连带责任
以非货币财产出资，未依法评估作价	委托评估机构对该财产评估作价。评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的，认定出资人未依法全面履行出资义务。
出资时符合法定条件；出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值	除另有约定外，出资人不需要承担责任
以不享有处分权的财产出资	按善意取得制度处理
以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权	对违法犯罪行为追究、处罚时，采取拍卖或者变卖的方式处置其股权
以划拨土地使用权出资，或者以设定权利负担的土地使用权出资	责令其在合理期间内办理土地变更手续或者解除权利负担；逾期未办的，应当认定出资人未依法全面履行出资义务
以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资	已交付公司使用但未办理权属变更手续	①指定期间办理了手续，认定其已履行了出资义务 ②自实际交付财产使用时享有相应股东权利
	已办理权属变更手续但未交付给公司使用	责令其向公司交付，在实际交付之前不享有相应股东权利

3.抽逃出资

法律规定	公司成立后，股东不得抽逃出资。——资本维持原则的体现
对抽逃出资的认定	①制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配； ②通过虚构债权债务关系将其出资转出； ③利用关联交易将出资转出； ④其他未经法定程序将出资抽回的行为。
抽逃出资的法律责任	（1）股东抽逃出资，应当返还出资本息；协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任。——对公司的责任 （2）在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；协助抽逃的对此承担连带责任。——对债权人的责任 （3）合理限制其利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等股东权利。 （4）经催告，其在合理期间内仍未缴纳或者返还出资，解除其股东资格。

【高频考点】股东的资格（★★★）

1.股东概念及特征

概念	（1）对公司出资并享有权利、承担义务的人。 （2）除国家有禁止或限制的特别规定外，代表本级政府履行出资人职责的机构、部门、企业法人、具有法人资格的事业单位和社会团体、自然人均可以成为公司股东。
特征	（1）在公司章程上被记载为股东，并在公司章程上签名盖章； （2）向公司投入章程中承诺的资产，并实际履行了出资义务； （3）工商行政机关登记的公司文件中列名为股东； （4）公司成立后取得公司签发的出资证明书； （5）被载入公司股东名册； （6）在公司中享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利。

2.股东资格取得

原始取得	设立取得	实际缴纳出资+公司设立	
	增资取得	有限责任公司	股东会经代表 2 / 3 以上表决权的股东通过，作出决议
		股份有限公司	股东大会决议+有权机关批准+出资
继受取得	转让、继承、赠与、公司合并		

3.名义股东与实际出资人

有限责任公司的实际出资人可以与名义股东订立合同，约定由实际出资人出资，并享有投资权益，以名义出资人为名义股东。

（1）代持股协议效力

如无法律规定的无效情形，实际出资人与名义股东签订的合同均为有效合同。

（2）名义股东与实际出资人的权利义务

①实际出资人实际履行了出资义务，可向名义股东主张权利。

②名义股东不能以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利 。

（3）隐名股东显名化

实际出资人未经公司其他股东半数以上（≥1/2）同意，请求公司变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册、记载于公司章程并办理公司登记机关登记的，人民法院不予支持。

（4）名义股东处分股权

①名义股东将登记于其名下的股权转让、质押或者以其他方式处分，实际出资人以其对于股权享有实际权利为由，请求认定处分股权行为无效的，人民法院可以参照善意取得制度的规定处理。

②名义股东处分股权造成实际出资人损失，实际出资人请求名义股东承担赔偿责任的，人民法院应予支持。

4.股东资格丧失

含义	指股东因法定原因或法定程序而丧失股东身份
法定情形	（1）公司法人资格消灭，如解散、破产、被合并； （2）自然人股东死亡或法人股东终止； （3）股东将其所持有的股权转让； （4）公司收购股权； （4）股权被人民法院强制执行； （5）法律规定的其他情形。

【高频考点】股东权利（★★★）

（一）财产权

1.利润分配权

2.优先认购权

3.股权（股份）转让权

4.股权优先购买权

5.请求收购股权（股份）权

6.剩余财产分配权

7.股权继承权

【说明1】股权（股份）转让权

（1）发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

（2）公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

（3）公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

【说明2】股权优先购买权

（1）有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满30日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

（2）经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

【说明3】请求收购股权（股份）权

有限责任公司存在下列情形之一的，对股东会决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

①公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合《公司法》规定的分配利润条件的；

②公司合并、分立、转让主要财产的；

③公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

（二）参与决策权

1.参加股东会议权

2.决议事项表决权

3.委托表决权

4.选举更换董事、监事权

5.提议召开临时股东会议

6.召集和主持股东会议权

7.临时提案权

8.提议召开董事会临时会议权

9.累积投票权

10.股东决策权

【说明 1】提议召开临时股东会议

①股东会的定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。

②代表 1/10 以上表决权的股东有权提议召开临时会议；

③股东大会应当每年召开 1 次年会。

④经单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求，应当在 2 个月内召开临时股东大会。

【说明 2】召集和主持股东会议权

①股东会议由董事会召集，董事长主持。

②特殊情形下，股东会由代表 1/10 以上表决权的股东自行召集和主持；股东大会由连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东自行召集和主持。

【说明 3】临时提案权

股东大会只能审议会议通知中列明的事项和股东以临时提案方式提交大会审议的事项。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

【说明 4】提议召开董事会临时会议权

①股份有限公司董事会每年度至少召开两次会议。

②代表 1/10 以上表决权的股东，有权提议召开董事会临时会议。

③董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

（三）知情权

1.股东会议知情权

（1）有限责任公司召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

（2）股份有限公司召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开30日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

2.查阅、复制公司重要文件权

（1）有限责任公司股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。

（2）股份有限公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

3.查阅会计账簿权

有限责任公司股东查阅公司会计账簿，需要书面请求公司同意。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

4.报酬知情权

股份有限公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。

【高频考点】股东诉讼（★★★）

（一）股东诉讼种类

1.股东代表诉讼，董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程规定或者他人侵害公司合法权益，给公司造成损失，公司拒绝或者怠于向该违法行为人请求损害赔偿时，具备法定资格的股东为了公司利益，有权以自己名义直接请求违法行为人赔偿公司损失

2.股东直接诉讼，董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益，股东直接诉讼的目的是为了股东自己的利益。

（二）股东诉讼情形

股东与股东的诉讼	（1）出资违约的诉讼 （2）填补出资的诉讼 （3）优先购买权诉讼
股东与公司的诉讼	（1）涉及股东会或董事会决议撤销或无效诉讼 （2）涉及股东知情权的诉讼 （3）涉及利润分配诉讼 （4）涉及公司股权收购的诉讼 （5）涉及解散公司的诉讼
股东对公司董事、监事、经理等高管	（1）直接侵害其股东利益的诉讼

的诉讼	（2）未依法履行职责的诉讼 （3）股东代表诉讼
股东对侵害公司利益第三人的诉讼	对公司债务人、侵权人的诉讼，也属于股东代位或代表诉讼的范畴

【说明 1】

涉及股东会或董事会决议撤销或无效的诉讼

1.确认决议无效诉讼权

股东认为公司股东会或股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规，可向人民法院提起确认决议无效的诉讼。

2.撤销决议诉讼权

股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

3.不成立诉讼权：

（1）公司未召开会议的，但依据《公司法》第 37 条第 2 款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；

（2）会议未对决议事项进行表决的；

（3）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合《公司法》或者公司章程规定的；

（4）会议的表决结果未达到《公司法》或者公司章程规定的通过比例的；

（5）导致决议不成立的其他情形。

4.外部善意相对人的保护：公司决议被法院判决确认无效或者撤销的，公司依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

【说明 2】

涉及股东知情权的诉讼

1.股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。

2.公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

3.公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。

4.股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系业务的，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外

5.股东为了向他人通报有关信息查阅公司会计账簿，可能损害公司合法利益的

6.股东在向公司提出查阅请求之日前的 3 年内，曾通过查阅公司会计账簿，向他人通报有关信息损害公司合法利益的

7.公司章程、股东之间的协议等实质性剥夺股东查阅或者复制公司文件材料的权利，公司不得以此为由拒

绝股东查阅或者复制。

8.股东依据法院生效判决查阅公司文件材料的，在该股东在场的情况下，可以由会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员辅助进行。

9.股东行使知情权后泄露公司商业秘密导致公司合法利益受到损害，公司可以请求该股东赔偿相关损失。

10.辅助股东查阅公司文件材料的会计师、律师等泄露公司商业秘密导致公司合法利益受到损害，公司可以请求赔偿相关损失。

【说明 3】

涉及利润分配诉权

1.股东应提交载明具体分配方案的股东（大）会的有效决议

2.股东未提交载明具体分配方案的股东会决议，请求公司分配利润的，法院应驳回其诉讼请求。

【说明 4】

涉及公司股权收购的诉讼

根据《公司法》第 74 条规定，就下列事项决议投反对票的有限责任公司股东，自股东会会议决议通过之日起 60 日内，与公司不能按照合理的价格达成股权收购协议的，可以自股东会会议决议通过之日起 90 日内向人民法院提起诉讼：

①公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合《公司法》规定的分配利润条件的；

②公司合并、分立、转让主要财产的；

③公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

【说明 5】

解散公司的诉讼

<table>
<tr><td>诉讼提起人</td><td colspan="2">单独或者合计持有公司全部股东表决权 10%以上的股东提起</td></tr>
<tr><td rowspan="4">情形</td><td>持续 2 年以上无法召开股东会或者股东大会</td><td rowspan="3">公司经营管理发生严重困难的</td></tr>
<tr><td>持续 2 年以上不能作出有效股东会或股东大会决议</td></tr>
<tr><td>公司董事长期冲突，且无法通过股东会或者股东大会解决</td></tr>
<tr><td colspan="2">经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形</td></tr>
<tr><td>法院不予受理的情形</td><td colspan="2">（1）股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销企业法人营业执照未进行清算为由，提起解散公司诉讼的；
（2）驳回后，同一理由再提诉讼
（3）解散公司之诉+申请法院清算之诉→清算之诉不受理</td></tr>
<tr><td>管辖</td><td colspan="2">公司住所地法院管辖（主要办事机构所在地，不明的，注册地）</td></tr>
<tr><td>当事人</td><td colspan="2">公司为被告，其他股东为共同原告或第三人</td></tr>
</table>

审理	先调解原则，公司应当自收购股份的调解书生效之日起 6 个月内将股份转让或者注销。

【说明 6】

董事、监事、高级管理人员的派生诉讼权

即针对公司利益受损，原本原告应为公司，但有权代表公司提起诉讼的人不提起诉讼时的无奈之举。

原告	适用情形	先诉请求	被请求人的作为	股东
有限公司股东； 股份公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上的股东	董事、高管违法、违规或违章，给公司造成损失	书面请求监事会/监事（不设监事会的）	拒绝起诉； 30 日内未起诉	代位起诉
	监事违法、违规或违章，给公司造成损失	书面请求董事会/执行董事（不设董事会的）		
	情况紧急、不立即起诉公司利益将会受到难以弥补的损害			直接起诉

第四节 公司运行

【高频考点】公司组织机构（★★★）

（一）股东会（股东大会）

1.股东（大）会职权

（1）决定公司的经营方针和投资计划（≠经营计划、投资方案）；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会或者监事的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（10）修改公司章程；

（11）公司章程规定的其他职权；

【注意】有限责任公司股东对股东会职权范围内的事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2.股东会（股东大会）会议的召集与主持

（1）有限责任公司

①首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。

②设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上（≥1/2）董事共同推举一名董事主持。

③不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。

④董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表 1/10 以上表决权的股东可以自行召集和主持。

（2）股份有限公司

股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

3.股东会（股东大会）会议的召开

（1）有限责任公司

①股东会会议分为定期会议和临时会议。

②定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。

③代表 1/10 以上表决权的股东，1/3 以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

④召开股东会会议，应当于会议召开 15 日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

⑤股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

（2）股份有限公司

股东大会应当每年召开 1 次年会。

有下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会：

①董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；

【注意】股份有限公司设董事会，其成员为 5-19 人。

②公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

③单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

④董事会认为必要时；

⑤监事会提议召开时；

⑥公司章程规定的其他情形。

召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开 30 日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开 5 日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；

董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

4.股东会（股东大会）会议表决

（1）有限责任公司

①股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

②股东会的议事方式和表决程序，除公司法有规定的外，由公司章程规定。

③股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表 2/3 以上（≥2/3）表决权的股东通过。（特殊多数决）

④普通多数决：过半数或半数以上（《公司法》无明文规定）

（2）股份有限公司

①股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

②股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（≥2/3）通过。

【注意】股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

（二）董事会（执行董事）及经理

1.董事会主要行使下列职权：

（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

【注意】决定公司的经营方针和投资计划是股东会的权力

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（10）制定公司的基本管理制度；

（11）公司章程规定的其他职权。

2.董事会的组成

	有限责任公司	国有独资公司	股份有限公司

人数	3-13 人		5-19 人
职工代表	①两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立：应当有职工代表 ②其他有限责任公司：可以有职工代表	①应当有公司职工代表； ②职工代表由公司职工代表大会选举产生； ③其他成员由国有资产监督管理机构委派	可以有职工代表 【注意】董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事长	董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定	董事长、副董事长由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生
次数	章程决定	——	1 年至少 2 次
召集和主持	董事长＞副董事长＞半数以上董事共同推举 1 名董事		
任期	每届任期不得超过 3 年，连选可以连任。		
	【注意】任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的（低于 3 人或 5 人时），在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。		
表决	实行一人一票		

（三）监事会（监事）

1.监事会的组成

	有限责任公司	国有独资公司	股份有限公司
设立	股东人数少或规模小的，可以设 1-2 名监事	必须设监事会	
人数	不得少于 3 人	不得少于 5 人	不得少于 3 人
代表	监事会应当包括职工代表，职工代表的比例不得低于 1/3		
主席	全体监事过半数选举产生	监事会主席由国有资产监督管理机构指定	全体监事过半数选举产生

2.监事会（不设监事会的监事）的职权

（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（5）向股东会会议提出提案；

（6）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；

（9）公司章程规定的其他职权。

第十四章 破产法

第二节 破产程序

【高频考点】破产申请（★★★）

1.债务人申请

当**债务人不能清偿到期债务**，并且**资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，**债务人可以向人民法院提出**重整、和解或者破产清算**申请**。**

2.债权人申请

当**债务人不能清偿到期债务，债权人**可以向人民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。

【提示**】债务人已解散**但未清算或者未在合理期限内清算完毕，且未清偿债务的情形下，**债权人**以债务人未能清偿债务为由向法院提出破产清算申请的，法院应予受理。但债务人在法定异议期限内举证证明其未出现破产原因的除外。

3.依法对债务人负有清算责任的人申请

企业法人已解散但未清算或者未清算完毕，资产不足以清偿债务的，**依法负有清算责任的人**应当向人民法院申请破产清算。

【提示**】依法负有清算责任的人**包括未清算完毕情形下已经成立的清算组，以及应清算未清算情形下依法负有启动清算程序的清算义务人。

4.国务院金融监督管理机构申请

商业银行、证券公司、保险公司等金融机构出现破产原因的，国务院金融监督管理机构可以向人民法院提出对该金融机构进行重整或者破产清算的申请。

【高频考点】破产申请的受理（★★★）

（一）受理时限

1.法院应当自收到**债权人申请**之日起5日内通知债务人。有异议的，应当自收到法院通知之日起7日内向

法院提出。法院应当自异议期满之日起10日内裁定是否受理。

2.债务人对债权人的申请未在法定期限内向人民法院提出异议或者异议不成立的，人民法院应当依法裁定受理破产申请，并自裁定作出之日起5日内送达债务人。

3.债务人收到法院受理债权人提出的破产申请裁定后，应当自裁定送达之日起15日内向人民法院提交财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况。债务人拒不提交的，人民法院可以对债务人的直接责任人员采取罚款等强制措施。

4.债务人或对债务人企业负有清算责任的人提出破产申请的，人民法院应当自收到申请之日起15日内对申请人的主体资格、破产原因以及有关材料和证据进行审查，并依据《企业破产法》第10条的规定做出是否受理裁定。人民法院受理破产申请的，应当自裁定作出之日起5日内送达申请人。人民法院认为申请人应当补充、补正相关材料的，应当自收到破产申请之日起5日内告知申请人。**当事人补充、补正相关材料的期间不计入**自收到申请之日起15日内。

5.有特殊情况，如债权人人数众多、债权债务关系复杂等，需要延长裁定受理期限的，经上一级人民法院批准，可以延长15日。

（二）受理后的工作

人民法院裁定受理破产申请后，应在规定时间内完成以下工作：

1.指定管理人。人民法院受理破产申请后，应同时指定管理人，管理人负责接管债务人的财产。除重整、和解程序中债务人经人民法院许可自行管理财产和营业事务外，管理人成为债务人财产的实际控制者，依法管理和处分债务人财产。

2.发出破产申请受理的通知和公告。人民法院裁定受理破产申请后，应当自裁定**受理破产申请之日起25日内**通知已知债权人，并予以公告。

（三）不予受理或驳回

1.破产申请的不予受理

（1）**债务人**有**隐匿、转移财产等行为，为了逃避债务而申请破产的；**

（2）**债权人**借破产申请**毁损债务人商业信誉，意图损害公平竞争的。**

人民法院裁定不受理破产申请的，应当自裁定作出之日起5日内送达申请人并说明理由。申请人对不予受理破产申请的裁定不服的，有权自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

2.破产申请的驳回

人民法院受理破产申请后，经审查发现债务人有巨额财产下落不明且不能合理解释财产去向等情形，即没有达到不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力界限的，可以裁定驳回申请。

申请人对驳回申请的裁定不服的，有权自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

【高频考点】破产申请受理的法律后果（★★★）

（一）相关人员的义务

1.债务人及有关人员的义务

（1）为防止债务人以清偿为名转移或转让企业财产，**保障所有破产债权人都能够得到平等清偿，**人民法院

受理破产申请后，**债务人对个别债权人的债务清偿无效。**

（2）债务人的有关人员（包括法定代表人、财务管理人员和经理、监事等其他管理人员）自人民法院**受理破产申请的裁定送达债务人之日起至破产程序终结之日**承担下列义务：

①妥善保管其占有和管理的财产、印章和账簿、文书等资料；

②根据人民法院、管理人的要求进行工作，并如实回答询问；

③列席债权人会议并如实回答债权人的询问；

④未经人民法院许可，不得离开住所地；

⑤不得新任其他企业的董事、监事、高级管理人员。

2.债务人的债务人或者财产持有人的义务

（1）人民法院受理破产申请后，债务人的债务人或者财产持有人应当**向管理人清偿债务或者交付财产。**

（2）债务人的债务人或者财产持有人**故意违反规定向债务人**清偿债务或者交付财产，**使债权人受到损失的，不免除**其清偿债务或者交付财产的义务。

（二）双方均未履行完毕合同的处理

1.法院受理破产申请后，**管理人**对破产申请**受理前**成立而**债务人和对方当事人均未履行完毕**的合同有权决定**解除**或**继续履行**，并通知对方当事人。

2.管理人自破产申请**受理之日起 2 个月内未通知**对方当事人，或**自收到对方当事人催告之日起 30 日内未答复的，视为解除合同。**

3.管理人**决定继续履行合同，**对方当事人应当履行，但对方当事人有权要求管理人提供担保。管理人不提供担保的，视为解除合同。

（三）保全措施的解除与执行程序的中止

1.保全措施

（1）破产申请受理前，已经采取的保全措施

①人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除。

②对债务人财产已采取保全措施的相关单位，在知悉人民法院已裁定受理有关债务人的破产申请后，应当依照规定及时解除对债务人财产的保全措施。

（2）破产申请受理后，采取新的保全措施

破产申请受理后，对于可能因有关利益相关人的行为或其他原因，影响破产程序依法进行的，受理破产申请的人民法院可以**根据管理人的申请**或依**职权**，对债务人的全部或部分财产采取保全措施。

（四）民事诉讼或者仲裁的中止与继续

人民法院**受理破产申请后**，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管债务人的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行（在原审人民法院）。

1.破产申请受理前，债权人就债务人财产提起下列诉讼，破产申请受理时案件尚未审结的，人民法院应当**中止审理：**

（1）主张次债务人代替债务人直接向其偿还债务的；

（2）主张债务人的出资人、发起人和负有监督股东履行出资义务的董事、高级管理人员，或者协助抽逃出

资的其他股东、董事、高级管理人员、实际控制人等直接向其承担出资不实或者抽逃出资责任的；

（3）以债务人的股东与债务人法人人格严重混同为由，主张债务人的股东直接向其偿还债务人对其所负债务的；

（4）其他就债务人财产提起的个别清偿诉讼。

2.破产申请受理前，债权人就债务人财产向人民法院提起的民事诉讼，人民法院已经作出生效民事判决书或者调解书但尚未执行完毕的，破产申请受理后，相关执行行为应当依据《企业破产法》的规定中止，债权人应当依法向管理人申报相关债权。

3.破产申请受理后，债权人就债务人财产向人民法院提起民事诉讼的，**人民法院不予受理。**

4.债务人**破产宣告后，**人民法院应当判决驳回债权人的诉讼请求。但是，债权人一审中变更其诉讼请求为追收的相关财产归入债务人财产的除外。

债务人**破产宣告前，**人民法院裁定驳回破产申请或者终结破产程序的，上述中止审理的案件应当依法恢复审理。

第三节 破产债权

【高频考点】债权申报（★★★）

（一）破产债权与破产债权申报

破产债权	破产申请受理前成立+经依法申报确认+通过破产程序+从破产财产中获得公平清偿+可强制执行的财产请求权（不同于破产费用、取回权、别除权）
破产债权的申报	1.指债权人在法院受理破产申请后依照法定程序和期限，主张并证明其债权存在，参加破产程序的法律行为。 2.债权申报是债权人参加破产程序，行使权利的基础。
申报的期限	最短不得少于30日，最长不超过3个月。自法院发布受理破产申请公告之日起算。

（二）债权申报范围

1.债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，不必申报，由管理人调查后列出清单并予以公示。职工对清单记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人不予更正的，职工可以向人民法院提起诉讼。

2.未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。

3.附条件、附期限的债权和诉讼、仲裁未决的债权，债权人可以申报。

4.连带债权人可以由其中一人代表全体连带债权人申报债权，也可以共同申报债权。

5.债务人的保证人或者其他连带债务人已经代替债务人清偿债务的，以其对债务人的求偿权申报债权。

6.债务人的保证人或者其他连带债务人尚未代替债务人清偿债务的，以其对债务人的将来求偿权申报债权。

但是，债权人已经向管理人申报全部债权的除外。（不得重复申报）

7.保证人被裁定进入破产程序的，债权人有权申报其对保证人的保证债权。

主债务未到期的，保证债权在保证人破产申请受理时视为到期。一般保证的保证人主张行使先诉抗辩权的，人民法院不予支持，但债权人在一般保证人破产程序中的分配额应予提存，待一般保证人应承担的保证责任确定后再按照破产清偿比例予以分配。

保证人被确定应当承担保证责任的，保证人的管理人可以就保证人实际承担的清偿额向主债务人或其他债务人行使求偿权。

8.债务人、保证人均被裁定进入破产程序的，债权人有权向债务人、保证人分别申报债权。

债权人向债务人、保证人均申报全部债权的，从一方破产程序中获得清偿后，其对另一方的债权额不作调整，但债权人的受偿额不得超出其债权总额。保证人履行保证责任后不再享有求偿权。

9.连带债务人数人被裁定适用《破产法》规定的程序的，其债权人有权就全部债权分别在各破产案件中申报债权。

10.管理人或者债务人依照规定解除合同的，对方当事人以因合同解除所产生的损害赔偿请求权申报债权。

11.债务人是委托合同的委托人，被裁定适用本法规定的程序，受托人不知该事实，继续处理委托事务的，受托人以由此产生的请求权申报债权。

12.债务人是票据的出票人，被裁定适用《破产法》规定的程序，该票据的付款人继续付款或者承兑的，付款人以由此产生的请求权申报债权。

13.破产申请受理后，债务人欠缴款项产生的滞纳金，包括债务人未履行生效法律文书应当加倍支付的迟延利息和劳动保险金的滞纳金，债权人作为破产债权申报的，人民法院不予确认。

（三）债权申报后果

1.债权人取得破产程序当事人地位。

2.债权的诉讼时效因债权申报而中断。即未到期的债权，在破产申请受理时视为到期；附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。

3.债权人逾期申报或未按规定申报债权的，将产生失权或其他不利后果。

【高频考点】债权人会议与债权人委员会（★★★）

（一）债权人会议（权力机构）

是破产程序中依人民法院的通知或公告组成的，表达债权人共同意思，对有关破产事项进行决议和对破产程序进行监督的机构。

1.债权人会议的职权

（1）核查债权；

（2）申请法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬；

（3）监督管理人；

（4）选任和更换债权人委员会成员；

（5）决定继续或者停止债务人的营业；

（6）通过重整计划；

（7）通过和解协议；

（8）通过债务人财产的管理方案；

（9）通过破产财产的变价方案；

（10）通过破产财产的分配方案；

（11）人民法院认为应当由债权人会议行使的其他职权。

【注意】通过和解协议和通过破产财产分配方案时，有担保债权且未放弃优先受偿权的债权人无表决权。

2.债权人会议的召开

（1）第一次会议由人民法院负责召集，自债权申报期限届满之日起 15 日内召开。

（2）以后的债权人会议，在人民法院认为必要时，或者管理人、债权人委员会、占债权总额 1/4 以上的债权人向债权人会议主席提议时召开。

（3）债权人会议设主席 1 人，由人民法院在有表决权的债权人中指定。主席负责主持债权人会议。

（4）召开债权人会议，管理人应当提前 15 日将会议时间、地点、内容、目的等事项通知已知的债权人。

3.表决

（1）依法申报债权的债权人为债权人会议成员，有权参加债权人会议，享有表决权。

（2）对债务人的特定财产享有担保权的债权人，也享有表决权，只有通过和解协议和通过破产财产分配方案时，不享有表决权。

（3）债权人可以委托代理人出席债权人会议，行使表决权。

（4）债务人的职工和工会代表有权参加债权人会议，但不享有表决权。

4.决议

一般情况	出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的 1/2 以上。（人数＞1/2+债权额≥1/2）
重整计划	出席会议的债权人过半数通过，并且占债权总额的 2/3 以上。（人数＞1/2+债权额≥2/3）
和解	出席会议的有表决权的债权人过半数通过，其所代表的债权额占无财产担保的债权总额 2/3 以上。（人数＞1/2+无担保债权额≥2/3）

（二）债权人委员会

含义	对破产程序进行监督的常设机构，也叫破产监督人。
设立	其是否设立，由债权人会议根据需要确定。
组成	由债权人会议选任的债权人代表和 1 名债务人的职工代表或者工会代表组成，不得超过 9 人，由人民法院以书面决定认可。
职权	（1）监督债务人财产的管理和处分；

	（2）监督破产财产分配； （3）提议召开债权人会议； （4）债权人会议委托的其他职权。

第四节 债务人财产

【高频考点】债务人财产的范围与认定（★★★）

债务人财产，是指破产申请**受理时属于债务人的全部财产，以及破产申请受理后至破产程序终结前债务人取得的财产。**

（一）债务人财产的范围

1.除债务人所有的货币、实物外，债务人依法享有的可以用货币估价并可以依法转让的债权、股权、知识产权、用益物权等财产和财产权益，人民法院均应当认定为债务人财产。

2.下列财产**不应认定**为债务人财产

（1）债务人基于仓储、保管、承揽、代销、借用、寄存、租赁等合同或者其他法律关系占有、使用的他人财产；

（2）债务人在所有权保留买卖中尚未取得所有权的财产；

（3）所有权专属于国家且不得转让的财产；

（4）其他依照法律、行政法规不属于债务人的财产。

（二）债务人财产的认定、处分与保全

1.债务人财产的认定

（1）债务人已依法设定担保物权的特定财产，人民法院应当认定为债务人财产。

（2）债务人对按份享有所有权的共有财产的相关份额，或者共同享有所有权的共有财产的相应财产权利，以及依法分割共有财产所得部分，人民法院均应认定为债务人财产。

（3）破产申请受理后，有关债务人财产的执行程序未中止的，采取执行措施的相关单位应当依法予以纠正。依法执行回转的财产，人民法院应当认定为债务人财产。

2.债务人财产的处分

管理人处分《企业破产法》第69条规定的债务人重大财产的，应当事先制作财产管理或者变价方案并提交债权人会议进行表决，债权人会议表决未通过的，管理人不得处分。

3.债务人财产的保全

破产申请受理后，对于可能因有关利益相关人的行为或者其他原因，影响破产程序依法进行的，受理破产申请的人民法院可以根据管理人的申请或者依职权，对债务人的全部或者部分财产采取保全措施。

【高频考点】涉及债务人财产的撤销与无效（★★★）

（一）撤销的行使主体

1.原则上由**管理人**统一行使；

2.在**重整程序**中，经债务人申请，人民法院批准，**债务人可以在管理人的监督下自行行使**撤销权。

（二）请求人民法院予以撤销的情形

1.人民法院受理破产**申请前 1 年内，**涉及债务人财产的下列行为，管理人有权请求人民法院依法予以撤销：

（1）**无偿**转让财产的；

（2）以**明显不合理的价格**进行交易的；

（3）对**没有财产担保的债务提供财产担保**的；

（4）对**未到期的债务提前清偿**的；

（5）**放弃债权**的。

2.人民法院受理破产**申请前 6 个月内**，债务人有不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的情形，仍对**个别债权人进行清偿**的，管理人有权请求人民法院予以**撤销。**但个别清偿使债务人财产受益的除外。

【提示】存在上述情形的，管理人可以依据《企业破产法》第 31 条和第 32 条的规定提起诉讼，请求撤销涉及债务人财产的相关行为并由相对人返还债务人财产。

（三）几种撤销行为的处理

1.撤销以明显不合理价格进行交易行为的处理

人民法院根据管理人的请求撤销涉及债务人财产的以明显不合理价格进行的交易的，买卖双方应当依法返还从对方获取的财产或者价款。因撤销该交易，对于债务人应返还受让人已支付价款所产生的债务，受让人请求作为**共益债务**清偿的，人民法院应予支持。

2.债务人提前清偿未到期债务行为的处理

破产申请受理前 **1 年内**债务人提前清偿的未到期债务，在破产申请受理前已经到期，管理人请求撤销该清偿行为的，人民法院**不予支持**。但是，该清偿行为发生在破产申请受理**前 6 个月**内且债务人有《企业破产法》第 2 条第 1 款规定情形的除外。

3.管理人未提起撤销诉讼的处理

破产申请受理后，管理人未依据规定请求撤销债务人无偿转让财产、以明显不合理价格交易、放弃债权行为的，债权人依据《民法典》第 538 条、第 539 条等规定提起诉讼，请求撤销债务人上述行为并将因此追回的财产归入债务人财产的，人民法院应予受理。相对人以债权人**行使撤销权的范围超出债权人的债权**抗辩的，人民法院**不予支持。**

管理人因过错未依法行使撤销权导致债务人财产不当减损，债权人提起诉讼主张管理人对其损失承担相应赔偿责任的，人民法院应予支持。

（四）对撤销申请不予支持的几种情形

1.债务人对**以自有财产设定担保物权的债权**进行的个别清偿，管理人依据《企业破产法》第 32 条的规定请求撤销的，人民法院不予支持。但是，债务清偿时担保财产的价值低于债权额的除外。

2.债务人经诉讼、仲裁、执行程序对债权人进行的个别清偿，管理人依据《企业破产法》第 32 条的规定请

求撤销的，人民法院不予支持。但是，债务人与债权人恶意串通损害其他债权人利益的除外。

（3）债务人对债权人进行的以下个别清偿，管理人依据《企业破产法》第32条的规定请求撤销的，人民法院不予支持：

一是债务人为**维系基本生产需要而支付水费、电费**等的；

二是债务人**支付劳动报酬、人身损害赔偿金**的；

三是**使债务人财产受益的其他个别清偿。**

（五）可撤销行为的起算点

1.可撤销行为的起算点，为行政监督机构作出**撤销决定之日。**

2.债务人经过强制清算程序转入破产程序的，可撤销行为的起算点为**人民法院裁定受理强制清算申请之日。**

（六）涉及债务人财产无效的情形

1.涉及债务人财产的下列**行为无效**

（1）为逃避债务而隐匿、转移财产的；

（2）虚构债务或者承认不真实的债务的。

【提示】上述无效行为既可能发生在破产程序中，也可能发生在人民法院受理破产申请前6个月或者1年内。

2.管理人提起诉讼，主张被隐匿、转移财产的实际占有人返还债务人财产，或者主张债务人虚构债务或者承认不真实债务的行为无效并返还债务人财产的，人民法院应予支持。

【高频考点】破产费用、共益债务（★★★）

1.破产费用

人民法院受理破产申请后发生的下列费用为破产费用：

（1）破产案件的诉讼费用；

（2）管理、变价和分配债务人财产的费用；

（3）管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用。

人民法院裁定受理破产申请的，此前债务人尚未支付的公司强制清算费用、未终结的执行程序中产生的评估费、公告费、保管费等执行费用，可以参照企业破产法关于破产费用的规定，由债务人财产随时清偿。

2.共益债务

人民法院受理破产申请后发生的下列债务为共益债务：

（1）因管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务；

（2）债务人财产受无因管理所产生的债务；

（3）因债务人不当得利所产生的债务；

（4）为债务人继续营业而应支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务；

（5）管理人或者相关人员执行职务致人损害所产生的债务；

（6）债务人财产致人损害所产生的债务。

破产申请受理后，经债权人会议决议通过，或者第一次债权人会议召开前经人民法院许可，管理人或者自

行管理的债务人可以为债务人继续营业而借款。提供借款的债权人主张参照上述第（4）项的规定优先于普通破产债权清偿的，人民法院应予支持，但其主张优先于此前已就债务人特定财产享有担保的债权清偿的，人民法院不予支持。

管理人或者自行管理的债务人可以为前述借款设定抵押担保，抵押物在破产申请受理前已为其他债权人设定抵押的，债权人主张按照民法典规定的顺序清偿，人民法院应予支持。

3.清偿规则（外部有先后、内部按比例）

（1）破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。

（2）债务人财产不足以清偿所有破产费用和共益债务的，先行清偿破产费用。

（3）债务人财产不足以清偿所有破产费用或者共益债务的，按照比例清偿。

（4）债务人财产不足以清偿破产费用的，管理人应当提请人民法院终结破产程序。人民法院应当自收到请求之日起15日内裁定终结破产程序，并予以公告；债务人财产不足以支付所有破产费用，但破产案件的债权人、管理人、债务人的出资人或者其他利害关系人愿意垫付相关费用的，经人民法院同意，破产程序可以继续进行。

第十五章 电子商务法

【高频考点】电子商务征税的一般税收原则（★★）

1.中性原则

（1）课税应在电子商务与常规商务之间，寻求中性和公平

（2）从事类似交易、处于类似情况下的纳税人应缴纳类似水平的税款

2.公平效率原则

（1）税收公平

税法对具有同等纳税能力的人应当规定相同的税收负担，其有两项要求：

①非歧视性

②按纳税能力实行区别对待

（2）税收效率

国家征税应使社会承担的非税款负担为最小，即以最少的成本损失取得依法应有的税收收入，税收效率包括：

①税收的经济效率（税收要以对经济最小的负面影响而获取最大的税收收入）

②税收的行政效率

3.税收法定原则

征税主体必须依照法律的规定征税，纳税主体依照法律的规定纳税，内容包括：

（1）课税要素法定

（2）课税要素明确

（3）税收程序合法

4.灵活原则

（1）税收制度应具备灵活性，以保证税制与技术和商业共同发展：以现行税制为基础，不单独开征新税

（2）处理国际税收关系：坚持收入来源地优先征税原则

（3）处理国内税收关系：确立流转税对供货方和劳务提供方征收的原则

十六章 社会保险法

【高频考点】社会保险法的基本原则（★★★）

1.普遍保障性原则，对公民实行普遍的社会保障。

2.基本保障原则，国家和社会基于公民的保障满足基本生活需要和提供基本生存条件的保障。

3.多层次原则，社会保险除了基本保险外，还可建立补充保险。如补充养老保险（企业年金、职业年金）、补充医疗保险，商业人寿、健康保险。

4.合理性原则，社会保险水平应当与经济社会发展水平相适应，是对基本保障方针的具体化

5.社会化原则，是指社会保险资金来源社会化、社会保险管理的社会化、社会保险责任的社会化。

6.国家承担最终责任原则，国家不仅是社会保险制度的发起者和监督者，也是社会保险制度的资助者和保证者，是最终责任的承担者。

第十七章 民事诉讼法

第二节 民事诉讼受案范围和管辖

【高频考点】法院受理民事案件的范围（★★★）

1.**平等主体之间发生的财产权和人身权纠纷**。包括：①民法调整的财产关系以及与财产关系相联系的人身关系所引起的争议纠纷。②商法调整的商事关系引起的纠纷。③其他因经济关系所发生的纠纷。

2.**因劳动关系引起的纠纷**，法律明文规定依照民事诉讼程序审理的案件。

3.**其他法律调整的社会关系**引起的纠纷，包括法律明文规定应依照民事诉讼程序审理的案件，如选民资格案件、宣告失踪或者宣告失踪人死亡案件、认定公民无民事行为能力或限制民事行为能力案件、认定财产无主案件等。

二、管辖的种类

管辖，是指上下级法院之间或者同级法院之间，受理第一审民事案件的分工和权限。

（一）级别管辖

1.中级人民法院管辖：

（1）重大涉外案件；

（2）在本辖区内有重大影响的案件；

（3）最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

（二）地域管辖

1.一般地域管辖（普通管辖）：实行“原告就被告”原则。（由被告住所地人民法院管辖）

（1）对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。

【注意 1】公民的住所地，是指公民的户籍所在地。

【注意 2】公民的经常居住地，是指公民离开住所地至起诉时已连续居住 1 年以上的地方，但公民住院就医的地方除外。

（2）对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由**被告住所地**人民法院管辖。

【注意】法人或者其他组织的住所地是指法人或者其他组织的主要办事机构所在地。法人或者其他组织的主要办事机构所在地不能确定的，法人或者其他组织的注册地或者登记地为住所地。

（3）对没有办事机构的个人合伙、合伙型联营体提起的诉讼，由被告注册登记地人民法院管辖。没有注册登记，几个被告又不在同一辖区的，被告住所地的人民法院都有管辖权。

（4）例外规定

1）下列民事诉讼，由**原告住所地**人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由**原告经常居住地**人民法院管辖：

①对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼；

②对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼；

③对被采取强制性教育措施的人提起的诉讼；

④对被监禁的人提起的诉讼；

⑤被告一方被注销户籍。

【注意】原告、被告均被注销户籍的，由被告居住地人民法院管辖。

2）夫妻一方离开住所地超过 1 年，另一方起诉离婚的案件，**可以**由**原告住所地**人民法院管辖。

3）追索赡养费、抚育费、扶养费案件的**几个被告住所地不在同一辖区**的，**可以**由**原告住所地**人民法院管辖。

2.特殊地域管辖

特殊地域管辖（特别管辖），是指以当事人住所地、诉讼标的、诉讼标的物所在地，或者引起法律关系发生、变更或者消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖。

（1）因合同纠纷提起的诉讼，由**被告住所地**或者**合同履行地**人民法院管辖。

1）合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。

2）合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。

3）合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。

4）财产租赁合同、融资租赁合同以租赁物使用地为合同履行地。合同对履行地有约定的，从其约定。

5）以信息网络方式订立的买卖合同，通过信息网络交付标的的，以买受人住所地为合同履行地；通过其他方式交付标的的，收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的，从其约定。

（2）因保险合同纠纷提起的诉讼，由**被告住所地**或者**保险标的物所在地**人民法院管辖。

1）因财产保险合同纠纷提起的诉讼，如果保险标的物是**运输工具**或者**运输中的货物**，可以由**运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地**人民法院管辖。

2）因人身保险合同纠纷提起的诉讼，可以由**被保险人住所地**人民法院管辖。

（3）因票据纠纷提起的诉讼，由**票据支付地**或者**被告住所地**人民法院管辖。

（4）因公司设立、确认股东资格、分配利润、解散、股东名册记载、请求变更公司登记、股东知情权、公司决议、公司合并、公司分立、公司减资、公司增资等纠纷提起的诉讼，由**公司住所地**人民法院管辖。

（5）因铁路、公路、水上、航空运输和联合运输合同纠纷提起的诉讼，由**运输始发地、目的地**或者**被告住所地**人民法院管辖。

（6）因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

（7）因铁路、公路、水上和航空事故请求损害赔偿提起的诉讼，由**事故发生地**或者**车辆、船舶最先到达地、航空器最先降落地**或者**被告住所地**人民法院管辖。

（8）因船舶碰撞或者其他海事损害事故请求损害赔偿提起的诉讼，由碰撞发生地、碰撞船舶最先到达地、加害船舶被扣留地或者被告住所地人民法院管辖。

（9）因海难救助费用提起的诉讼，由救助地或者被救助船舶最先到达地人民法院管辖。

（10）因共同海损提起的诉讼，由船舶最先到达地、共同海损理算地或者航程终止地的人民法院管辖。

3.协议管辖

协议案件性质	合同或者其他财产权益纠纷，人身关系的民事纠纷不得协议管辖（同居或解除婚姻、收养关系后发生财产争议可以协议）。
协议法院级别	仅适用于**合同或者和其他财产权益纠纷中**的第一审案件。
协议法院范围	可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。
协议法院特点	管辖协议不得违反有关**级别管辖和专属管辖**的规定。
协议管辖形式	须采用**书面形式**。
协议管辖变更	协议一方当事人住所在签订后变更，由签订管辖协议时的住所地人民法院管辖；约定除外。
	合同转让的，协议管辖对合同受让人有效，但转让时受让人不知道，或转让协议另有约定且原合同相对人同意的除外。

4.专属管辖

（1）因不动产纠纷	不动产所在地法院管辖
（2）因港口作业发生纠纷	港口所在地法院管辖
（3）因继承遗产纠纷提起的诉讼	由被继承人死亡时住所地或主要遗产所在地法院管辖

【注意 1】不动产纠纷：

指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。

【注意 2】农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。

【注意 3】不动产已登记：

以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

5.共同管辖与选择管辖

（1）共同管辖：原告同时向两个以上有管辖权的人民法院起诉，则由**最先立案**的法院管辖（同行政诉讼）。

（2）两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院。

（3）人民法院在立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，不得重复立案；立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，裁定将案件移送给先立案的人民法院。

【注意】选择管辖是指，依照法律规定，对同一案件两个以上法院都有管辖权时，当事人可以选择其中一个法院起诉。

（三）移送管辖

1.移送管辖符合条件：

（1）移送法院已经受理案件；

（2）移送法院对案件无管辖权；

（3）受移送法院对案件有管辖权。

2.管辖权的转移：由上级法院决定或同意把案件的管辖权由下级法院转移给上级法院；或由上级法院转移给下级法院审理。

（四）指定管辖

1.受移送法院认为自己对移送来的案件无管辖权，报请上级人民法院指定管辖。

2.有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权。

3.两个或者两个以上的法院都认为自己对案件有管辖权，或者两个或两个以上法院都认为自己对案件没有管辖权，通过协商未能解决管辖争议，报请共同上级法院指定管辖。

第三节 民事诉讼参加人

【高频考点】共同诉讼（★★★）

（一）必要的共同诉讼

1.必要的共同诉讼，是指当事人一方或双方为**2人以上**，其**诉讼标的**是**共同**的，人民法院认为**必须合并审理**，并作出同一判决的诉讼。在必要的共同诉讼中，共同诉讼人**必须一同起诉**或者**一同应诉**，彼此有连带关系，其中1人的诉讼行为经其他共同诉讼人承认，对其他共同诉讼人**发生效力**。

2.必要的共同诉讼主要包括：

（1）劳务派遣工作人员因执行工作任务造成他人损害的，可以**用工单位与劳务派遣单位**为共同被告。

（2）营业执照上登记的经营者与实际经营者不一致的，以**登记的经营者和实际经营者**为共同诉讼人。

（3）在诉讼中，未依法登记领取营业执照的个人合伙的**全体合伙人**为共同诉讼人。

（4）企业法人分立的，因分立前的民事活动发生的纠纷，以**分立后的企业**为共同诉讼人。

（5）借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，**出借单位和借用人**为共同诉讼人。

（6）保证合同纠纷

连带保证	债权人向保证人和被保证人一并主张权利的	应将**保证人**和**被保证人**列为**共同被告**
	债权人仅起诉被保证人	只列被保证人为被告
	债权人仅起诉保证人的	无需通知被保证人作为共同被告参加诉讼
一般保证	债权人仅起诉保证人的	**应当**通知被保证人作为共同被告参加诉讼
	债权人仅起诉被保证人的	可只列被保证人为被告

（7）无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，**无民事行为能力人、限制民事行为能力人**为共同被告。

（8）在继承遗产的诉讼中，部分继承人起诉的，人民法院应通知其他继承人作为共同原告参加诉讼；被通知的继承人不愿意参加诉讼又未明确表示放弃实体权利的，人民法院仍应将其列为共同原告。

（9）原告起诉被代理人和代理人，要求承担连带责任的，**被代理人和代理人**为共同被告。

（10）共有财产权受到他人侵害，部分共有权人起诉的，**其他共有权人**为共同诉讼人。

（11）以挂靠形式从事民事活动，该**挂靠人和被挂靠人**为共同诉讼人。

（二）普通的共同诉讼

1.普通的共同诉讼，是指诉讼标的属于同一种类，人民法院认为**可以合并审理**并经当事人同意的诉讼。普通的共同诉讼当事人之间没有共同权利义务，其中1人的诉讼行为对其他共同诉讼人**不发生效力**。

2.普通的共同诉讼必须同时具备以下条件：

（1）诉讼标的属于**同一种类**（不能是共同的）；

（2）几个诉讼必须属于同一人民法院管辖；

（3）几个诉讼必须适用同一种诉讼程序；

（4）合并审理能够达到简化诉讼程序、节省时间和费用的目的。

【高频考点】诉讼代理人（★★★）

（一）诉讼代理人的概念与特征

1.概念

根据法律规定或者当事人的授权为一方当事人进行诉讼的人，称为诉讼代理人。

2.特征

（1）诉讼代理人必须**以被代理人的名义**进行诉讼；

（2）诉讼代理人是有诉讼行为能力的人；

（3）同一诉讼代理人只能代理一方当事人，不能同时代理双方当事人；

（4）在代理权限内实施诉讼行为；

（5）代理诉讼行为所产生的法律后果直接由被代理人承担。

（二）法定诉讼代理人

法定诉讼代理人，是指根据法律的规定直接代理无诉讼行为能力的当事人实施民事诉讼行为的人。

法定代理是法律为没有诉讼行为能力的人专门设立的一种诉讼代理制度。

法定代理人的代理权，是根据民法等实体法上规定的**亲权**（父母对未成年子女在人身和财产方面的管教和保护的权利和义务）和**监护权**而产生的。

（二）委托诉讼代理人

1.当事人、法定代理人可以委托 1-2 人作为诉讼代理人。

2.下列人员可以被委托为诉讼代理人：

（1）律师、基层法律服务工作者；

（2）当事人的近亲属或者工作人员；

（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

3.委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的**授权委托书。**

授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为**承认、放弃、变更诉讼请求**，进行**和解**，提起**反诉**或者**上诉**，必须有委托人的**特别授权**。

当事人向人民法院提交的授权委托书，应当在开庭审理前送交人民法院。授权委托书**仅写“全权代理”而无具体授权**的，诉讼代理人**无权**代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提出反诉或者提起上诉。

4.适用简易程序审理的案件，双方当事人同时到庭并径行开庭审理的，可以当场口头委托诉讼代理人，由人民法院记入笔录。

5.委托诉讼代理权在下列情况下归于消灭：

（1）诉讼终结；

（2）委托代理人死亡或者丧失诉讼行为能力；

（3）委托代理人辞去或解除委托。

6.辞却或解除委托，当事人应当**书面**告知人民法院，并由人民法院通知对方当事人，否则，不发生辞却或解除的效力。

第五节 民事诉讼程序

【高频考点】第一审普通程序（★★★）

（一）起诉与受理

1.起诉

（1）起诉条件

①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

②有明确的被告；

③有具体的诉讼请求和事实、理由；

④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

（2）起诉方式

①起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。

②书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

2.受理

（1）审查起诉

①起诉是否属于法院受理民事诉讼的范围；

②是否属于受诉法院的管辖；

③起诉是否符合法定条件；

④起诉手续是否完备；

⑤起诉书内容是否明确具体。

（2）立案

①起诉符合法定条件的，应当在**7日内**立案并通知当事人。

②认为起诉不符合法定条件的，应当在7日内作出不予受理裁定。

③在立案后，发现起诉不符合法定条件的，应当裁定驳回起诉。

（3）法院受理当事人起诉的，诉讼时效重新计算。法院裁定不予受理或驳回起诉的，不发生诉讼时效中断。

（二）审理前的准备

1.送达文书

（1）法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告。

（2）原告口头起诉的，也应当在5日内将记录口头起诉的笔录抄件发送被告。

（3）被告应当在收到之日起15日内提出答辩状。

（4）法院应当在收到答辩状之日起5日内将答辩状副本发送原告。

2.权利告知

法院应当在受理案件通知书和应诉通知书中告知原告和被告所享有的诉讼权利、所承担的诉讼义务，或者以口头形式告知当事人诉讼权利义务。

3.审查诉讼材料和调查收集证据。

4.通知追加当事人。

5.程序分流

（1）当事人没有争议，符合督促程序规定条件的，可以转入督促程序。

（2）开庭前可以调解的，采取调解方式及时解决纠纷。

（3）根据案件情况，确定适用简易程序或者普通程序。

（4）需要开庭审理的，通过要求当事人交换证据等方式，明确争议焦点。

6.召集庭前会议。

（三）审理期限

立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，报请院长批准，批准延长的期限，最长不超过6个月；在上述期限内还未审结，需要延长的，则由受诉法院报请上级法院批准，延长的期限由上级法院决定。

（四）宣判

1.公开宣判

人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。

2.判决书内容

（1）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；

（2）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；

（3）判决结果和诉讼费用的负担；

（4）上诉期间和上诉的法院。

3.裁定适用范围

（1）不予受理；

（2）对管辖权有异议的；

（3）驳回起诉；

（4）保全和先予执行；

（5）准许或者不准许撤诉；

（6）中止或者终结诉讼；

（7）补正判决书中的笔误；

（8）中止或者终结执行；

（9）撤销或者不予执行仲裁裁决；

（10）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；

（11）其他需要裁定解决的事项。

【提示】上述第（1）项～第（3）项可以上诉。

（五）案件在审理中几种特殊情况的处理

1.撤诉

（1）申请撤诉的条件

①必须是原告提出申请；

②向受诉法院提出；

③必须在诉讼程序开始之后，法院宣告判决之前提出；

④申请撤诉是否准许由法院裁定。

（2）按撤诉处理的有

原告（包括无民事行为能力的当事人的法定代理人、有独立请求权的第三人）经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理。

2.缺席判决

（1）被告提出反诉，法院已经把反诉和本诉合并审理，而原告经合法传唤，无正当理由拒不到庭的，或未经法庭许可中途退庭，对反诉可以缺席判决。

（2）不是必须到庭的被告经合法传唤，无正当理由拒不到庭的，或未经法庭许可中途退庭的。

（3）法院裁定不准撤诉的，原告经合法传唤，无正当理由拒不到庭的。

（4）无民事行为能力的被告人的法定代理人，经合法传唤无正当理由拒不到庭的。

（5）无民事行为能力的离婚诉讼，当事人的法定代理人不能到庭的。

3.延期审理

（1）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的。

（2）当事人临时提出回避申请的。

（3）需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的。

4.诉讼中止

（1）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的。

（2）一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的。

（3）作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的。

（4）一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加诉讼的。

（5）本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的。

5.诉讼终结

（1）原告死亡，没有继承人，或者继承人放弃诉讼权利。

（2）被告死亡，没有遗产，也没有应当承担义务的人。

（3）离婚案件一方当事人死亡。

（4）追索赡养费、扶养费、抚养费以及解除收养关系案件的一方当事人死亡。

第十八章 刑法

第一节 刑法基础

【高频考点】追诉时效（★★★）

追诉时效，是指对犯罪分子追究刑事责任的法定有效期限。**超过这个期限，一般不再追究**犯罪分子的刑事责任。

1.追诉时效的期限

（1）法定最高刑为**不满5年**有期徒刑的，**经过5年。**

（2）法定最高刑为**5年以上不满10年**有期徒刑的，**经过10年。**

（3）法定最高刑为**10年以上**有期徒刑的，**经过15年。**

（4）法定最高刑为**无期徒刑、死刑的，经过20年。**如果20年以后认为必须追诉的，须报请**最高人民检察院核准。**

2.追诉期限的计算

（1）一般犯罪追诉期限的计算：从**犯罪之日**起计算。

（2）**连续或继续**犯罪追诉期限的计算：犯罪行为有连续或者继续状态的，从**犯罪行为终了之日**起计算。

3.追诉时效的延长

（1）在人民检察院、公安机关、国家安全机关**立案侦查或者在人民法院受理案件以后，**逃避侦查或者审判的，**不受追诉期限的限制。**

（2）**被害人在追诉期限内提出控告，**人民法院、人民检察院、公安机关应**当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。**

4.追诉时效的中断

在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限**从犯后罪之日**起计算。犯罪分子在实施犯罪行为后，在追诉时效期限内又犯罪的，**前罪的追诉时效就此中断，并从后罪成立之日起重新计算。**

第二节 犯罪构成

【高频考点】犯罪主体（★★★）

（一）自然人犯罪主体

1.刑事责任年龄

（1）已满**16周岁**的人犯罪，应当负刑事责任。

（2）已满**14周岁不满16周岁**的人，犯**故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪**的，应当负刑事责任。

（3）已满**12周岁不满14周岁**的人，犯**故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣**，经**最高人民检察院**核准追诉的，应当负刑事责任。

（4）对未成年人犯罪案件的处理

一是从宽处罚原则，即**已满14周岁不满18周岁**的人犯罪，**应当**从轻或者减轻处罚。因不满16周岁不予刑

事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候,依法进行专门的矫治教育。

二是排除死刑的适用，对犯罪时**不满 18 周岁的人不适用死刑。**

（5）已满 **75 周岁**的人**故意**犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；**过失**犯罪的，**应当**从轻或者减轻处罚。**并且对已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。**

2.刑事责任能力

（1）精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任。

（2）间歇性精神病人在精神正常时犯罪，应当负刑事责任；尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。

（3）**醉酒的人**犯罪的，**应当**负刑事责任。

（4）**又聋又哑**的人或者**盲人**犯罪的，可以**从轻、减轻**或者**免除**处罚。

（二）单位犯罪主体

1.犯罪主体必须是公司、企业、事业单位、机关、团体。

2.主观方面必须有为本单位谋取非法利益的故意，由单位集体或者其负责人作出犯罪决定，并通过直接责任人员加以实施。

3.必须限于《刑法》的特别规定。

第四节 刑罚适用

【高频考点】累犯、自首（★★★）

（一）累犯

1.一般累犯

（1）一般累犯，是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在 5 年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的情况。

（2）一般累犯的成立条件

①前罪和后罪**都必须是故意犯罪。**

②前罪被判处的刑罚和后罪应当判处的刑罚都必须是**有期徒刑以上**的刑罚。

③后罪必须发生在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后的 **5 年之内。**

④累犯**不适用于不满 18 周岁**的人犯罪。

3.特别累犯

（1）特别累犯，是指危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后的任何时候，再犯上述任一类罪的情况。

（2）特别累犯的成立条件

①前罪和后罪都必须是**危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质**的组织犯罪。

②后罪必须发生在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后。

（二）自首

1.一般自首

一般自首，是指犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为。

（1）**自动投案。**犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案，从而将自己置于司法机关的合法控制下，接受司法机关的审查、裁判的行为。下列情形应当**视为自动投案：**

①犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；

②犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；

③罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；

④犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；

⑤经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。

⑥并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；

⑦公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案；

⑧犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的；

⑨明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的；

⑩在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的；

⑪因特定违法行为被采取劳动教养、行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为的；

⑫其他符合立法本意，应当视为自动投案的情形。

【注意】犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。

（2）如实供述自己的罪行

①犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但**在司法机关掌握其主要犯罪事实之前**主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行。

②犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，**只对如实供述部分犯罪的行为，认定**为自首。

③共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，**除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，**才能认定为自首。

④犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又**翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。**

2.特别自首

（1）特别自首，是指被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的行为。

（2）其他罪行，是指供述的罪行在犯罪性质或罪名上与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行不同。

【高频考点】缓刑（★★★）

缓刑，是指附条件地不执行所判刑罚的一种刑罚执行制度。

1.适用对象与条件

（1）适用对象

①缓刑适用于被判处**拘役或者3年以下有期徒刑**的犯罪分子。

②**不满18周岁的**人、**怀孕的妇女**和**已满75周岁**的人，**应当**宣告缓刑。

（2）适用条件

①犯罪情节较轻；

②有悔罪表现；

③没有再犯罪的危险；

④宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

（3）禁止条件

对**累犯**和**犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。**

2.缓刑考验期限

（1）拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上1年以下，但是不能少于2个月。

（2）有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下，但是不能少于1年。

（3）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

3.缓刑的执行

（1）实行社区矫正。

（2）被宣告缓刑的犯罪分子违反禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。

（3）在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑。

（4）在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监管规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。

【高频考点】假释（★★★）

假释，是指对被判处有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期后，如果确有悔改表现，不致再危害社会，附条件地予以提前释放的刑罚执行制度。

1.假释的适用

（1）服刑时间

①被判处**有期徒刑**的犯罪分子，执行原判刑期**1/2以上，**被判处**无期徒刑**的犯罪分子，实际执行**13年以上。**

②被判处**死刑缓期执行的罪犯减为无期徒刑或者有期徒刑**后，**实际执行15年以上**，方可假释，该实际执行时间应当从死刑缓期执行期满之日起计算。

（2）条件

认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的。

2.假释的间隔时间

罪犯减刑后又假释的，间隔时间不得少于 1 年；对一次减去 1 年以上有期徒刑后，决定假释的，间隔时间

不得少于 1 年 6 个月。罪犯减刑后余刑不足 2 年，决定假释的，可以适当缩短间隔时间。

3.限制

（1）对**累犯**以及因**故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪**被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，**不得**假释。

【提示】对于**累犯**，应**当从重处罚，不适用缓刑、不得假释**，对被判处**死刑缓期执行的累犯可以决定对其限制减刑。**

（2）对于生效裁判中有财产性判项，罪犯确有履行能力而不履行或者不全部履行的，不予假释。

（3）对原具有国家工作人员身份犯贪污贿赂罪的罪犯拒不认罪悔罪的，或者确有履行能力而不履行或者不全部履行生效裁判中财产性判项的，不予假释，一般不予减刑。

4.假释的考验期限

（1）依法实行**社区矫正。**

（2）有期徒刑的假释考验期限，为没有执行完毕的刑期；无期徒刑的假释考验期限为 10 年。

5.职业禁止

（1）因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的可以职业禁止。

（2）禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为 3-5 年。

第五节 涉税犯罪

【高频考点】逃税罪（★★★）

1.客体

客体侵犯的是我国税收征收管理制度。

2.客观方面

（1）采取欺骗、隐瞒手段，进行虚假纳税申报或者不申报、不缴或者少缴税款行为。

（2）纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在 **10 万元以上并且占各税种应纳税总额 10%以上，**经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的。

（3）纳税人 5 年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予 **2 次以上行政处罚，**又逃避缴纳税款，数**额在 10 万元以上并且占各税种应纳税总额 10%以上的。**

（4）扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，**数额在 10 万元以上**的。

3.主体

既可以是个人，也可以是单位，包括纳税人和扣缴义务人。

4.主观方面必须是出于直接故意。

5.不构成逃税罪的情形

（1）凡逃税额不足各税种应纳税总额10%的，或者逃税额不足10万元的，或者逃税额超过10万元但不足

各税种应纳税总额10%的，或者逃税额不足10万元但超过各税种应纳税总额10%的，均属于一般逃税违法行为，不构成逃税罪。

（2）5年内因逃避缴纳税款而被税务机关处2次以下行政处罚，或者虽经2次税务行政处罚但再未逃税的，或者2次处罚后又逃税且逃税额在10万元以下的，属于一般税收违法行为。

6.构成犯罪情形

（1）逃税额占各税种应纳税总额10%以上**且**逃税额在10万元以上的，才能构成逃税罪。

（2）凡5年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予2次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在10万元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的，则构成逃税罪。

【高频考点】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪（★★★）

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，是指违反发票管理法规，在没有真实交易情况下故意虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的一种犯罪。

1.客体《刑法》条文没有明确规定，主流观点认为侵犯了国家税收征管制度和国家税收制度。

2.客观方面

实施了虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在10万元以上或者造成国家税款损失数额在5万元以上。

3.主体是一般主体。单位和个人均可构成。

4.主观方面表现为故意。一般情况下，都是为了达到骗取出口退税款、抵扣税款或者其他非法利益的目的而故意虚开。

5.“虚开”

（1）包括**为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开**四种情况。

（2）具有下列行为之一的，属于“虚开增值税专用发票”：

①没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票；

②有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票；

③进行了实际经营活动，但让他人为自己代开增值税专用发票。

【高频考点】虚开发票罪（★★★）

（一）虚开发票的构成

客体	国家发票的管理制度 **【犯罪对象】**普通发票
客观方面	虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的普通发票，情节严重的行为。 **【立案追诉】（2023年新增）**

	①虚开发票金额累计在 50 万元以上的； ②虚开发票 100 份以上且票面金额在 30 万元以上的； ③五年内因虚开发票受过刑事处罚或者二次以上行政处罚，又虚开发票，数额达到上述第①、②项标准 60%以上的。
主体	一般主体，即自然人和单位都可以构成本罪的主体。
主观方面	直接故意

（二）虚开发票罪的处罚

虚开发票罪情节严重的，处 2 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处 2 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯虚开发票罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯罪的规定处罚。

下列情形，属于**情节严重**：

①虚开发票金额累计在 50 万元以上的；

②虚开发票 100 份以上且票面金额在 30 万元以上的；

③五年内因虚开发票受过刑事处罚或者二次以上行政处罚，又虚开发票，数额达到上述第①、②项标准 60%以上的。

情节特别严重具体标准没有统一明确的规定，由各地根据当地经济发展情况，以及虚开发票的社会危害性程度掌握。

第十九章 刑事诉讼法

第二节 刑事诉讼有关制度

【高频考点】认罪认罚从宽制度（★★）

（一）基本原则

1.贯彻宽严相济刑事政策

2.坚持罪责刑相适应

3.坚持证据裁判

4.坚持公检法三机关配合制度

（二）适用范围和适用条件

1.适用阶段和适用案件范围

认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼**全过程**，适用于所有刑事案件的侦查、起诉、审判各个阶段，没有适用罪名和可能判处刑罚的限定，犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的，可以依照规定，按**程序**上从简、**实体**上从宽处理。

【注意 1】认罪，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议。

人、被告人真诚悔罪，愿意接受处罚。

2. 认罪认罚后”从宽＂的把握

（1）″从宽＂的理解。

“可以从宽”**不是一律从宽**，对犯罪性质和危害后果特别严重、犯罪手段特别残忍、社会影响特别恶劣的犯罪嫌疑人、被告人，认罪认罚不足以从轻处罚的，依法不予从宽处罚。

（2）从宽幅度的把握。

办理认罪认罚案件，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段、对查明案件事实的价值和意义是否确有悔罪表现，以及罪行严重程度等，**综合考量**确定从宽的限度和幅度。

（三）权益保障

1.犯罪嫌疑人、被告人辩护权保障

（1）获得法律帮助权

（2）法律帮助的衔接及拒绝法律帮助的处理

（3）辩护人职责

2.被害方权益保障

（1）听取意见

（2）促进和解、谅解

（3）被害方异议的处理

3.强制措施的适用

（1）对于罪行较轻、采用非羁押性强制措施足以防止发生有关规定的社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人，根据犯罪性质及可能判处的刑罚，依法可**不适用**羁押性强制措施。

（2）犯罪嫌疑人认罪认罚，公安机关认为罪行较轻、没有社会危险性的，应当**不再**提请人民检察院审查逮捕。

（3）已经逮捕的犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的，人民法院、人民检察院应当及时审查羁押的必要性，经审查认为没有继续羁押必要的，应当**变更为取保候审**或者**监视居住**。

（四）侦查机关职责

1.对移送审查起诉的案件，公安机关应当在**起诉意见书中写明犯罪嫌疑人自愿认罪认罚**情况。

2.认为案件符合速裁程序适用条件的，可以在**起诉意见书中建议检察院适用速裁程序办理**，并简要说明理由。

3.对**可能适用速裁程序**的案件，公安机关应当快速办理，对犯罪嫌疑人未被羁押的，可以**集中移送审查起诉**，但不得为集中移送拖延案件办理。

（五）检察院的职责

1.权利告知

2.提供法律帮助

3.权利保障

4.自愿性、合法性审查

5.签署具结书

（1）犯罪嫌疑人自愿认罪，同意量刑建议和程序适用的，**应当在辩护人或者值班律师在场**的情况下签署认罪认罚具结书。

（2）犯罪嫌疑人不需要签署认罪认罚具结书的情形：

①犯罪嫌疑人是**盲、聋、哑人**，或是**尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人**的；

②未成年犯罪嫌疑人的**法定代理人、辩护人**对未成年人认罪认罚**有异议**的；

③其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。

6.提起公诉

（1）犯罪嫌疑人认罪认罚的，检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等**提出量刑建议**。

①犯罪嫌疑人**侦查阶段**认罪认罚的，**主刑从宽的幅度可以适当放宽**；

②被告人在**审判阶段**认罪认罚的，可以**适当缩减**。

③建议判处罚金刑的，参照主刑的从宽幅度提出确定的数额。

（2）犯罪嫌疑人自愿认罪并且愿意积极赔偿损失，但由于被害方赔偿请求明显不合理，未能达成调解或者和解协议的，一般不影响对犯罪嫌疑人从宽处理。

（3）犯罪嫌疑人认罪认罚，检察院经审查

①认为符合速裁程序适用条件的，应当在**10日以内**作出是否提起公诉的决定；对可能判处的有期徒刑**超过1年**的，可以**延长至15日**。

②认为不符合速裁程序适用条件的，应当在规定的期限内作出是否提起公诉的决定。（1个月+15日）

（六）人民法院的职责

1.认罪认罚的审查

2.量刑建议的审查与调整

（1）量刑建议的审查

对于检察院提出的量刑建议，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名准确，量刑建议适当的，法院应当采纳。

具有下列情形之一的，不予采纳：

①被告人的行为**不构成犯罪**或**不应当追究刑事责任**的；

②被告人**违背意愿**认罪认罚的；

③被告人**否认**指控的犯罪事实的；

④**起诉指控**的罪名与**审理认定**的罪名**不一致**的；

⑤其他可能影响公正审判的情形。

【注意】对于检察院起诉指控的事实清楚，量刑建议适当，但**指控的罪名与审理认定的罪名不一致**的，法院可以听取检察院、被告人及其辩护人对审理认定罪名的意见，依法作出裁判。

（2）量刑建议的调整

①法院经审理，**认为量刑建议明显不当**，或被告人、辩护人对量刑建议**有异议且有理有据**的，检察院可以

调整量刑建议。

②法院认为调整后的量刑建议适当的，应当予以采纳；

③检察院**不调整**量刑建议或者**调整后仍然明显不当**的，法院应当依法作出判决。

【高频考点】刑事辩护制度（★★★）

（一）辩护种类

1.自行辩护

犯罪嫌疑人、被告人为自己进行的辩护。

自行辩护贯穿于刑事诉讼**整个过程**。

2.委托辩护

犯罪嫌疑人、被告人依法委托律师或者其他具有法定资格的公民担任辩护人。

（1）犯罪嫌疑人自被侦查机关**第一次讯问**或者**采取强制措施**之日起，有权委托辩护人；在**侦查期间**，只能委托**律师**作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

（2）侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。

人民检察院自收到移送起诉案件材料之日起 3 日内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。

人民法院自受理案件之日起 3 日内，应当告知被告人有权委托辩护人。

犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民检察院和公安机关应当及时、人民法院应当在 3 日以内向其监护人、近亲属或者其指定的人员转达要求。

3.指定辩护

遇有法律规定的特定情况时，司法机关通知依法承担法律援助义务的机构指派律师，为没有委托辩护被告人进行辩护。

（1）**可以**指定辩护

对下列没有委托辩护人的被告人，人民法院可以通知法律援助机构指派律师为其提供辩护：

①共同犯罪案件中，其他被告人已经委托辩护人的；

②案件有重大社会影响的；

③人民检察院抗诉的；

④被告人的行为可能不构成犯罪的；

⑤有必要指派律师提供辩护的其他情形。

（2）**应当**指定辩护

对下列没有委托辩护人的犯罪嫌疑人、被告人，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护：

①盲、聋、哑人；

②尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人；

③可能被判处无期徒刑、死刑的人。

【注意】高级人民法院复核死刑案件和死刑缓期执行期间故意犯罪的案件，被告人没有委托辩护人的，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。

（二）辩护人范围及其限制

1.犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托 1-2 人作为辩护人。1 名辩护人**不得**为 2 名以上的同案被告人，或者未同案处理但犯罪事实存在关联的被告人辩护。

2.下列的人可以被委托为辩护人：

（1）律师；

（2）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；

（3）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

3.下列人员**不得**担任辩护人：

（1）正在被执行刑罚或者处于缓刑、假释考验期间的人；

（2）依法被剥夺、限制人身自由的人；

（3）被开除公职或者被吊销律师、公证员执业证书的人；

（4）人民法院、人民检察院、监察机关、公安机关、国家安全机关、监狱的现职人员；

（5）人民陪审员；

（6）与本案审理结果有利害关系的人；

（7）外国人或者无国籍人；

（8）无行为能力或者限制行为能力的人。

第（3）项至第（7）项规定的人员，如果是被告人的监护人、近亲属，由被告人委托担任辩护人的，可以准许。

4.审判人员和人民法院其他工作人员从人民法院**离任**后 **2 年**内，不得以律师身份担任辩护人。

审判人员和人民法院其他工作人员从人民法院**离任**后，不得担任原任职法院所审理案件的辩护人，但系被告人的监护人、近亲属的除外。

审判人员和人民法院其他工作人员的配偶、子女或者父母不得担任其任职法院所审理案件的辩护人，但系被告人的监护人、近亲属的除外。

（三）辩护人的权利与义务

1.辩护人的责任

根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。

2.辩护人的权利

（1）侦查期间辩护律师的权利

辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。

（2）会见、通信权（原则上辩护律师不需要经许可）

①辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。**其他辩护人**经人民法院、人民检察院**许可**，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

【注意】危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。

②辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟**不得超过 48 小时**。

③辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移**送审查起诉之日**起，可以向犯罪嫌疑人、被告人**核实有关证据**。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。

（3）查阅案件材料权（辩护律师不需要经许可）

辩护律师自人民检察院对案件**审查起诉之日**起，可以查阅、摘抄、复制案卷材料。其他辩护人经人民法院、人民检察院**许可**，也可以查阅、摘抄、复制案卷材料。

①人民检察院检察委员会的讨论记录、人民法院合议庭、审判委员会的讨论记录以及其他依法不公开的材料**不得**查阅、摘抄、复制。

②复制案卷材料可以采用复印、拍照、扫描、电子数据拷贝等方式。

③辩护律师可以申请查阅作为证据材料向人民法院移送的讯问录音录像，值班律师可以查阅案卷材料。

④查阅、摘抄、复制案卷材料，涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当保密；对不公开审理案件的信息、材料，或者在办案过程中获悉的案件重要信息、证据材料，不得违反规定泄露、披露，不得用于办案以外的用途。

（4）申请调取证据权

辩护人认为在调查、侦查、审查起诉期间监察机关、公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料未随案移送，**申请人民法院调取**的，应当以**书面**形式提出，并提供相关线索或者材料。

（5）调查取证权（仅辩护律师享有调查取证权）

①**辩护律师**经证人或者其他有关单位和个人**同意**，可以向他们收集、调取与本案有关的材料，也可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据，或者申请人民法院通知证人出庭作证。

②**辩护律师**经人民检察院或者人民法院**许可**，并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意，可以向他们收集与本案有关的材料。

3.辩护人义务

（1）辩护人或者其他任何人，不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，不得威胁、引诱证人作伪证以及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为。

（2）辩护人收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据，应当及时告知公安机关、人民检察院、人民法院。

（3）辩护律师对在执业活动中知悉的委托人的有关情况和信息，有权予以**保密**。但是，辩护律师在执业活

动中知悉委托人或者其他人，准备或者正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪的，应当及时告知司法机关。